

발 간 등 록 번 호
11-1130000-000489-01

가맹사업법상 불공정행위에 대한 세부 판단기준
(가맹분야 불공정거래행위 심사지침 제정)
마련을 위한 연구

2021. 9.

공정거래위원회

제 출 문

공정거래위원회 위원장 귀하

“가맹사업법상 불공정행위에 대한 세부 판단기준 (가맹분야
불공정거래행위 심사지침)마련에 관한 연구용역” 의
「최종보고서」를 다음과 같이 제출합니다.

2021. 9.

한국공정거래조정원

[연구수행자]

책임연구원: 유 영 국 (한국공정거래조정원 공정거래연구센터 연구위원)

연 구 원: 박 미 영 (한국공정거래조정원 공정거래연구센터 연구위원)

연 구 원: 박 준 영 (한국공정거래조정원 공정거래연구센터 연구위원)

< 목 차 >

제1장 서설·····	8
제1절 연구의 필요성 ·····	8
제2절 연구의 목표와 기대성과·····	11
제2장 가맹거래법상 불공정거래행위 규제·····	15
제1절 가맹사업법상 불공정거래행위 규제의 정당성과 그 필요성···	15
1. 가맹사업법 제정 배경과 입법취지·····	15
2. 가맹사업법 통한 불공정거래행위 규제의 정당성과 필요성·····	17
제2절 가맹사업법상 불공정거래행위 금지체계·····	20
1. 가맹사업법의 위반행위 개관·····	20
2. 가맹사업법상 불공정거래행위 금지의 법원(法源)과 체계·····	22
가. 가맹사업법 제12조	
나. 가맹사업법 시행령 제13조	
다. 가맹사업법 시행령 [별표 2] : 불공정거래행위의 유형 또는 기준	
3. 기타 금지행위·····	26
가. 부당한 점포환경개선 강요 금지 등(법 제12조의2)	
나. 부당한 영업시간 구속 금지(법 제12조의3)	
다. 부당한 영업지역 침해 금지(법 제12조의4)	

제3절 소규모가맹본부에 대한 적용배제 등	31
1. 가맹사업법 제3조	31
2. 적용제외 요건	31
3. 적용제외의 예외	32

제3장 가맹사업법상 가맹사업의 개념과 가맹본부의 거래상 지위 34

제1절 '가맹사업'의 개념과 다른 거래 유형과의 구분 34

1. '가맹사업'의 개념과 특성	34
2. 가맹거래법 제2조 제1항에 따른 가맹거래의 개념적 표지와 그 해석	37
3. 대리점 거래 등 다른 거래유형과의 구분	40
4. 가맹거래법상 '가맹거래'여부의 판단 기준 명확화: 거래의 특수성 강조	44
5. 플랫폼 연계 가맹거래의 특성 등 반영 필요성	45

제2절 가맹본부의 '거래상 지위'여부 판단과 관련 심·결례 50

1. '거래상 지위'의 개념적 이해와 판단 기준	50
가. '거래상 지위'의 개념	
나. 거래상 지위의 판단 기준과 가맹사업법 관련 공정거래위원회 심결례	
2. 공정거래법 및 가맹사업법 관련 판례 상 거래상 지위의 판단	58

제4장 위법성 판단기준 62

제1절 가맹사업법상 불공정거래행위의 위법성 요건 62

1. 위법성 요건에 대한 해석론 일반·····	62
2. 법률 조문별 위법성 요건·····	63
3. 쟁점별 정리·····	65

제2절 공정거래법상 불공정거래행위의 위법성 판단기준····· 67

1. 공정거래법상 불공정거래행위 위법성 판단기준·····	67
가. '공정거래저해성'의 의의 - '부당성'과의 관계	
나. 공정거래저해성의 내용	
다. 공정거래저해성의 판단방법 ① : '부당하게'와 '정당한 이유없이'	
라. 공정거래저해성의 판단방법 ② : '우려'의 판단	
마. 공정거래저해성의 판단방법 ③ : 종합적 접근방법	
2. 소결·····	75
가. 가맹사업법과 공정거래법의 관계	
나. 공정거래법상 공정거래저해성의 법리 참조	
다. 중복되는 금지행위 유형의 범위반 예시	

제3절 대리점법, 대규모유통업법상 불공정거래행위 위법성 판단기준·· 81

1. 대리점법상 불공정거래행위 위법성 판단·····	81
가. 대리점법 제6조 내지 제12조	
나. 심사지침 상 대리점거래에서의 부당성 판단기준	
2. 대규모유통업법상 불공정거래행위 위법성 판단·····	85
가. 대규모유통업법상 불공정거래행위	
나. 심사지침상 위법성 심사기준	

3. 소결·····	87
------------	----

제4절 가맹사업법 위반행위 사례 분석·····	88
----------------------------------	-----------

1. 공정거래위원회 심결례, 법원 판례 검토의 의의·····	88
-----------------------------------	----

2. 주요 심결례 및 판례 검토·····	88
------------------------	----

가. 가맹거래 관련 주요 심결례 분석

나. 가맹거래 관련 주요 판결 분석

제5장 결론: 가맹분야 불공정거래행위 심사지침(안)·····	107
--	------------

제1장 서설

제1절 연구의 필요성

- 최근 공정거래위원회에서 발표한 2020년도 가맹산업 현황에 의하면,¹⁾ 지난해 말 정보공개서 등록 기준 가맹본부 수, 브랜드 수, 가맹점 수는 각각 5,602개, 7,094개, 258,889개로, 모두 5년 연속 증가하는 추세를 보이고 있음²⁾
- 소규모 자본만으로 가맹본부가 제공하는 안정된 시스템과 브랜드 이미지 등을 이용하여 비교적 쉽게 창업할 수 있고, 경영과정에서 우려되는 사업적 위험부담을 줄이는 동시에 상품판매 등에만 전념할 수 있다는 점에서,³⁾ ‘가맹사업’은 ‘소상공인들의 생계유지를 위한 대표적 사업 모델’로 자리 잡음⁴⁾
- 그런데 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」(이하 ‘가맹사업법’) 제2조 제1호에 따른 ‘가맹사업’의 개념 정의에 비추어 보면, 가맹본부와 가맹점 사업자 간 거래구조에서는 양자의 매우 긴밀한 ‘상호의존적 관계’가 필연적으로 형성될 수밖에 없으며, 이는 가맹거래를 둘러싼 다양한 논쟁의 근본적 원인이 됨⁵⁾

가맹사업이라 함은 가맹본부가 가맹점사업자로 하여금 자기의 상표·서비스표·상호·간판 그 밖의 영업표지를 사용하여 일정한 품질기준이나 영업방식에 따라

1) 공정거래위원회, “공정위, 2020년도 가맹사업 현황 발표”, 2021.3.5. 보도자료. 공정거래위원회는 가맹본부가 등록한 정보공개서를 토대로 2020년도 가맹산업 현황을 발표하였으며, 동 현황은 브랜드 및 가맹본부는 ‘20년 말 기준, 가맹점은 ‘19년 말(정보공개서 내 기재 정보) 기준으로 작성되었다.

2) 공정거래위원회, 위 보도자료, 6면. 동 현황의 업종별 가맹점 수 분포에 따르면 가맹점수 100개 이상인 대형 브랜드는 5.7%에 불과한 반면, 가맹점수 10개 미만인 브랜드가 전체의 65.3%를 차지하고 있는 것으로 나타났다.

3) 김태희 외, “가맹사업 동기와 업종에 따른 점포운영특성, 관계특성, 성과 차이에 관한 연구”, 「식품유통연구」 제31권 제3호, 한국식품유통학회, 2014, 108-110면.

4) 김태희 외, 위의 글, 110-111면(‘프랜차이즈사업 선택 동기’ 부분 참조)

5) 2010.5.14. 법 개정으로 가맹업 관련 규정이 마련된 상법 제13장 가맹업(제168조의6 내지 168조의9)에 규정된 가맹업의 의의와 가맹업자 및 가맹상의 의무 역시 이러한 관계에 기초하고 있다.

상품 또는 용역을 판매하도록 하고, 가맹점사업자는 영업표지의 사용과 경영 및 영업활동 등에 대한 지원·교육의 대가로 가맹본부로부터 교육과 통제를 받으며, 가맹본부에 가맹금을 지급하는 지속적인 거래관계를 말함

- 가맹거래에 있어서 ‘가맹본부 - 가맹점사업자’ 양자의 관계는 양면적 속성을 가지는데, 한편으로는 ‘공동의 이익증진 및 상생협력의 토대’로서 역할을 하고, 다른 한편으로는 ‘거래상 우월적 지위 강화와 불공정거래관행 발생·고착의 기초’로 작용함
- 후자의 맥락에서 가맹점의 가맹본부에 대한 거래의존도가 절대적으로 높을 수밖에 없는 거래의 특성을 감안하면,⁶⁾ 가맹본부의 불공정거래 관행은 영세한 가맹점사업자의 직접적 피해로 이어질 수 있음⁷⁾
- 그에 따라 ‘가맹본부의 갑질을 방지하고 가맹점주 등 소상공인을 보호하기 위한 법·정책적 체계 강화’에 관한 요구가 지속되어 왔고, 공정거래위원회 또한 가맹사업법 관련 법·정책적 체계를 정립하고 실효적인 법집행을 위하여 꾸준히 노력하고 있음
- 그러나 이러한 노력에도 불구하고, 가맹거래 분야의 현실과 특수성이 반영된 별도의 ‘가맹사업법상 불공정행위에 대한 세부 판단기준’이 현재까지도 마련되지 못하면서, 공정거래위원회는 가맹사업법의 집행에 있어서 공정거래법상 「불공정거래행위 심사지침」 등을 활용해야만 하였음

6) 다른 상거래행위에서 찾아보기 어려운 가맹사업거래 관계의 특수한 성질에 관하여, 독립적 사업자 간 거래관계임에도 불구하고 가맹본부의 가맹점주에 대한 일정한 인적·물적 의무와 그에 따른 지배 관계에서 비롯된다고 지적하는 견해도 있음. 박은정, “가맹거래계약관계와 노동법: 지배종속의 발견”, 「월간 노동리뷰」, 2015.10., 37-42면.

7) 국민권익위원회, “가맹점사업자 보호 및 공정화를 위한 제도개선”, 2010.5., 3면(‘분쟁발생’ 부분 참조): “가맹점사업자는 가맹본부의 영업노하우나 지원시스템에 의존하여야 하고, 가맹본부는 경영과정에서 가맹점사업자를 통제하기 때문에 당사자 간에 ‘경제력’이나 ‘정보력’ 등에 있어서 대등한 관계가 어려움. 이로 인하여 강자인 가맹본부가 약자인 가맹점사업자의 활동을 부당하게 구속·제한하고, 불공정한 영업계약으로 과도한 폭리를 취하여 영세 가맹점사업자의 피해를 유발하는 등 관련 분쟁 증가”

- 특히, 가맹거래 관련 불공정행위에 대하여 공정거래법상 「불공정거래 행위 심사기준」을 적용해야 하는 상황은 법 해석에 있어서 가맹거래의 특수성이 반영되지 못하고, 그에 따라 가맹사업법상 적용대상, 금지행위 유형과 부당성을 판단하는 단계에서 일정한 법리적 한계를 노정해 옴
- 한편, 「대리점거래 공정화에 관한 법률」(이하 “대리점법”)과 「대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률」(이하 “대규모유통업법”)의 경우 각각 1개 이상의 불공정거래행위 또는 특정한 행위의 부당성 심사 기준을 이미 마련하여 운영 중에 있음⁸⁾
- 이에 가맹사업법상 불공정행위에 대한 세부 판단기준을 마련하여, ‘유통 3법 간 규정체계의 정합성’을 확보하는 동시에 수범자의 예측 가능성을 제고할 필요성이 있음
- 아울러, 플랫폼 기반 사업모델의 확산과 같은 최근의 급속한 거래환경 변화에 대응하기 위한 가맹거래법상 불공정행위의 판단기준 마련이 요구됨
- 가맹본부의 온라인판매에 따른 가맹점 등 소상공인의 피해를 예방하고 권익을 보호하기 위한 기반 마련 필요
- 가맹택시(카카오택시·타다 등)와 배달의민족·요기요 등 플랫폼 연계 가맹거래 등 새로운 영역에서 불공정거래 관련 민원이 다수 제기되고

8) 현재 유통 3법과 관련하여 제정·시행 중인 불공정거래행위 관련 심사지침

대리점법	대규모유통업법
대리점분야 불공정거래행위 심사지침 (2020.6.30. 제정)	TV홈쇼핑사업자의 특정 불공정거래행위에 대한 위법성 심사지침 (2015.12.31. 제정)
	대규모유통업 분야에서 판매장려금의 부당성 심사에 관한 지침 (2013.10.2. 제정)
	대규모 유통업 분야의 특약매입거래에 관한 부당성 심사지침 (2014.7.7. 제정)
	대규모유통업자의 반품행위에 대한 위법성 심사지침 (2018.2.14. 제정)
	온라인쇼핑몰업자의 불공정거래행위 심사지침 (2021.2.1. 제정)

있어 이에 대한 판단기준도 정립 필요

제2절 연구의 목표와 기대성과

1. 연구의 목표

- 이번 연구는 가맹분야의 거래현실과 특수성, 기존의 다양한 가맹사업법 위반 사례를 반영한 「가맹분야 불공정거래행위 심사지침」 제정안의 초안을 마련하여 공정거래위원회에 제공하는 것을 목표로 함

2. 연구의 기대성과

- 1) 가맹사업법상 ‘가맹거래’의 법적 개념을 구체화 하고 다른 거래방식과의 구분을 위한 명확한 기준 마련
- 심사지침 제정안은 가맹사업법 제2조 제1호에 따른 ‘가맹사업’해당성 여부를 판단하기 위한 각 표지의 의미를 구체화할 예정임
 - 동일한 영업표지를 사용하는 대리점 등 유사한 거래방식과 가맹거래를 구분하기 위한 기준을 제시할 것임
 - 특히, 가맹거래와 대리점거래의 개념 요건과 특수성, 실제 거래방식 등을 고려하여 양 자를 합리적으로 구분할 수 있는 표지를 도출하고자 함⁹⁾
 - 대리점법 제2조 제1호는 ‘대리점거래’에 해당하기 위해서는 i) 상품 또는 용역의 재판매 또는 위탁판매를 위해 행해지는 거래, ii) 일정기간 지속되는 계약을 체결하여, 반복적으로 행해지는 거래일 것

9) 양 자의 구분 결과에 따라서 적용 법조를 달리하는 만큼 구체적 기준의 제시가 중요함.

을 요건으로 규정함

- 2019년 추진된 '대리점거래에서의 불공정거래행위 심사지침' 마련을 위한 연구에서 대리점법 적용대상이 되는 대리점거래의 범위를 구체화 하기 위하여, ① 재판매 또는 위탁판매, 일정기간 지속되는 계약, 반복 적으로 행하여지는 거래 등 용어에 대한 정의 마련 및 유사개념(상법 등)과 비교, ② 가맹거래와 대리점거래의 구분기준(가맹금, 대리점 유통 마진 비교, 계약갱신권 등)의 명확화 등의 방식을 취한 바 있음
- 무엇보다도, 전속적 대리점거래 등과 가맹거래의 구별이 용이하지 않기 때문에 가맹거래와 대리점거래 등의 특징을 비교하여 양자를 구별할 개념적 표지와 명확한 기준을 제시하고자 함

2) 가맹거래의 부당성 판단기준 제시

○ 가맹사업법 제12조(불공정거래행위의 금지) 내지 제12조의4(부당한 영업 지역 침해금지)의 부당성 판단기준 도출

- 공정거래법상 「불공정거래행위 심사지침」¹⁰⁾과 대리점업법상 「대리점 분야 불공정거래행위 심사지침」¹¹⁾, 「대리점거래에서 금지되는 불공정거래행위 유형 및 기준 지정고시」¹²⁾ 등의 부당성 판단 기준을 비교·분석
- 실제로 2019년 「대리점분야 불공정거래행위 심사지침」 초안이 공정 거래법상 「불공정거래행위 심사지침」과의 형식적·내용적 측면의 정합성을 고려하면서 대리점거래의 특수성 등을 반영하는 방식으로 마련된 바 있음

10) 공정거래위원회 예규 제351호 「불공정거래행위 심사지침」, 2020.7.29.; '불공정거래행위의 위법성 판단기준'과 '유형별 불공정거래행위 위법성 판단기준'에 관한 자세한 논의는 김형배, 「공정거래법의 이론과 실제」, 도서출판 삼일, 2019, 321-325면 및 329-420면.

11) 공정거래위원회 예규 제348호 「대리점분야 불공정거래행위 심사지침」, 2020.6.30.

12) 공정거래위원회 고시 제2018-22호 「대리점거래에서 금지되는 불공정거래행위 유형 및 기준 지정고시」, 2018.12.21.

3) 가맹사업법 위반행위 유형별로 구체적인 위법성 심사기준을 마련

○ 공정거래위원회 심결례 및 법원 판례를 분석하여 위법성 심사기준 제시

- 거래거절 행위(법 제12조 제1항 제1호), 구속조건부 행위(법 제12조 제1항 제2호), 거래상지위의 남용 행위(법 제12조 제1항 제3호), 부당한 손해배상의무 부과행위(법 제12조 제1항 제5호), 그 밖의 불공정행위(법 제12조 제1항 제6호), 부당한 점포환경개선 강요 금지(법 제12조의2), 부당한 영업시간 구속 금지(법 제12조의3), 부당한 영업지역 침해 금지(법 제12조의4), 보복조치의 금지(법 제12조의5) 등의 사례를 검토·분석하여 위법성 심사기준을 제시

- 가맹본부의 가맹사업법 위반행위에 해당될 수 있는 구체적 사례를 예시 하면서 법 위반행위에 해당되지 않는 사례를 함께 제시

○ 가맹사업법 위반행위 중 공정거래법 제23조의 불공정거래행위와 중복되는 행위유형에 대해 심사기준에서 양자의 유사성·차별성을 제시할 예정임

4) 온라인·플랫폼 기반 사업모델의 확산 등 최근 거래환경 변화에 따른 가맹사업법상 불공정행위의 판단기준 마련

○ 카카오 등 가맹택시 및 배달의민족·요기요 등 플랫폼 관련 가맹거래의 시장현황과 특성 분석

○ 플랫폼 관련 가맹거래에서 발생할 수 있는 법 위반행위 유형을 분석하고 상기 가맹거래 행위 유형별 위법성 심사기준에 반영

5) 「가맹분야 불공정거래행위 심사지침」 제정안 마련

- 가맹분야 불공정거래행위 심사지침 제정안을 도출하기 위한 이론적·현실적 근거를 제시하고, 아래 제정안 목차에 부합하는 심사지침 제정안 초안을 작성하고자 함

제2장 가맹사업법상 불공정거래행위 규제

제1절 가맹사업법상 불공정거래행위 규제의 정당성과 그 필요성

1. 가맹사업법 제정 배경과 입법취지

- 1990년대 이후 프랜차이즈 즉, 가맹사업이 외식업, 소매업 등을 중심으로 급속히 확산되면서, 허위·과장에 의한 가맹점 모집, 부실한 가맹사업 운영 및 가맹본부의 불공정한 거래관행 등에서 비롯된 가맹본부와 가맹점사업자와의 분쟁이 증가하게 됨
- 이러한 가맹사업에서의 불공정한 거래관행을 시정하기 위해 공정거래위원회는 공정거래법상 금지된 불공정거래행위의 일환으로 「가맹사업에 있어서의 불공정거래행위 기준」을 1997년에 제정·운영하였음
- 그러나 공정거래위원회 고시만으로는 가맹사업 거래에 있어서 필수적이고 핵심적인 것으로 인식되는 정보공개, 계약기간 보장 등에 대한 법적 보호가 불충분하다는 지적이 있었고, 그에 따라 2002년 5월 13일 가맹본부의 사전의무 등을 강화한 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」(이하 ‘가맹사업법’)을 제정함으로써 사후규제뿐만 아니라 탄력적인 규제수단을 마련할 수 있게 됨
- 가맹사업법의 제정이유는 ‘가맹사업의 공정한 거래질서를 확립하고, 가맹본부와 가맹점사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형 있게 발전할 수 있도록 하기 위하여 가맹본부와 가맹점사업자가 준

수하여야 할 기본적인 사항을 규정하고, 가맹사업과 관련된 불공정 거래행위를 금지하려는 것임

- 이를 바탕으로 가맹사업법은 가맹사업의 공정한 거래질서를 확립하고 가맹본부와 가맹점사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형 있게 발전하도록 함으로써 소비자 복지의 증진과 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 함(법 제1조)
- 내용적인 측면에서는 전통적인 사후규제와 적극적인 사전규제를 혼합하여 규정하고 있으며, 가맹사업거래분쟁조정협의회를 통한 자율 규제 내용을 함께 담고 있음
- 가맹본부가 거래상 지위를 남용하지 못하도록 함으로써 가맹점사업자가 대등한 지위에서 공정하게 거래할 수 있도록 보장하는 것은 일견 중소기업자보호의 성격을 가지며, 이것이 목적조항에서 규율하는 공정거래법의 궁극적 목적 즉, 소비자 복지 또는 소비자 이익의 증진과 언제나 일치하지는 않음¹³⁾
 - 즉, 장기적으로는 중소기업자 발전이 경쟁을 촉진시킴으로써 소비자의 선택 폭을 넓히는 등 양자가 일치할 것이지만, 단기적으로는 가맹점사업자를 보호하기 위한 수단이 소비자에게는 불이익이 될 수 있음¹⁴⁾
 - 따라서 가맹사업법은 구체적인 해석에 있어 가맹점사업자의 이익과 소비자의 이익을 적절히 교량·형량하는 작업이 필요할 것이

13) 이봉의, “가맹사업법상 ‘가맹금’의 주요 쟁점”, 「경쟁과 법」 제3호, 서울대학교 경쟁법센터, 2014, 18면.

14) 이봉의, 앞의 글, 18면.

고, 가맹거래의 공정화를 실현하고 궁극적으로 소비자 복지를 증진하기 위한 것으로 집행되어야 할 것임¹⁵⁾

2. 가맹사업법을 통한 불공정거래행위 규제의 정당성과 필요성

- 가맹사업거래에서 발생하는 불공정거래행위에 대하여 공정거래법을 중심으로 한 기존의 법규정을 엄격하게 적용하는 동시에 보다 실효적인 집행을 위한 별도의 판단기준 마련과 규제제도 개선을 통하여 가맹사업거래에서의 문제 해결을 주장할 수 있음¹⁶⁾
 - 무엇보다도 불공정거래행위로서 거래상 지위남용 행위의 규제는 가맹사업관행에서 나타나는 불공정거래행위를 규율하는 데에 중요한 역할을 할 수 있음. 실제로 가맹사업거래에 있어서 가맹본부와 가맹점사업자의 관계를 고려하면 거래상 지위의 인정이 보다 용이할 것이며, 거래상 지위남용에 해당하는 구체적 행위유형이 가맹사업거래에서 불공정거래행위로서 쉽게 인정될 여지도 있음
 - 하지만 공정거래법에 따른 불공정거래행위로서 거래상 지위남용 행위의 규제는 가맹사업거래에서 발생하는 문제의 해결에 있어서 충분하지 않을 수 있는데, 이는 결국 공정거래법이 가맹사업거래의 특성과 법리적 쟁점을 충분히 반영하지 못하는 데에 이유가 있음¹⁷⁾
- 거래상 지위남용 행위를 가맹본부와 가맹점사업자 간의 거래에

15) 이봉의, 앞의 글, 19면.

16) 대표적으로 박세환, “공정위의 최근 불공정거래행위 심결례에 대한 소고”, 『경쟁법연구』 제41권, 한국경쟁법학회, 2020, 104-106면.

17) 유사한 논리로 대리점거래에서의 불공정거래행위를 별도로 규제해야 한다는 필요성에 대해 서술한 보고서로는 공정거래위원회, 불공정거래행위 및 시장지배적 지위남용행위 관련 위원회 심결 정리 및 분석, 정책연구용역보고서(연구책임자: 홍명수), 2007, 5면.

적용할 경우에, 상대적으로 열등한 지위에 있는 거래상대방으로서 가맹점사업자의 자율적 의사 존부가 실질적인 쟁점이 되는 경우가 많음

- 공급업자의 행위가 거래상 지위의 남용인지 여부와 관련하여 거래상대방이 자발적 의사로 불이익을 수용한 경우로 판단되면 규제 대상이 되지 않음. 이때 거래상대방 의사의 자율성은 실질적으로 파악하여야 하는데, 구체적인 사건에서 이에 대한 판단이 전혀 용이하지 않음
- 거래상대방으로서 가맹점사업자는 가맹본부로부터 불이익을 당한 경우에도 거래관계가 지속될 것을 고려하여 장기적·종합적인 관점에서 당장의 불이익을 감수할 가능성도 큼
- 위와 같은 문제는 가맹사업거래뿐만 아니라 대규모유통거래 및 대리점 거래에서도 유사하게 나타나는데, 공정거래위원회는 이에 기반 하여 거래의 공정화를 위한 다양한 노력을 기울이고 있음. 특히 「대리점 분야 불공정거래행위 심사지침」(2020.6.30. 시행)과 「온라인쇼핑몰 업자의 불공정거래행위 심사지침」(2021.2.1. 시행)은 해당 사업영역에서 거래상 지위남용 규제의 실효성을 높이기 위한 조치로 평가될 수 있음
- 마찬가지로 가맹사업거래의 불공정성 문제가 공정거래법상 거래상 지위남용의 구체화를 통하여 해결될 것으로 기대하는 데에는 일정한 한계가 있음.¹⁸⁾ 따라서 가맹사업법에서 규율하는 불공정거래행위에 대한 범위반행위 유형과 위법성 판단기준 등을 분명히 하는 것이

18) 공정거래위원회, 앞의 정책연구용역보고서 (연구책임자: 홍명수), 5면.

필요할 것이고, 이와 같은 맥락에서 「가맹사업거래에서의 불공정 거래행위 심사지침」의 마련 근거를 찾을 수 있을 것임

제2절 가맹사업법상 불공정거래행위 금지체계

1. 가맹사업법의 위반행위 개관

- 가맹사업법은 폭넓은 사후규제와 더불어 다양한 사전규제, 그리고 가맹사업거래 분쟁조정제도의 자율규제를 함께 규율하고 있음
- 우선 사전규제로는 가맹본부와 가맹점사업자의 준수사항(법 제5조, 제6조), 정보공개서의 등록 및 제공의무(법 제6조의2, 제7조), 가맹금 예치(법 제6조의5), 가맹금 반환(법 제10조), 가맹계약서의 기재사항(법 제11조)이 있음
- 그러나 가맹사업법은 전통적인 사후금지(ex post prohibition)를 중심으로 불공정거래행위의 금지(법 제12조), 부당한 점포환경개선 강요 금지(법 제12조의2), 부당한 영업시간 구속 금지(법 제12조의3), 부당한 영업지역 침해 금지(법 제12조의4) 및 정당한 사유없는 가맹계약의 갱신 거절 금지(법 제13조) 등을 폭넓게 규정하고 있음
- 법 제12조에 따라 구체적으로 금지되는 불공정거래행위에는 가맹점 사업자에 대하여 상품이나 용역의 공급 또는 영업의 지원 등을 부당하게 중단 또는 거절하거나 그 내용을 현저히 제한하는 행위(제1호), 가맹점사업자가 취급하는 상품 또는 용역의 가격, 거래 상대방, 거래지역이나 가맹점사업자의 사업활동을 부당하게 구속하거나 제한하는 행위(제2호), 거래상의 지위를 이용하여 부당하게 가맹점사업자에게 불이익을 주는 행위(제3호), 계약의 목적과 내용, 발생할 손해 등에 비하여 가맹점사업자에게 부당하게 손해배상

의무를 부담시키는 행위(제5호), 제1호부터 제3호까지 및 제5호
 외의 행위로서 부당하게 경쟁가맹본부의 가맹점사업자를 자기와
 거래하도록 유인하는 행위 등 가맹사업의 공정한 거래를 저해할
 우려가 있는 행위(제6호)가 있음

가맹사업법상 사전규제	▶ 가맹본부의 준수사항 (법 제5조) ▶ 가맹점사업자의 준수사항 (법 제6조) ▶ 정보공개서의 등록 등 (법 제6조의2) ▶ 정보공개서의 제공의무 등 (법 제7조) ▶ 가맹금 예치 (법 제6조의5) ▶ 가맹금 반환 (법 제10조) ▶ 가맹계약서의 기재사항 (법 제11조)
가맹사업법상 사후규제	▶ 불공정거래행위의 금지 (법 제12조) - 거래거절 (제1호) - 구속조건부 거래 (제2호) - 거래상 지위의 남용 (제3호) - 부당한 손해배상의무 부과행위 (제5호) - 그 밖의 불공정거래행위 (제6호) ▶ 부당한 점포환경개선 강요 금지 (법 제12조의2) ▶ 부당한 영업시간 구속 금지 (법 제12조의3) ▶ 부당한 영업지역 침해 금지 (법 제12조의4) ▶ 정당한 사유없는 가맹계약의 갱신 거절 금지(법 제13조)

2. 가맹사업법상 불공정거래행위 금지의 법원(法源)과 체계

가. 가맹사업법 제12조

- 가맹사업법은 가맹본부의 불공정거래행위를 다섯 가지로 열거하면서 가맹사업의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위를 하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다고 규정하고 있음 (법 제12조 제1항 각호)
- 가맹사업법이 예시하고 있는 행위유형은 다음과 같음
 - ① 가맹점사업자에 대하여 상품이나 용역의 공급 또는 영업의 지원 등을 부당하게 중단 또는 거절하거나 그 내용을 현저히 제한하는 행위(거래거절)
 - ② 가맹점사업자가 취급하는 상품 또는 용역의 가격, 거래상대방, 거래지역이나 가맹점사업자의 사업활동을 부당하게 구속하거나 제한하는 행위(구속조건부 거래)
 - ③ 거래상의 지위를 이용하여 부당하게 가맹점사업자에게 불이익을 주는 행위(거래상 지위의 남용)
 - ④ 계약의 목적과 내용, 발생할 손해 등 대통령령으로 정하는 기준에 비하여 과중한 위약금을 부과하는 등 가맹점사업자에게 부당하게 손해배상 의무를 부담시키는 행위(부당한 손해배상 의무 부과행위)
 - ⑤ ①~④ 이외의 행위로서 부당하게 경쟁가맹본부의 가맹점사업자를 자기와 거래하도록 유인하는 행위 등 가맹사업의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위(그 밖의 불공정거래행위)
- 위에서 정한 행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정하도록 위임함 (법 동조 제2항)

나. 가맹사업법 시행령 제13조

- 시행령은 법 제12조 제2항의 규정에 따라 불공정거래행위의 유형 또는 기준을 [별표 2]에 별도로 마련하고 있음(영 제13조 제1항)
- 아울러 공정거래위원회는 필요하다고 인정하는 경우에 [별표 2]의 유형 또는 기준의 범위 내에서 특정업종 또는 특정행위에 적용되는 세부적인 불공정거래행위의 유형 또는 기준을 정하여 고시할 수 있는데(영 동조 제2항), 지금까지 이 규정에 따라 제정된 고시는 존재하지 않음

다. 가맹사업법 시행령 [별표 2] : 불공정거래행위의 유형 또는 기준

- 시행령 [별표 2]는 가맹사업법이 금지하는 불공정거래행위를 '1. 거래거절, 2. 구속조건부 거래, 3. 거래상 지위의 남용, 4. 부당한 손해배상 의무 부과 행위, 5. 그 밖의 불공정거래행위'로 유형화하여 구체적인 내용을 규정함
- 먼저 '1. 거래거절'에 관해서는 '가. 영업지원 등의 거절, 나. 부당한 계약갱신의 거절, 다. 부당한 계약해지'로 구분하고, 부당한 계약갱신 거절은 다시 '1) 직영점 설치 목적의 계약갱신 요구 거절, 2) 차별적인 계약갱신 요구 거절, 3) 점포환경개선 비용 관련 계약 갱신 요구 거절, 4) 기타 계약갱신 거절'로 분류하고 있음
- 부당하게 또는 정당한 이유없이 '거래거절'을 당한 가맹점사업

자는 자신의 사업이 위축되거나 불의에 사업을 중단할 위기에 처하게 되어 결국 시장에서의 경쟁이 감소될 위험이 존재하기 때문에 규제의 필요성이 있음

- 다음으로 ‘2. 구속조건부 거래’는 ‘가. 가격의 구속, 나. 거래상 대방의 구속, 다. 가맹점사업자의 상품 또는 용역의 판매제한, 라. 영업지역의 준수강제, 마. 그 밖에 가맹점사업자의 영업활동의 제한’으로 구분됨

- 가맹사업거래에서는 기본적으로 당해 가맹사업을 영위하는 데 필수적이고 통일적인 브랜드 이미지를 제공할 수 있는 품목에 대해 ‘배타적 공급계약’이 내재되어 있으나, 구체적인 거래의 형태 또는 구속의 정도가 공정한 경쟁을 저해할 우려가 있는 경우에는 불공정한 거래방법으로서 규제를 받음

- ‘3. 거래상 지위의 남용’은 ‘가. 구입강제, 나. 부당한 강요, 다. 부당한 계약조항의 설정 또는 변경, 라. 경영의 간섭, 마. 판매목표 강제, 바. 불이익제공’으로 구분되어 있음

- 가맹사업은 실제 거래관계에서 가맹점사업자가 가맹본부에 의존하거나 지시에 따라야 하는 사업구조의 형태를 가지고 있어 가맹본부의 거래상 지위 남용행위에 따른 분쟁의 소지가 많아 해당사업자의 시장에서의 우월한 지위의 정도 및 상대방이 받게 되는 불이익의 내용과 정도 등을 종합적으로 고려하여 불공정한 거래행태를 규율하고자 함

- ‘4. 부당한 손해배상 의무 부과행위’에 대해서는 ‘가. 과중한 위약금

설정·부과행위, 나. 소비자 피해에 대한 손해배상의무 전가행위, 다. 부당한 영업위약금 부과행위, 라. 그 밖의 손해배상의무 부과행위'로 구분되어 있으며, 이 중 과중한 위약금 설정·부과행위는 '1) 계약 중도해지 시 과중한 위약금 설정·부과 행위, 2) 과중한 지연손해금 설정·부과행위'로 분류되어 규율하고 있음

- 가맹사업거래에서는 가맹본부와 가맹점사업자 간의 교섭력의 차이 또는 계약의 성질 등으로 인하여 부당한 손해배상의무 부과행위가 나타날 여지가 많음. 이러한 불공정거래행위는 공정거래법상 불이익 제공행위로서 해석될 여지는 있으나 가맹사업거래의 특성을 반영하여 가맹사업법에 명시적인 규정을 두어 규율하고 있음

- '5. 그 밖의 불공정거래행위'는 따로 유형을 세분하지는 아니하고, 가맹본부가 다른 경쟁가맹본부의 가맹점사업자를 자기와 거래하도록 하여 자기의 가맹점사업자의 영업에 불이익을 주거나 다른 경쟁가맹본부의 가맹사업에 불이익을 주는 행위를 뜻한다고 규정함

1. 거래거절	가. 영업지원 등의 거절 나. 부당한 계약갱신의 거절 1) 직영점 설치 목적의 계약갱신 요구 거절 2) 차별적인 계약갱신 요구 거절 3) 점포환경개선 비용 관련 계약갱신 요구 거절 4) 기타 계약갱신 요구 거절 다. 부당한 계약해지
---------	---

2. 구속조건부 거래	가. 가격의 구속 나. 거래상대방의 구속 다. 가맹점사업자의 상품 또는 용역의 판매제한 라. 영업지역의 준수강제 마. 그 밖에 가맹점사업자의 영업활동의 제한
3. 거래상 지위의 남용	가. 구입강제 나. 부당한 강요 다. 부당한 계약조항의 설정 또는 변경 라. 경영의 간섭 마. 판매목표 강제 바. 불이익제공
4. 부당한 손해배상의무 부과행위	가. 과중한 위약금 설정·부과행위 1) 계약 중도해지 시 과중한 위약금 설정·부과 행위 2) 과중한 지연손해금 설정·부과행위 나. 소비자 피해에 대한 손해배상의무 전가행위 다. 부당한 영업위약금 부과행위 라. 그 밖의 부당한 손해배상의무 부과행위
5. 그 밖의 불공정거래행위	○ 다른 경쟁가맹본부의 가맹점사업자와 관련한 불공정거래행위

3. 기타 금지행위

가. 부당한 점포환경개선 강요 금지 등 (법 제12조의2)

- 가맹사업법에 따르면 가맹본부는 다음의 정당한 사유 없이 점포환경개선을 강요할 수 없음(법 제12조의2 제1항)
- 점포의 시설, 장비, 인테리어 등의 노후화가 객관적으로 인정되는

경우(영 제13조의2 제1항 제1호)

- 위생 또는 안전의 결함이나 이에 준하는 사유로 인하여 가맹사업의 통일성을 유지하기 어렵거나 정상적인 영업에 현저한 지장을 주는 경우(영 제13조의2 제1항 제2호)

· 또한, 가맹본부는 다음 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고 가맹점사업자의 점포환경개선에 소요되는 비용으로서 대통령령으로 정하는 비용의 100분의 40 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율에 해당하는 금액을 부담하여야 함(법 제12조의2 제2항)

- 가맹본부의 권유 또는 요구가 없음에도 가맹점사업자의 자발적 의사에 의하여 점포환경개선을 실시하는 경우(동조 제2항 제1호)

- 가맹점사업자의 귀책사유로 인하여 위생·안전 및 이와 유사한 문제가 발생하여 불가피하게 점포환경개선을 하는 경우(동조 제2항 제2호)

- 한편, 여기서 말하는 '대통령령으로 정하는 비용'이란 '1. 간판 교체비용, 2. 인테리어 공사비용(장비·집기의 교체비용을 제외한 실내건축공사에 소요되는 일체의 비용)'을 뜻하고(영 제13조의2 제2항 각호), '대통령령으로 정하는 비율'은 점포의 확장 또는 이전을 수반하지 아니하는 경우에는 100분의 20, 점포의 확장 또는 이전을 수반하는 경우에는 100분의 40에 해당함(영 제13조의2 제3항 각호)

· 가맹점의 점포환경개선이 실시되는 경우 가맹본부도 매출증대효과

등의 이익을 함께 누리게 되는 점을 고려하여 가맹본부가 그 비용의 일부를 부담하도록 하고, 가맹본부가 불필요하게 점포환경개선을 요구하는 행위를 방지하여 가맹점사업자의 권익보호를 강화하는 데 목적이 있음

나. 부당한 영업시간 구속 금지 (법 제12조의3)

- 가맹본부는 정상적인 거래관행에 비추어 부당하게 가맹점사업자의 영업시간을 구속하는 행위를 할 수 없음(법 제12조의3 제1항)
- 가맹사업법은 다음 두 가지 유형의 가맹본부 행위를 부당한 영업시간 구속으로 간주함(법 제12조의3 제2항 각호, 영 제13조의3)
 - 가맹점사업자의 점포가 위치한 상권의 특성 등의 사유로 오전 0시부터 오전 6시까지 또는 오전 1시부터 오전 6시까지의 매출이 그 영업에 소요되는 비용에 비하여 저조하여 직전 3개월 동안 영업손실이 발생함에 따라 가맹점사업자가 영업시간 단축을 요구함에도 이를 허용하지 아니하는 행위(제1호)
 - 가맹점사업자가 질병의 발병과 치료 등 불가피한 사유로 인하여 필요 최소한의 범위에서 영업시간의 단축을 요구함에도 이를 허용하지 아니하는 행위(제2호)
- 가맹본부가 우월한 거래상 지위를 이용하여 부당한 영업시간을 강요함에 따라 가맹점사업자의 피해가 확산되는 것을 예방하기 위하여, 가맹본부가 가맹점사업자의 영업시간을 부당하게 구속하는 행위를 불공정한 거래행위로서 허용하지 않음

다. 부당한 영업지역 침해금지 (법 제12조의4)

- 가맹본부는 가맹계약 체결 시 가맹점사업자의 영업지역을 설정하여 가맹계약서에 이를 기재하여야 함(법 제12조의4 제1항)
- 가맹본부가 가맹계약 갱신과정에서 상권의 급격한 변화 등 대통령령으로 정하는 사유가 발생하여 기존 영업지역을 변경하기 위해서는 가맹점사업자와 합의하여야 함(법 제12조의4 제2항)
 - 재건축, 재개발 또는 신도시 건설 등으로 상권의 급격한 변화가 발생하는 경우(영 제13조의4 제1호)
 - 해당 상권의 거주인구 또는 유동인구가 현저히 변동되는 경우(영 제13조의4 제2호)
 - 소비자의 기호변화 등으로 인하여 해당 상품·용역에 대한 수요가 현저히 변동되는 경우(영 제13조의4 제3호)
 - 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 경우로서 기존 영업지역을 그대로 유지하는 것이 현저히 불합리하다고 인정되는 경우(영 제13조의4 제4호)
- 나아가 가맹본부는 정당한 사유 없이 가맹계약기간 중 가맹점사업자의 영업지역 안에서 가맹점사업자와 '동일한 업종'의 자기 또는 계열회사의 직영점이나 가맹점을 설치하는 행위를 할 수 없음(법 제12조의4 제3항)
 - 여기서 말하는 '동일한 업종'은 수요층의 지역적·인적 범위,

취급품목, 영업형태 및 방식 등에 비추어 동일하다고 인식될 수 있을 정도의 업종을 의미함

- 영업지역의 설정 강제는 사전적 행태규제로서 가맹사업법 전체 체계와 부조화될 뿐만 아니라 사실상 시장을 분할하여 독점을 형성하고 경쟁을 저해할 수 있는 경쟁법상의 문제를 내포하지만,¹⁹⁾ 가맹본부가 가맹점사업자의 영업지역을 설정 및 보호함으로써 무엇보다 가맹점사업자의 매출감소를 방지하고 가맹점사업자의 권익보호를 강화하는 실익이 있음

19) 이혁, “프랜차이즈 영업지역 규제의 문제점과 개선방안”, 「기업법연구」 제28권 제4호, 한국기업법학회, 2014.12., 165면.

제3절 소규모가맹본부에 대한 적용배제 등

1. 가맹사업법 제3조

- 가맹사업법은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 즉, 가맹금의 총액 및 연간매출액이 크지 않은 소규모가맹본부에 대해 동법을 적용하지 않는다는 규정을 마련하고 있음(동법 제3조 제1항 각호)
- 현행 법률(법률 제18113호, 시행 2021.4.20.)은 제3조의 조문제목을 '적용배제'로 하고 있지만, 조만간 시행될 개정 법률(법률 제18190호, 시행 2021.11.19.)에서는 '소규모가맹본부에 대한 적용배제 등'으로 변경되어 동조 및 가맹사업법 전체 취지를 보다 명확히 보여주는 것이라 할 수 있음

2. 적용제외 요건

- 동조에 따라 가맹사업법이 적용되지 않는 경우는 다음과 같음
 - ① 가맹점사업자가 가맹금의 최초 지급일부터 6개월까지의 기간 동안 가맹본부에게 지급한 가맹금의 총액이 100만 원 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 금액을 초과하지 아니한 경우(동조 동항 제1호)
 - 현행 시행령에 따르면 여기에 해당하는 가맹금 총액은 100만 원임(령 제5조 제1항)
 - ② 가맹본부의 연간 매출액이 2억 원 이내의 범위에서 대통령령으로

정하는 일정규모 미만인 경우(동조 동항 제2호)

- 현행 시행령에 따르면 여기에 해당하는 연간매출액은 5천만 원(해당 가맹사업과 같은 품질기준이나 영업방식에 따라 상품이나 용역을 판매하는 직영점을 개설하여 운영하고 있는 경우에는 해당 직영점의 매출액을 포함하여 5천만 원)을 말함(령 제5조 제2항 본문)
- 다만, 가맹본부가 가맹사업을 시작하기 전에 직영점을 개설하여 운영한 기간이 1년 이상인 경우에는 2억 원(직영점의 매출액을 포함하여 2억 원)으로 함(령 제5조 제2항 단서)
- 가맹본부의 연간매출액에 관해서는 시행령이 보다 더 상세한 규정을 두고 있는데, 먼저 연간매출액 산정은 바로 전 사업 연도의 손익 계산서상의 매출액으로 하지만(령 제5조 제3항 본문), 가맹본부가 손익계산서를 작성하지 아니하는 경우에는 「부가가치세법」에 따른 바로 전 2개 과세기간의 부가가치세확정신고서상의 과세표준과 면세 수입금액을 합한 금액으로 확정함(령 제5조 제3항 단서)
- 또한, 가맹본부가 가맹사업을 시작한 후 1년이 지나지 아니한 경우에는 사업을 시작한 때부터 마지막으로 부가가치세확정신고를 한 때까지의 부가가치세확정신고서(부가가치세확정신고를 하지 아니한 경우에는 부가가치세예정신고서)상의 과세표준과 면세수입금액을 합한 금액을 제3항 단서의 금액으로 보기로 규정함(령 제5조 제4항)

3. 적용제외의 예외

- 위 규정에도 불구하고 법 제6조의2부터 제6조의5까지, 제7조, 제9조,

제10조 및 제15조의2는 모든 가맹사업거래에 적용됨(법 제3조 제2항)

- 따라서 본 연구의 대상인 불공정거래행위에 관해서는 법 제3조의 적용제외가 해당되므로 가맹금 100만원 미만, 연간 매출액 5천만 원 미만인 가맹본부에 대해서는 법 제12조, 제12조의2 내지 제12조의4가 적용되지 않음

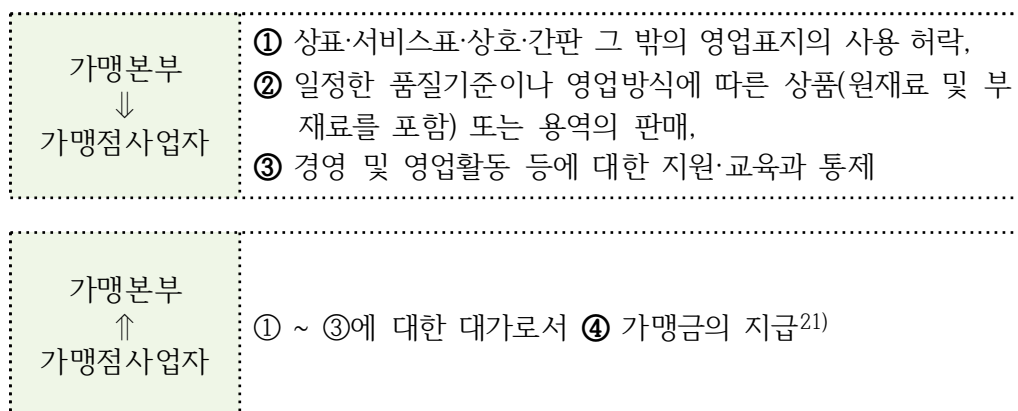
가맹사업법 적용제외 요건	▶ 가맹점사업자가 가맹본부에게 지급한 가맹금이 총액 100만원 미만인 경우 (법 제3조 제1항 제1호) ▶ 가맹본부의 연간매출액이 5천만 원 미만인 경우 (법 제3조 제1항 제2호)
가맹사업법 적용제외의 예외조항	▶ 정보공개서의 등록 등 (법 제6조의2) ▶ 정보공개서의 등록의 거부 등 (법 제6조의3) ▶ 정보공개서 등록의 취소 (법 제6조의4) ▶ 가맹금 예치 등 (법 제6조의5) ▶ 정보공개서의 제공의무 등 (법 제7조) ▶ 허위·과장된 정보제공 등의 금지 (법 제9조) ▶ 가맹금의 반환 (법 제10조) ▶ 가맹점사업자피해보상보험계약 등 (법 제15조의2)

제3장 가맹사업의 개념과 적용범위 및 가맹본부의 거래상 지위

제1절 가맹거래법상 ‘가맹거래’의 개념과 다른 거래 유형과의 구분

1. ‘가맹사업’의 개념과 특성

- 가맹사업법 제2조 제1호는 “가맹사업”을 가맹본부가 가맹점사업자로 하여금 자기의 상표·서비스표·상호·간판 그 밖의 영업표지(이하 “영업표지”)를 사용하여 일정한 품질기준이나 영업방식에 따라 상품(원재료 및 부재료를 포함) 또는 용역을 판매하도록 함과 아울러 이에 따른 경영 및 영업활동 등에 대한 지원·교육과 통제를 하며, 가맹점사업자는 영업표지의 사용과 경영 및 영업활동 등에 대한 지원·교육의 대가로 가맹본부에 가맹금을 지급하는 지속적인 거래관계로 규정하고 있음²⁰⁾
- 동법 제2조 제1호에 따른 ‘가맹사업’의 정의 규정에 의하면, 가맹본부와 가맹점사업자의 ‘계속적 거래관계’로서 가맹사업의 개념적 표지는 다음과 같이 도출될 수 있음



20) 가맹사업, 이른바 프랜차이즈 등 용어의 유래와 입법 배경에 관하여는 신동권, 「중소기업보호법」, 박영사, 2020, 379-380면.

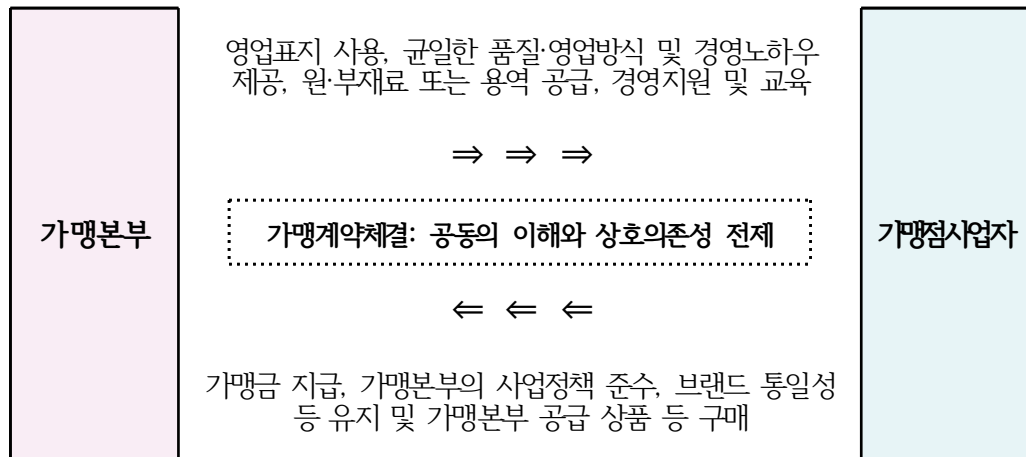
- 다만, 위에서 구분한 ① 내지 ④의 표지가 가맹거래만의 고유한 개념적 표지는 아니며, 다른 유통(거래)방식에서도 동일한 성격으로 규정될 수 있는 부분이 있음. 그럼에도 불구하고, '③ 경영 및 영업활동 등에 대한 지원·교육과 통제'는 가맹거래의 특징적 표지로서 다른 거래방식과의 구분에 있어서 중요한 의미를 가짐
- 이와 같은 ① 내지 ④의 개념적 표지는 가맹본부와 가맹점사업자 간의 '상호의존적 이해관계' 내지 '상당한 정도의 종속성 내지 의존성'이 사업활동에 전제될 수밖에 없음을 보여줌. 이는 다른 거래 유형과의 비교에 있어서 주된 차이점인 동시에 가맹사업에 있어서 우려되는 다양한 불공정거래관행의 구조적 배경이 됨
- 한편, 아래의 헌법재판소 전원재판부 결정은²²⁾ 가맹사업의 본질적 특성을 이해함에 있어서 주목할 만함

가맹사업의 동일성과 가맹본부의 명성을 유지하기 위하여 가맹본부가 가맹점사업자에게 가맹본부의 영업전략과 기업문화에 맞는 일정한 지시 및 통제를 하여야 한다. 이때 가맹본부의 통제는 가맹점사업자 영업의 주된 부분에 관련된 것이어야 하고, 통제의 정도는 단순한 제의나 암시보다는 강하고, 강압적 요구보다는 약한, 상당한 수준의 지시 및 통제를 의미한다.

- 가맹사업법 제2조 제1항 및 헌법재판소의 가맹사업 개념에 관한 규정과 결정은 다음과 같은 가맹거래의 구조적 이해의 기초를 제공함

21) '가맹금'에 관하여는, 이봉의, 앞의 글, 18-27면.

22) 헌법재판소 2015.9.24. 선고 2015헌마149 경정(전원재판부) - 심의절차종료결정취소.



- 가맹본부와 가맹사업자간 체결하는 가맹계약의 기본적 속성이자 전제로서 ‘공동의 이해와 상호의존성’을 거래당사자간 경제적 이해의 측면에서 실시한 아래의 서울고법 판결은²³⁾ 거래본부와 가맹점사업자간의 가맹거래의 속성을 명확히 제시하고 있음

가맹사업은 경제적 측면에서 볼 때 가맹사업자가 다수의 가맹점을 모아 적은 자본으로 전국적인 유통망을 만들 수 있고, 가맹점이 인건비, 재고비용, 가맹점 운영비등을 부담하므로 유통망 유지비용이 절감되는 이점이 있으며, 가맹계약자의 측면에서는 가맹사업자의 기술력, 노하우와 명성, 그리고 경영전반에 대한 지도와 지원 아래 경영경험이 없이도 소자본으로 사업을 할 수 있고, 가맹본부를 통해 효과적인 홍보를 할 수 있으며 공동의 대량 구매, 공동물류 등으로 운영경비를 대폭 절감할 수 있기 때문에 단시일 내에 투자효과를 거둘 수 있는 이점을 지니고 있는 것으로 일반적으로 이해된다.

- 이에 더하여, 다음의 대법원 판례는²⁴⁾ 위와 같은 가맹거래 관계에 있어서 가맹본부와 가맹사업자의 경영상 기본적 관계를 명확히 하고 있음. 이러한 대법원의 판시는 다른 유통(거래)방식과의 구분에 있어서 핵심적 표지를 지적한 것으로 볼 수 있음

23) 서울고등법원 2001.12.4. 선고 2000누2183 판결.

24) 대법원 2018.7.20. 선고 2015두59679 판결; 대법원 1996.2.23. 선고 95도2608 판결.

가맹사업법의 적용 대상이 되는 가맹계약은 각각 독립된 상인인 가맹본부와 가맹점사업자 사이의 가맹점운영과 관련된 계속적 거래관계에 관한 계약으로 볼 수 있고, 가맹점사업자는 기본적으로 가맹본부의 지원 및 경영지도 등에 기초하여 가맹점을 독자적인 책임과 비용으로 경영하여야 한다.

- 특히, 아래의 서울고법 및 대법원의 판결은²⁵⁾ '가맹거래의 본질에 기초한 가맹거래의 개념적 이해'의 단초를 제공하는 것으로서, 가맹거래의 양 당사자로서 가맹본부와 가맹사업자의 이해관계가 대립적 성격의 일반적 거래와 다른 '특수성'을 전제하고 있음을 명확히 함

가맹사업은 서로 이해관계가 대립하는 자를 양 당사자로 하는 일반 거래관계와는 달리 기본적으로 상대방을 통하여 자신의 단점을 보완하고 장점을 살려나가는 상호의존적인 면이 강한 사업방식으로 가맹본부와 다수의 가맹점사업자가 일종의 가맹사업조직을 형성하여 가맹사업의 유지·발전이라는 공동의 이해관계를 전제한다는 특수성을 가진다.

2. 가맹거래법 제2조 제1항에 따른 가맹거래의 개념적 표시와 그 해석

가. 상표·서비스표·상호·간판 그 밖의 영업표지 사용

- '상표'란 자기의 상품(지리적 표시가 사용되는 상품의 경우를 제외하고는 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함)과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)을 말함. 가맹본부는 자신의 상품과 타인의 상품을 구분하기 위하여 상표를 사용할 수 있고, 이를 가맹점사업자도 사용할 수 있도록 허락할 수 있음

- '서비스표'라 함은 서비스업을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타

25) 서울고등법원 2001.12.4. 선고 2000누2183 판결; 대법원 2005.6.9. 선고 2003두7484 판결.

인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말함

- 또한 '상호'란 사업자가 영업활동을 함에 있어서 자기의 영업을 타인의 영업과 식별하기 위하여 정하고 사용하는 명칭으로서 상인의 명칭을 의미한다. 상법 제46조 제20호에 따른 상인으로서 가맹본부는 그 성명 기타의 명칭으로 상호를 정할 수 있으며, 이를 가맹점사업자도 사용할 수 있도록 허락할 수 있다.

나. 일정한 품질기준이나 영업방식에 따라 상품(원재료 및 부재료를 포함) 또는 용역을 판매하도록 함

- 가맹본부의 품질기준 설정은 제품이나 서비스를 시간, 재료, 성과, 신뢰도, 외형 또는 제품의 특성 등의 측면에 비추어 일정한 표준에 부합하도록 함을 의미함. 아울러, 영업방식 설정은 영업시간·판매 방식·고객응대요령, A/S 기준 등 을 일정한 표준에 맞추는 것을 말함
- 가맹사업에서는 가맹사업의 통일성과 가맹본부의 명성 유지를 위하여 합리적으로 필요한 범위 내에서 가맹점사업자가 판매하는 상품 및 용역에 대하여 가맹점사업자로 하여금 가맹본부가 제시하는 품질기준 준수를 요구하고, 그러한 품질기준의 준수를 위하여 필요한 경우 가맹본부가 제공하는 상품 또는 용역을 사용하도록 요구할 수 있음²⁶⁾
- 가맹점 매뉴얼(manual)은 가맹본부가 제품의 통일성과 품질관리 및 명성의 유지를 위하여 가맹점계약에 터잡아 가맹점운영규칙의 일환으로 제정하여 운영하는 것이므로, 가맹점사업자가 상품을 제조·판매·보관·포장하는 등의 방법에 관하여는 물론 가맹점계약에 의하여

26) 대법원 2005.6.9. 선고 2003두7484 판결.

가맹점사업자에게 부과되어 있는 의무를 구체화하기 위한 내용도 포함될 수 있음²⁷⁾

다. 경영 및 영업활동 등에 대한 지원·교육과 통제

- 가맹본부는 해당 사업 분야에서 자기만 가지고 있는 사업노하우, 영업비밀, 영업방식 등을 가맹점사업자에게 전수하여야 함

상법 제168조의7(가맹업자의 의무) ① 가맹업자는 가맹상의 영업을 위하여 필 요한 지원을 하여야 한다.

- 이에 가맹본부는 가맹사업의 동일성과 가맹본부의 명성 유지를 위하여 가맹점사업자에게 가맹본부의 영업전략과 기업문화에 맞는 일정한 지시 및 통제를 하며, 이때 가맹본부의 통제는 가맹점사업자 영업의 주된 부분에 관련된 것이어야 하고, 통제의 정도는 단순한 제의나 암시보다는 강하고, 강압적 요구보다는 약한, 상당한 수준의 지시 및 통제를 의미함²⁸⁾

라. 가맹금을 지급하는 지속적인 거래관계

- 가맹계약은 독립된 상인 간에 일방이 타방의 상호, 상표 등의 영업 표지를 이용하고, 그 영업에 관하여 일정한 통제를 받으며, 이에 대한 대가를 타방에 지급하기로 하는 특수한 계약형태로서, 그 기본적인 성격은 각각 독립된 상인으로서 의 가맹본부 및 가맹점사업자 간의 계약기간 동안의 지속적인 물품공급계약이라 할 것임²⁹⁾

27) 대법원 2005.6.9. 선고 2003두7484 판결.

28) 헌법재판소 2015.9.24. 선고 2015헌마149 결정(전원재판부) - 심의절차종료결정취소.

29) 대법원 1996.2.23. 선고 95도2608 판결.

- 일회성 기술이나 노하우 전수 등에 따른 대가 지급의 관계는 이에 해당하지 않음

3. 대리점 거래 등 다른 거래유형과의 구분: 여집합적 거래유형의 상호적 포섭

- 주지한 바와 같이, ‘가맹거래’는 다른 유통(거래)방식들과 비교하여 공통되는 개념적 표지를 가짐. 동시에 그 정도를 달리할 수는 있으나 가맹거래의 특수성을 부각하는 표지로서 ‘경영 및 영업활동 등에 대한 지원·교육과 통제’가 전제될 수 있음³⁰⁾

- 이러한 맥락에서 가맹사업법 제2조 제1항에 ‘가맹거래’ 개념의 정의 규정이 마련되어 있음에도 불구하고 가맹거래는 그 속성상 다른 거래 유형, 예를 들면 대리점사업자, 상법상 위탁판매인, 대리상, 중개인 또는 상표 등의 사용권자와 유사한 측면이 있어 그 개념적 구분을 요함

제168조의6(의의) 가맹업자는 가맹상의 영업을 위하여 필 요한 지원을 하여야 한다. 자신의 상호·상표 등(이하 이 장에서 “상호등”이라 한다) 을 제공하는 것을 영업으로 하는 자[이하 “가맹업자”(加盟業者)라 한다]로부터 그의 상호등을 사용할 것을 허락받아 가맹업자가 지정하는 품질 기준이나 영업방식에 따라 영업을 하는 자를 가맹상(加盟商)이라 한다.

제168조의7(가맹업자의 의무) ① 가맹업자는 가맹상의 영업을 위하여 필요한 지원을 하여야 한다.

② 가맹업자는 다른 약정이 없으면 가맹상의 영업지역 내에서 동일 또는 유사한 업종의 영업을 하거나, 동일 또는 유사한 업종의 가맹계약을 체결할 수 없다.

제168조의8(가맹상의 의무) ① 가맹상은 가맹업자의 영업에 관한 권리가 침해되지 아니하도록 하여야 한다.

② 가맹상은 계약이 종료한 후에도 가맹계약과 관련하여 알게 된 가맹업자의 영업상의 비밀을 준수하여야 한다.

30) 이와 동일한 견해로, 윤성운·조준연, “가맹사업 관련 법적 개념과 관련 쟁점”, 「경쟁과 법」 제3호, 서울대학교 경쟁법센터, 2014.10., 13면: “가맹사업 내지 가맹거래의 가장 근본적인 표지 내지 상품 등의 유통에 있어서의 상인 간의 다른 거래 형태와의 본질적 차이는 ‘경영 및 영업활동 등에 대한 지원·교육과 통제’라고 볼 수 있을 것이다.”

- 다만, 위에서 보는 바와 같이 상법 제13장(제168조의6 내지 168조의10)에서 가맹업에 관한 구체적 규정을 별도로 마련(2010.5.14. 신설)하고 있는 만큼 상법상 대리상(제87조), 중개인(제93조) 및 위탁판매인(제101조 내지 제102조) 개념과의 구분은 대리점법상 대리점 개념과의 비교에 보다 의미 있을 것임.³¹⁾ 이에 가맹거래와 대리점거래 간 개념적 구분 집중할 필요가 있음
- 실제로 가맹사업법을 비롯한 대리점법과 대규모유통업법은 각 법률이 포섭하지 못하는 거래 형태, 즉 여집합적 유형을 상호적으로 포섭하고 있으나,³²⁾ 그 경계가 언제나 명확한 것은 아님
- 이러한 맥락에서, 가맹본부로부터 동일한 영업표지를 사용하고 지원·교육과 통제를 받으며 가맹금을 받는 경우에만 가맹사업거래에 해당될 수 있으며, 대리점법은 가맹사업법 제2조 제1호에서 정하는 가맹사업에 해당하는 거래의 경우 대리점법을 적용하지 않도록 하여, 중복적용을 피하고 있음. 가맹사업법이 적용되지 않은 거래의 경우

31) 이와 관련하여, 공정거래위원회, 대리점거래에서의 불공정거래행위 심사지침 마련을 위한 연구, 서울대학교 산학협력단 (연구책임자: 이봉익), 2018, 35-36면; 김운정, “대리점법 집행기준 및 운용방안 연구”, 「현안분석」 2016-03, 법제연구원, 2016, 63면. 상법상 대리상에는 계약의 체결과 이행을 대리하는 ‘계약대리상’과 중개를 대리하는 ‘중개대리상’이 있음. 자기의 명의 없이 보험사의 대리점이나 이동통신사의 대리점과 같은 본사의 계약체결을 대리하는 ‘계약대리상’ 또는 금융투자 대리점과 같이 본사의 계약체결을 중개하는 ‘중개대리상’은 대리점법상 위탁판매에 해당된다고 볼 필요가 있음.

구 분	거래유형	특 징
대리점법	재판매	자기명의○, 자기계산○
	위탁판매	자기계산X, 위탁수수료○, 특정 공급업자
상법	대리상	자기명의X, 자기계산X, 판매수수료○
	중개인	자기명의X, 자기계산X, 중개수수료○, 불특정 공급업자
	위탁매매	자기명의○, 자기계산X, 위탁수수료○, 불특정 공급업자

32) 공정거래위원회, 앞의 정책연구용역보고서 (연구책임자: 이봉익), 30면: “대리점법은 가맹사업법, 대규모유통업법이 적용되지 않은 거래형태를 규제할 수 있도록 입법되면서, 재판매 또는 위탁판매에 해당되는 포괄적인 적용범위를 규정하고 있음.”

대리점거래에 해당된다면 대리점법의 적용을 받을 수 있음³³⁾

- 이에 실무적 관점에서는 대리점 또는 판매점과의 명확한 구분 필요성이 제기되어 왔음. 왜냐하면, 가맹사업의 고유한 특성을 포착하지 못하는 경우 대리점법 또는 공정거래법상 불공정거래행위 금지조항을 적용하는 경우와의 차이를 반영할 수 없게 되는 측면이 있기 때문임. 다만, 이를 명확히 구분하는 것이 언제나 용이하지는 않은 측면이 있음
- 실무적으로 대리점거래는 유통단계에 있어서 상위에 위치한 공급업자로부터 상품을 계속 공급받아 자기의 명의로 계산으로 매수하여 '재판매'하거나, 상품의 소유권을 공급업자가 가지면서 위탁수수료나 소비자판매가격의 일부를 지급받는 조건으로 '위탁판매'하는 경우를 말함.³⁴⁾ 이와 관련하여 「계속적 재판매거래등에 있어서의 거래상 지위 남용행위 세부유형 지정고시」는 용어 사용에 있어서 '대리점'을 직접 언급하고 있지는 않으나, 대리점거래의 개념적 범위를 '상품의 재판매나 위탁판매에 관한 거래'로 규정하고 있음.³⁵⁾ 또한 대리점법 제2조 제1항은 이러한 거래가 '일정 기간 지속되는 계약을 체결하여 반복적으로 행하여지는' 경우를 규정함으로써 일응 '계속적 거래관계'를 상정하고 있음³⁶⁾

계속적 계약관계에 해당하는 가맹사업(프랜차이즈) 계약관계에서 가맹사업

33) 공정거래위원회, 앞의 정책연구용역보고서 (연구책임자: 이봉의), 24면.

34) 최영홍, “대리점법에 대한 법리적 검토”, 「경제법연구」 제15권 제1호, 한국경제법학회, 2016, 182면.

35) 공정거래위원회 고시 제2017-6호 (시행 2017.6.2.) 「계속적 재판매거래등에 있어서의 거래상 지위 남용행위 세부유형 지정고시」. 동 고시의 적용범위를 규정한 제2조 제1항은 '이 고시는 상품의 재판매·위탁판매 등을 위하여 일정한 기간 동안 약정을 하고 공급업자가 판매업자에게 계속적으로 상품을 매입거래, 위·수탁거래 등의 방법으로 공급하는 거래(이를 “계속적 재판매거래등”이라 한다)에서 공급업자가 판매업자에 대해 거래상 우월한 지위를 가지는 경우에 적용한다.'고 규정하고 있다.

36) 송일두, “대리점법의 문제점 및 개선방안에 관한 연구”, 고려대학교 박사학위논문, 2017, 39면. 계속적 거래관계란 계약에 의한 급부가 일회 이행된 경우 계약이 종료되지 않고 시간상 계속성을 띠는 관계를 말함. 대리점은 공급업자의 상품을 재판매하거나 위탁판매하기 위해 상품의 유통을 위한 업무를 정례적으로 행하게 됨.

법상의 위 계약갱신요구권 행사기간이 경과하였고, 가맹계약에 계약의 갱신 또는 존속기간의 연장에 관하여 별도의 약정이 없거나 그 계약에 따라 약정된 가맹점사업자의 계약갱신요구권 행사기간마저 경과한 경우에는, 당사자가 새로이 계약의 갱신 등에 관하여 합의하여야 한다. 그 경우 가맹본부는 가맹점사업자의 갱신요청을 받아들여 갱신 등에 합의할 것인지 여부를 스스로 판단·결정할 자유를 가진다. 다만 가맹본부의 갱신거절이 당해 가맹계약의 체결 경위·목적이나 내용, 계약관계의 전개 양상, 당사자의 이익 상황 및 가맹계약 일반의 고유한 특성 등에 비추어 신의칙에 반하여 허용되지 아니하는 특별한 사정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 다만, ‘계속적 계약관계’로서 가맹사업 계약관계에 관한 대법원 판결에 의하면,³⁷⁾ 다른 거래행위 유형과 달리 가맹계약을 둘러싼 특별한 사정에 대한 신의칙상 고려를 강조하고 있음. 이는 가맹본부와 가맹점사업자 간 계약의 특수성 즉, ‘가맹계약 일반의 고유한 특성’이 반드시 고려되어야 함을 보여주는 것으로 이해됨. 이는 다른 거래 유형과의 구분에 있어서 핵심적 표지로 역할 할 수 있음
- 또한, 주지한 바와 같이 ‘경영 및 영업활동 등에 대한 지원·교육과 통제’는 대리점거래에 있어서 공급업자(본사)와 대리점주 간의 관계에서 인정될 수 있는 통상적인 수준의 사업활동 지원의 관점으로 볼 수 없는 측면이 있음. 이와 관련하여, 가맹본부의 통제를 ‘가맹점사업자 영업의 주된 부분에 관련된 것이어야 하고, 통제의 정도는 단순한 제의나 암시보다는 강하고, 강압적 요구보다는 약한, 상당한 수준의 지시 및 통제’라고 본 헌법재판소 결정의 취지는 주목할 만함.³⁸⁾ 실제로 대리점 거래관계에서 가맹거래상 위와 같은 수준의 지시와 통제가 이루어진다면 경영간섭이 문제될 소지가 있을 것임

37) 대법원 2020.7.23. 선고 2019다289495 판결.

38) 헌법재판소 2015.9.24. 선고 2015헌마149 결정(전원재판부) - 심의절차종료결정취소.

4. 가맹거래법상 '가맹거래'여부의 판단 기준 명확화: 거래의 특수성 강조

- 거래 개념의 명확화 요구는 가맹거래에 국한된 것은 아니며, 대리점 거래에 있어서도 '대리점거래' 정의 규정의 문제점을 제기하고³⁹⁾ 이를 명확히 하고자 하는 시도가 계속되고 있음
- 실제 거래관계나 유형이 해당 법령에서 정의하는 개념 범위에 예외 없이 포섭되기란 쉽지 않음. 이는 유사한 거래 유형 간 구분이 상대적으로 더 어려울 수 있음을 의미하며, 다양한 거래방식과 유형이 혼재되어 지속되는 경우 또한 빈번한 만큼 거래 개념을 단일한 정의 하에서 규정하는 것은 쉽지 않음
- 그럼에도 불구하고 법 적용 여부를 판단하기 위한 핵심 기준으로서 거래 개념의 정의 규정은 지속적으로 구체화되어야 함. 이러한 맥락에서, 가맹사업법 제2조 제1항 등에 따른 '가맹사업'은 그 규정 자체를 보다 구체화하기 보다는 다른 거래 유형과의 차이점을 심사 지침을 통하여 제시함으로써 실무적 예측가능성과 안정성을 제고할 수 있을 것임
- 동시에 가맹사업이 다른 거래 유형과 명확히 구분되는 가맹거래의 특수성을 드러내는 표지를 부각하기 위해, 가맹본부와 가맹점사업자 간의 '상호의존적 이해관계'와 '상당한 정도의 종속성 내지 의존성' 그리고 이러한 '사업 구조를 유지하기 위한 가맹본부와 가맹점사업자 간의 준수사항', 무엇보다도 '경영 및 영업활동 등에 대한 지원'

39) 공정거래위원회, 앞의 정책연구용역보고서 (연구책임자: 이봉의), 14-16면: “현행 대리점 관련 법령 등의 대리점거래에 관한 정의규정에서 ‘재판매 또는 위탁판매’, ‘일정 기간 지속되는 계약’, ‘반복적으로 행하여지는 거래’ 등을 언급하면서 명확하지 않고 있을 뿐만 아니라, 대리점거래에 포섭될 수 있는 실제적 거래관계나 유형이 매우 다양한 상황에서 그 개념을 단일하게 정의하기 어려운 만큼 법 적용범위의 모호성 내지 규제범위의 확장의 문제가 제기될 수 있음”

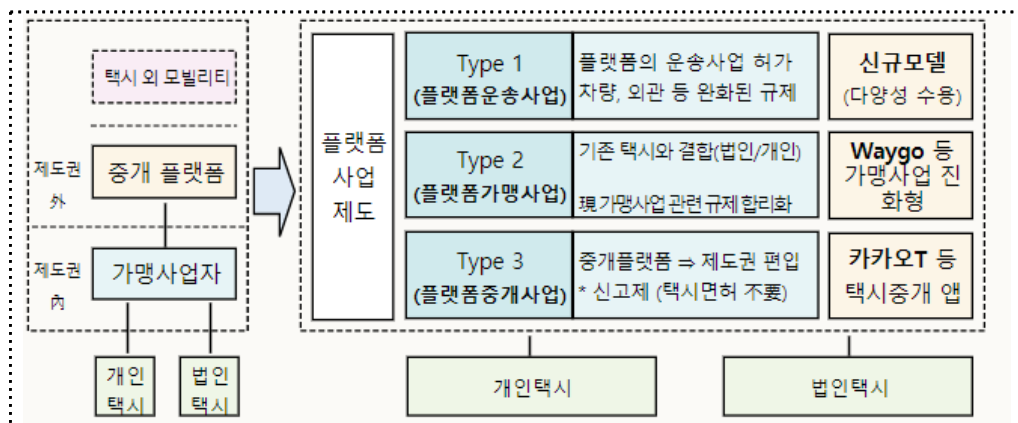
교육과 통제'가 전제된 거래의 본질적·구조적 특성을 지적인 법원의
판시 사항을 심사지침에 제시할 필요가 있음

- 이와 동시에, '신의성실 원칙에 기초한 가맹본부와 가맹점사업자의 상호적 의무사항의 고려 필요성'을 위법성 심사의 일반원칙의 하나로 제시하여, 가맹거래의 구조와 이해관계의 특수성이 가맹거래 당사자의 귀책 여부를 형량함에 있어서 추가적으로 고려될 수 있도록 할 필요가 있음
- 위와 같은 요구는 가맹사업법 제2장에서 '가맹사업거래의 기본원칙'으로서 가맹사업당사자의 '신의성실의 원칙'을 제4조에 규정하고 그에 따른 행위의무로서 '가맹본부와 가맹사업자의 준수사항'을 제5조 및 제6조에 구체화하고 있다는 점을 고려한 것임. 당해 조항에서 보는 바와 같이 가맹사업당사자가 준수해야 할 구체적 내용은 다른 거래유형의 당사자에게 기대되는 행위의무의 수준을 상회하는 것으로 그 자체로 다른 유통(거래)방식과의 차별적 성격을 보여줌⁴⁰⁾
- 결국, 이러한 '가맹사업법상 규정 체계는 거래당사자의 상호적 의무와 책임을 법제화함으로써 그 준수 여부가 가맹사업구조 유지의 핵심임을 밝히는 것'으로, 대리점법이나 대규모유통업법 등 다른 거래유형을 규율하는 법률에 비추어 주목할 만한 특징으로 볼 수 있음

5. 플랫폼 연계 가맹거래의 특성 등 반영 필요성

40) 주지한 바와 같이, 가맹거래당사자의 준수사항은 '상호적 이해와 작용'에 기초한 시행이 의미를 가질 수 있는 만큼 다른 거래 유형에 비하여 거래의 일반원칙으로서 '신의성실의 원칙'이 보다 강조될 수밖에 없는 측면이 있다.

- 디지털 경제로의 급격한 전환으로 새로운 형태의 거래가 이루어지면서, 가맹택시 또는 배달의 민족·요기요 등 플랫폼 연계 가맹거래 등에서 불공정거래행위 관련 문제제기가 증가하고 있음. 이러한 맥락에서 검토해 볼 수 있는 대표적 영역으로 소위 ‘가맹택시’와 ‘배달플랫폼’ 등에 대한 기본적 대응 방향을 제시하고자 함
- 플랫폼 운송사업의 확대에 따른 ‘다양한 운송플랫폼 사업을 제도화’ 과정에서 개정된 여객자동차운송법은 기존의 운송업 체계를 개편해 운송플랫폼 사업을 신설하고 아래 3가지 ‘플랫폼 기반 모빌리티’ 유형으로 구분함⁴¹⁾



- ‘플랫폼 운송사업’ (Type 1, 플랫폼 사업자가 직접 차량을 확보해 유상운송)
- ‘플랫폼 가맹사업’ (Type 2, 플랫폼 사업자가 택시를 가맹점으로 확보해 유상운송)
- ‘플랫폼 중개사업’ (Type 3, 중개 플랫폼(앱 등 응용프로그램)을 통해 운송 중개 서비스 제공)

41) 국토교통부, “모빌리티 혁신의 발걸음이 빨라집니다. - 운송 플랫폼사업 제도화를 위한 여객자동차법 개정안 4월 8일부터 시행”, 2021.4.7. 보도자료, 1-2면; 국토교통부, “택시제도 개편방안”, 2019.7.17., 5면.

- 위의 두 번째 유형과 관련하여 국토교통부는 플랫폼 사업자가 택시를 가맹점으로 확보하여 유상운송을 제공하는 방식으로 Type 2의 경우 일정 요건 충족 시 요금자율신고제로 운영될 예정임을 밝힌 바 있음. 동시에 국토교통부는 이미 카카오T 블루, 마카롱택시, 반반택시그린, 우버택시 등 Type 2 형태의 브랜드 택시 약 3만대가 운행 중이며, 이번 법령 개정을 통해 브랜드 택시가 더욱 활성화 될 것으로 예상함⁴²⁾
- 가맹택시의 경우 플랫폼 사업자의 브랜드와 인프라를 이용하고 그에 따른 가맹 수수료를 지급하는 방식으로 가맹사업의 일반적 구조에 상응함. 이와 관련하여, 기존에는 플랫폼 사업자와 가맹계약을 맺은 택시와 그렇지 않은 택시와의 갈등에 초점이 맞춰졌으나, 최근 플랫폼 사업자와 가맹계약을 맺은 택시 사이에 ‘가맹수수료’ 등에 관한 문제 제기가 이어지고 있음⁴³⁾
- 이와 같은 ‘수수료’ 관련 문제⁴⁴⁾ ‘광고비’와⁴⁵⁾ 함께 배달플랫폼 사업자와 가맹점간에 주된 불만사항으로 제기되어 왔음⁴⁶⁾

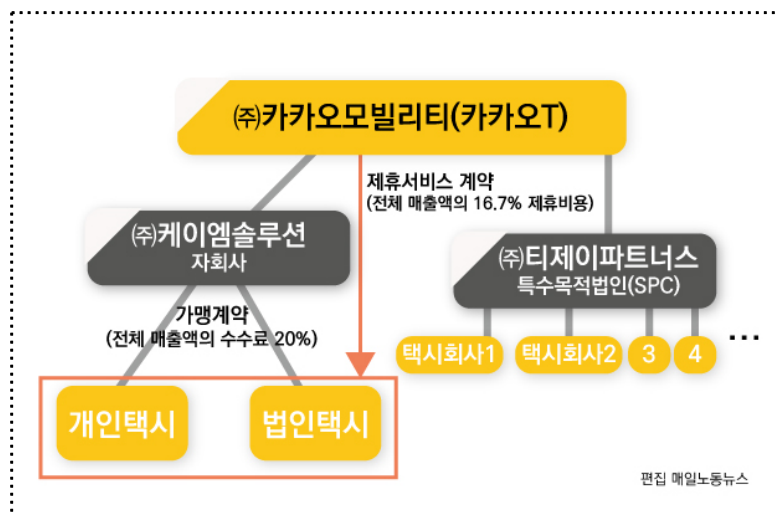
42) 국토교통부, 앞의 보도자료, 3면.

43) 아시아 경제, “이번엔 내분...뿔난 카카오 가맹택시 기사들 '협의회' 결성” 2021.4.1. 기사: “협의회 의 주장은 이렇다. 카카오모빌리티는 가맹 수수료를 가져갈 때 20%를 떼간 뒤 15~16.5%의 금액을 돌려주는 방식을 취하고 있어 계산 과정에서 매출이 뺏기기 되는 문제가 발생하고 있다는 것이다. [...] 이에대해 카카오모빌리티는 "기사들이 가맹계약을 '페이백(Pay-back)' 방식으로 오해해서 발생한 문제"라고 해명했다. 카카오모빌리티에 따르면 카카오T블루 개인택시 기사들은 '가맹계약'과 '제휴계약' 2개의 별개 계약을 체결하게 된다. '가맹계약'은 카카오모빌리티의 자회사인 KM솔루션과 맺고 '제휴계약'은 카카오모빌리티와 맺는다. 가맹계약의 경우 '카카오T블루' 브랜드 이용에 따라 택시들이 KM솔루션에 지불하는 비용이고, 제휴계약은 카카오모빌리티가 택시들이 운행하면서 생기는 '운행데이터' 등을 활용하고 그 데이터 값을 택시들에게 지불하는 것이다.”; 매일노동뉴스, “[가맹택시 택시 노동자에게 독일까 약일까] “카카오T블루 택시노동자 월급, 최저임금도 안 돼”, 2020.10.8.

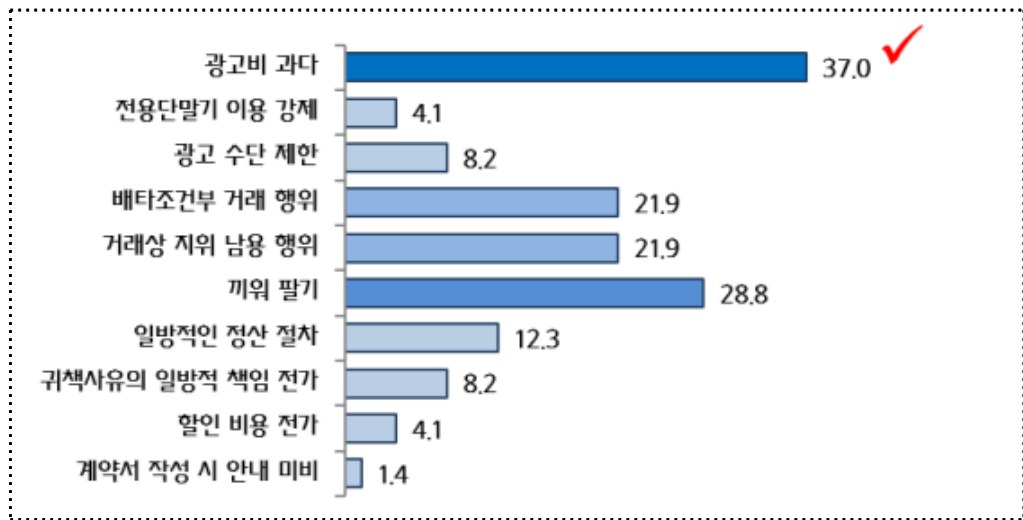
배달앱 수수료 수준 적정도					
구분	업체	종합평가[%]			응답업체수 [개]
		과도함	보통	적절함	
거래 배달앱	배달의 민족	55.1	29.4	15.5	472
	요기요	62.9	26.1	11.0	356
	배달통	61.2	27.9	10.9	147
기업 형태	독립점	65.5	26.8	7.7	142
	프랜차이즈	52.2	30.5	17.3	364
전체*		56.0	29.4	14.6	506

*배달의 민족·요기요·배달통 3개 플랫폼 입점업체 506개사 전체
자료: 중소기업중앙회 '배달앱 가맹점 실태조사(2019)'

- 한편, 중소기업중앙회에서 2019년 실시한 실태조사에 의하면 배달앱 입점 업체들이 경험한 불공정거래행위 유형은 참고할 만함⁴⁷⁾



- 44) 중소기업중앙회, 배달앱 가맹점 실태조사, 2019.5., 4-12면.
 45) 중소기업중앙회, 앞의 실태조사, 13-21면.
 46) 네이버 비즈니스위치, “배민·요기요 배달앱 열풍... 수수료 과도하단 지적도”, 2019.10.29.; 매일경제, “‘단건 배달’ 플랫폼 싸움에 등 터진 사장님들 ‘수수료 떠안아’”, 2021.7.8. 기사; 식품외식경제, “배달앱 가맹점 10곳 중 8곳 ‘배달앱 수수료 과도하게 높다’”, 2020.8.28. 기사 등 참조.
 47) 중소기업중앙회, 앞의 실태조사, 48면.



- 다만, 기존에 전형적인 가맹사업 분야로 이해되던 영역과는 차이를 보일 수 있기 때문에, 기존 법 규범이 적절히 해석·적용될 수 있는지 여부를 우선적으로 판단할 필요가 있음
- 그에 따라 기존 규정을 보완하는 수준에서 플랫폼 연계 가맹거래 유형의 특성과 문제점을 포섭할 수 있을지, 아니면 별도의 심사지침 등을 제정할 것인지에 대한 판단이 요구될 수 있음

제2절 가맹본부의 '거래상 지위'여부 판단과 관련 심·결례

1. '거래상 지위'의 개념적 이해와 판단 기준

불공정거래행위 금지에 있어서 사업자의 거래상 지위 정도와⁴⁸⁾ 거래관계의 범위⁴⁹⁾ 관련 대법원 판례는 가맹본부와 가맹점사업자 간 거래상 지위의 성립요건 도출과 그러한 지위 보유 여부의 판단,⁵⁰⁾ 부당성 판단 기준은 중요한 의미를 가짐. 특히, '계속적 거래관계'에 있어서 거래상 지위 남용에 대한 다양한 판례에 주목할 필요가 있음⁵¹⁾

대법원은 이러한 거래상 지위 남용 금지의 취지를 다음과 같이 밝힌 바 있음.⁵²⁾ 이는 거래상 지위 남용과 관련하여 특정 산업이나 거래유형을 별도로 규제하기 위한 법령을 두는 우리 법제의 입법적 근거를 제공함

[...] 불공정거래행위의 한 유형으로 사업자의 우월적 지위의 남용행위를 규정하고 있는 것은 현실의 거래관계에서 경제력에 차이가 있는 거래주체 간에도 상호 대등한 지위에서 구 독점규제및공정거래에관한법률이 보장하고자 하는 공정한 거래를 할 수 있게 하기 위하여 상대적으로 우월적 지위에 있는 사업자에 대하여 그 지위를 남용하여 상대방에게 거래상 불이익을 주는 행위를 금지시키고자 하는 데 그 취지가 있는 것으로서, [...]

48) 대법원 2000.6.9. 선고 96누19427 판결; 대법원 2002.1.25. 선고 2000두9359 판결; 대법원 2011.5.13. 선고 2009두24108 판결 등. 이항, “공정거래법에서 ‘거래상 지위’의 개념과 판단기준”, 「법제연구」 제51호, 한국법제연구원, 2016, 41-43면.

49) 대법원 2006.11.9. 선고 2003두15225 판결; 대법원 2015.9.10. 선고 2012두18325 판결; 거래상 지위 남용행위의 상대방이 경쟁자 또는 사업자가 아니라 일반 소비자인 경우에는 단순히 거래관계에서 문제 될 수 있는 행태 자체가 아니라, 널리 거래질서에 미칠 수 있는 파급효과라는 측면에서 거래상 지위를 가지는 사업자의 불이익 제공행위 등으로 불특정 다수의 소비자에게 피해를 입힐 우려가 있거나, 유사한 위반행위 유형이 계속적·반복적으로 발생할 수 있는 등 거래질서와의 관련성이 인정되는 경우에 한하여 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 것으로 해석함이 타당하다.

50) 대법원 2000.6.9. 선고 96누19427 판결; 대법원 2002.1.25. 선고 2000두9359 판결; 대법원 2006.11.9. 선고 2003두15225 판결; 대법원 2009.10.29. 선고 2007두20812 판결; 대법원 2011.5.13. 선고 2009두24108 판결; 등.

51) 거래상 지위를 인정한 사례에 관하여, 권오승·서정, 「독점규제법 - 이론과 실무 -」(제4판), 법문사, 2020, 457-458면.

52) 대법원 1998.9.8. 선고 96누2003 판결, 대법원 2000.6.9. 선고 97누19427 판결; 대법원 2002.1.25. 선고 2000두9359 판결 등.

[...] ‘자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위’를 규정하고 있는 것은, 현실의 거래관계에서 경제력에 차이가 있는 거래주체 간에도 상호 대등한 지위에서 법이 보장하고자 하는 공정한 거래를 할 수 있게 하기 위하여 상대적으로 우월한 지위 또는 적어도 상대방의 거래활동에 상당한 영향을 미칠 수 있는 지위에 있는 사업자에 대하여 그 지위를 남용하여 상대방에게 거래상 불이익을 주는 행위를 금지시키고자 하는 데 그 취지가 있는 것으로서, [...]

이러한 맥락에서 가맹사업법 제12조 제1항 제3호는 가맹본부에 의한 거래상 지위 남용행위를 금지하고 있음. 다만, 당해 법령과 동법 제12조 제2항에 따른 [별표2]는 불공정거래행위의 유형과 기준을 제시하고 있을 뿐 가맹사업에 있어서 ‘거래상 지위’의 개념을 별도로 정하고 있지 않음. 이에 가맹거래의 특수성 고려에 앞서 공정거래법 제23조 제1항 제4호 및 관련 심사지침의 내용과 그 해석에 유념할 필요가 있음

가. ‘거래상 지위’의 개념

- 주지한 바와 같이 공정거래법 제23조 제1항 제4호는 ‘자기의 거래상 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위’를 금지하고 있으며, 이에 기초하여 「불공정거래행위 심사지침」(V. 6. (1))은 아래와 같이 규정하고 있음

사업자가 거래상 우월적 지위가 있음을 이용하여 열등한 지위에 있는 거래상대방에 대해 일방적으로 물품 구입강제 등 각종 불이익을 부과하거나 경영에 간섭하는 것은 경제적 약자를 착취하는 행위로서 거래상대방의 자생적 발전기반을 저해하고 공정한 거래기반을 침해하므로 금지된다.

- 불공정거래행위 금지에 있어서 ‘거래상 지위’는 다른 사업자와의

거래관계에서 발생하는 주관적·상대적 지위를 의미하는 것으로⁵³⁾ 시장지배적 지위와 같은 정도의 강한 지위를 의미하는 것은 아니지만, 적어도 상대방의 거래활동에 상당한 영향을 미칠 수 있는 지위로서 그 상대방과의 관계에서 상대적으로 결정됨⁵⁴⁾

- 거래상 지위 남용행위는 일본 사적독점의 금지 및 공정거래의 확보에 관한 법률(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)을 계수한 것으로 보이며,⁵⁵⁾ 거래당사자 간의 사회적·경제적 힘이나 지위의 차이가 존재하는 현실을 반영하여 사적자치의 원칙을 적절히 제한하는 의미를 가짐⁵⁶⁾
- 일본 사적독점금지법 제2조 제9항 제5호의 해석론에 의하면, ‘우월적 지위’는 시장에서 독점적·지배적 지위에 있다는 의미의 ‘절대적 우월성’을 말하는 것은 아니고 ‘개별적 거래의 상대방에 대한 우월적인 지위’에 있다는 의미에서의 ‘상대적 우월성’을 말하는 것임
- 다만, 실제 거래관계에서는 당사자 간에 거래상의 지위에 격차가 존재하는 것이 통상적이므로 당사자 간에 힘의 차이가 있다는 이유만으로는 우월적 지위가 인정되지 않는다고 봄.⁵⁷⁾ 이에 거래상대방에

53) 이황, 앞의 글, 44면.

54) 권오승·서정, 앞의 책, 455면; 공정거래위원회, 「경쟁법론Ⅱ」, 경인문화사, 2010, 339면.

55) 이호영, 「독점규제법」 제5판, 홍문사, 2015, 329면. 현행 공정거래법과 같이 시장지배적 지위에 이르지 못한 거래상 지위의 남용을 불공정거래행위로 금지하는 것은 일본 사적독점금지법의 예에 따른 것으로 볼 수 있음. ‘거래상 지위’의 개념에 관하여는 공정거래위원회, 앞의 정책연구용역보고서 (연구책임자: 이봉의), 26-27면.

56) 이민호, “거래상 지위의 남용행위와 거래질서”, 「경쟁법연구」 제34권, 한국경쟁법학회, 2016.11, 252면. 다만, 거래상 지위 남용행위를 광범위하게 인정하여 사적 거래에 행정청의 개입을 널리 인정하는 경우 사적 자치의 원칙의 훼손 위험 역시 경계해야 함.

57) 이호영, 앞의 책, 329면(谷原修身, 条解独占禁止法, 弘文堂, 1999, p. 212). 또한 우월적 지위 유무의 판단 기준에 대하여 일본 공정거래위원회 및 학자들은 대체로 ‘거래필요성’ 여부를 기준으로 하는 입장을 취하고 있음. 이에 거래상대방이 행위자와 거래를 하지 않으면 안 되는 상황에 있는 경우에 우월적 지위가 있다고 봄(白石忠志, 独禁法講義, 有斐閣, 2005, p. 49).

영향을 미칠 수 있는 '우월한 지위'의 보유 여부에 관한 판단은, 그러한 영향을 미칠 가능성에 관한 종합적 고려를 요함

나. 거래상 지위의 판단 기준과 가맹사업법 관련 공정거래위원회 심결례

- 주지한 바와 같이 가맹거래법은 거래상 지위 여부를 판단하기 위한 기준을 별도로 규정하고 있지 않은 만큼, 공정거래위원회의 「불공정거래행위 심사지침」(예규 제351호, 2020.7.29. 시행) 등에 규정된 판단 기준과 거래상 지위가 인정될 수 있는 예시적 상황을 참고할 필요가 있음

불공정거래행위 심사지침 V. 6. (3) 거래상 지위 여부	(3) 거래상 지위 여부 (가) 거래상지위가 인정되기 위해서는 우선, 계속적인 거래관계가 존재하여야 한다. ① 계속적 거래를 하는 경우에는 통상 특화된 자본설비, 인적자원, 기술 등에 대한 투자가 이루어지게 된다. 이렇게 고착화(lock-in) 현상이 발생하면 상대방은 우월적 지위에 있게 되어 이를 이용하여 불이익한 거래조건을 제시하는 것이 가능해지고 그 상대방은 이미 투입한 투자 등을 고려하여 불이익한 거래조건 등을 수용할 수밖에 없는 상황이 된다. ② 계속적 거래관계 여부는 거래관계 유지를 위해 특화된 자본설비, 인적자원, 기술 등에 대한 투자가 존재하는지 여부를 중점적으로 검토한다. 예를 들어 거래상대방이 거래를 위한 전속적인 설비 등을 가지고 있는 경우에는 거래상지위가 있는 것으로 볼 수 있다. (나) 거래상지위가 인정되기 위해서는 또한, 일방의 타방에 대한 거래의존도가 상당하여야 한다. ① 거래의존도가 상당하지 않은 경우에는 계속적 거래관계라 하더라도 거래처 등을 변경하여 불이익한 거래조건을 회피할 수 있으므로 거래상 지위가 인정되기 어렵다.
--	---

	② 통상 거래의존도는 일방 사업자의 전체 매출액에서 타방 사업자에 대한 매출이 차지하는 비중을 중심으로 검토한다. (다) <u>계속적 거래관계 및 거래의존도를 판단함에 있어 그 구체적인 수준이나 정도는 시장상황, 관련 상품 또는 서비스의 특성 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.</u> (라) 거래상 지위가 인정될 가능성이 있는 거래관계(예시) ▣ 본사와 협력업체 또는 대리점, 대형소매점과 입점업체, 도시가스사와 지역관리소, 제조업체와 부품납품업체, 지역독점적 공공시설 관리업자와 시설임차사업자, 독점적 공공사업자와 계약업체, 방송사와 방송프로그램 공급사업자 등간 거래관계 ▣ 거래상대방인 판매업자가 특정 사업자가 공급하는 유명상품을 갖추는 것이 사업운영에 극히 중요한 경우 특정사업자와 판매업자간 거래관계 ▣ 제조업자 또는 판매업자가 사업활동에 필요한 원재료나 부품을 특정 사업자로부터 공급받아야 하는 경우 특정사업자와 제조 또는 판매업자간 거래관계 ▣ 특정 사업자와의 거래가 장기간 계속되고, 거래관계 유지에 대규모투자가 소요됨으로써 거래상대방이 거래처를 전환할 경우 설비전환이 곤란하게 되는 등 막대한 피해가 우려되는 경우 등
--	--

- 동 심사지침의 거래상 지위 여부의 판단 기준에 비추어 가맹거래 분야에서 문제된 바 있는 ‘할인행사 관련 거래상 지위 남용행위’ 사건 등의 공정거래위원회 판단은 주목할 만 함. 한편, 이와 같은 공정거래위원회의 판단은 화장품 할인행사를 실시하면서, 자신이 부담하기로 한 할인비용의 절반을 가맹점주들에게 추가로 부담하도록 강요한 가맹사업법 위반행위를 제재한 최근 사례와 그 맥락을 같이 함⁵⁸⁾

58) 공정거래위원회, ‘가맹점에 할인행사 비용 떠넘긴 엘지생활건강 엄중 제재’, 2021.9.10. 보도자료 참고.

공정거래위원회 2021.6.22. 의결 제2021-171호 (주)비에이치씨의 가맹사업법 위반행위에 대한 건	가) 거래상 지위 성립 여부 다음과 같은 점을 고려할 때, 피심인은 가맹점사업자에 대하여 거래상 지위가 있는 것으로 판단된다. 첫째, 피심인의 가맹점사업자는 피심인의 영업표지 등을 사용하는 대가로 일정 금액의 가맹금을 피심인에게 지급하고 피심인으로부터 상호, 상표, 포장, 디자인뿐만 아니라 상품의 생산에 대한 노하우 등 <u>영업행위 일체에 대하여 지원을 받고 있는 등 피심인에게 전적으로 의존하는 거래관계</u>에 있다. 둘째, 가맹점사업자가 피심인의 가맹사업에 참여하기 위해서는 피심인이 제시하는 조건과 기준 등에 따라 점포 및 내부 시설 장비 등을 준비하여야 하고, 이와 관련하여 상당한 비용의 투자(개점료, 인테리어 비용, 주방집기 비용)가 이루어져야 하는 바, 가맹점사업자들이 피심인과 거래 단절이 되는 경우에는 가맹점사업자는 <u>투자비용의 회수가 곤란할 뿐만 아니라 대체거래선 확보가 용이하지 아니하여 상당한 경제적 손실</u>을 입게 되기 때문에 가맹점사업자는 피심인의 요구에 응할 수밖에 없다.
공정거래위원회 2000.12.23. 의결 제2000-180호 (주)제너시스의 거래상 지위남용행위 및 거래거절행위에 대한 건	가. 피심인의 우월적 지위 성립 여부 이 사건에서 가맹사업자인 피심인은 다음과 같은 점에서 가맹점에 대하여 거래상 지위가 우월함이 인정된다. 첫째, 가맹점은 피심인의 <u>영업표지 등을 사용한</u> 대가로 일정액의 금액(가맹비 : 5백만원, 계약이행보증금 : 2백만원)을 피심인에게 지급하고 피심인으로부터 상호, 상표, 포장, 디자인뿐만 아니라 제품의 생산에 대한 노하우 등 <u>영업행위 일체에 대하여 지원을 받고 있는 등</u> 가맹점은 피심인에게 <u>의존하는 거래관계</u>에 있다는 점. 둘째, 가맹점은 피심인의 가맹사업에 참여하기 위해서 피심인이 제시하는 조건과 기준에 따라 점포 및 내부시설장비 등을 준비해야 하고 또 <u>상당액의 투자가 선행</u>되어야 하는 바, 만약 피심인이 <u>가맹계약을 해지하는 경우 가맹점은 투자비용을 회수할 수 있는 다른 방법이 없어 가맹점은 상당한 경제적 손실</u>이 입게 되므로 가맹사업자의 요구에 응할 수밖에 없는 사정에 있다는 점.

공정거래위원회 2017.1.26. 의결 제2017-080호 (주)토니모리의 가맹사업법 위반행위에 대한 건	(1) 거래상 지위 성립 여부 다음과 같은 점을 고려할 때 피심인은 가맹점사업자에 대하여 거래상 지위가 있는 것으로 인정된다. 첫째, 피심인은 화장품 브랜드샵 시장에서 최근 몇 년간 매출액이 급성장하고 있는 유력한 사업자로서 피심인 가맹점사업자들은 피심인과 <u>계속적인 거래관계</u>를 유지하기를 희망한다는 점. 둘째, 한 점포에서 <u>특정 브랜드의 제품만을 판매</u>하는 브랜드샵의 특성상 피심인 가맹점사업자들은 피심인의 영업표지가 부착된 제품만을 판매하므로 가맹점 운영과 관련하여 피심인에게 <u>전적으로 의존하는 거래관계</u>에 있다는 점. 셋째, 가맹점사업자들은 가맹사업에 대한 기술, 경험 및 자금 면에서 현격하게 우위에 있는 가맹본부의 지원을 필요로 하는 위치에 있고, 가맹점사업자들은 가맹계약에 따라 가맹본부와 지속적인 거래관계를 유지하면서 가맹본부가 요구하는 조건과 기준에 따라 점포 및 내부시설을 준비하여야 하며 원치 않는 시기에 계약이 해지될 경우 위와 같은 <u>시설투자비용을 충분히 회수하기 어려워져 경제적 손실</u>을 입게 된다는 점. 넷째, 가맹사업의 본질적 특성상 가맹사업의 동일성 유지를 위한 범위 내에서 <u>가맹본부의 가맹점사업자에 대한 일정한 통제</u>가 허용된다는 점.
공정거래위원회 2013.6.26. 의결 제2013-119호 (주)파리크라상의 가맹사업법위반행위 에 대한 건	가) 거래상지위 성립 여부 피심인은 다음과 같은 점을 고려할 때 가맹점사업자에 대하여 거래상지위가 있는 것으로 판단된다. 첫째, 가맹사업의 특성 상 가맹점사업자들은 가맹사업에 대한 기술, 경험 및 자금 면에서 <u>절대적인 약점이 사업적 능력에서 현격하게 우위에 있는 가맹본부의 전적인 지원에 의해 보완</u>되는 위치에 있고, 가맹계약에 따라 가맹본부와 <u>지속적인 거래관계를 유지</u>하면서 가맹본부가 요구하는 조건과 기준에 따라 점포 및 내부시설을 준비하여야 하며, 원치 않는 시기에 계약이 해지될 경우 위와 같은 <u>시설투자비용을 충분히 회수하기 어려워져 경제적 손실</u>을 입는 점에서 통상 가맹본부의 거래상지위가 인정된다. 둘째, 피심인은 국내 프랜차이즈 베이커리 <u>시장에서 1위 사업</u>

	자로서 소비자선호도가 매우 높은 편이므로 <u>가맹점사업자로서는 피심인과의 지속적인 거래관계를 유지하고자</u> 하며 이로서 가맹본부는 가맹점사업자에 대한 거래상 우월한 지위를 가진다고 할 수 있다.
공정거래위원회 2012.11.27. 의결 제2012-262호 현대자동차(주)의 가맹사업법위반행위에 대한 건	가) 거래상지위 성립 여부 피심인은 다음과 같은 점을 고려할 때 가맹점사업자에 대하여 거래상지위가 있는 것으로 판단된다. 첫째, 가맹사업의 특성 상 가맹점사업자들은 가맹사업에 대한 기술, 경험 및 자금 면에서 <u>절대적인 약점을 사업적 능력에서 현격하게 우위에 있는 가맹본부의 전적인 지원에 의해 보완</u>받는 위치에 있고, 가맹계약에 따라 가맹본부와 <u>지속적인 거래관계를 유지</u>하면서 가맹본부가 요구하는 조건과 기준에 따라 점포 및 내부시설을 준비하여야 하며, 원치 않는 시기에 계약이 해지될 경우 위와 같은 <u>시설투자비용을 충분히 회수하기 어려워져 경제적 손실</u>을 입는 점에서 통상 가맹본부의 거래상지위가 인정된다. 둘째, 피심인은 국내 자동차 제조시장에서 시장지배적사업자이고, 자동차정비가맹 <u>시장에서 1위 사업자</u>의 위치에 있으므로 소비자신뢰도 및 선호도가 매우 높은 편이며, 이러한 피심인과 가맹계약을 체결하게 되는 경우, 피심인의 보증수리 업무를 위탁받게 되어 안정적인 수익을 기대할 수 있게 될 뿐만 아니라 자동차정비업의 특성 상 보증수리 고객이 일반수리 등에 대한 고객으로 유인될 가능성이 높은 점 등을 고려할 때, <u>가맹점사업자로서는 피심인과의 지속적인 거래관계를 유지하고자</u> 하며 이로서 가맹본부는 가맹점사업자에 대한 거래상 우월한 지위를 가진다고 할 수 있다.

- 이상의 공정거래위원회 심결례에서 보는 바와 같이, 가맹사업 역시 거래당사자로서 가맹본부와 가맹점사업자 간의 종속성 내지 의존성의 정도가 상당한 계속적 거래관계를 전제하고 있음. 다만 다른 거래 유형에서 통상적으로 고려되는 '사업자의 업무상 지휘감독권'의 관점에서 보면, 이와 유사한 '가맹본부의 지시·통제권'에 상응

하는 '가맹본부의 전적인 지원에 의한 가맹점사업자의 사업적 능력 보완 및 사업활동 지속'이라는 측면이 반드시 고려되어야 할 것임. 이는 위 심결례에서 보는 바와 같이 거래의존도를 보다 강화하는 동시에 대체거래선 확보를 사실상 불가능하게 하는 가맹사업의 특성으로 보아야 하기 때문임

2. 공정거래법 및 가맹사업법 관련 판례 상 거래상 지위의 판단

- 가맹사업법 상 거래상 지위 여부 판단 기준 등에 도출함에 있어서, 그 기본적 표지는 공정거래법 제23조 제1항 제4호의 해석·적용례의 검토는 중요한 의미를 가짐

대법원 1993.7.27. 선고 93누4984 판결	법 제23조 제1항 제4호, 고시 제6조 제4호 소정의 <u>우월적 지위남용</u> 에 의한 불공정거래행위는 ① 사업자간의 거래에 있어, ② 사업자가 자기의 거래상의 지위가 우월함을 이용하여, ③ 정상적인 거래관행에 비추어 부당하게, ④ 상대방에게 불이익이 되도록 거래조건을 설정 또는 변경하거나 그 이행과정에서 불이익을 주는 행위로서, ⑤ 공정한 거래를 저해할 우려가 있어야 할 것인바, [...]
대법원 2000.6.9. 선고 97누19427 결정	법 제23조 제1항 제4호와 제2항 및 그에 근거한 1995.7.8. 자 공정거래위원회 고시 제1995-6호 제6조 제4호에서 불공정거래행위의 한 유형으로 사업자의 <u>우월적 지위의 남용행위</u> 를 규정하고 있는 것은 <u>현실의 거래관계에서 경제력에 차이가 있는 거래주체 간에도 상호 대등한 지위에서 법이 보장하고자 하는 공정한 거래를 할 수 있게 하기 위하여 상대적으로 우월적 지위에 있는 사업자에 대하여 그 지위를 남용하여 상대방에게 거래상 불이익을 주는 행위를 금지시키고자 하는 데 그 취지가 있는 것으로서, 여기서 말하는 우월적 지위에 해당하는지 여부는 당사자가 처하고 있는 시장의 상황, 당사자 간의 전체적 사업능력의 격차, 거래의 대상인 상품의 특성 등을 모두 고려하여 판단하여야 하고, 그러한 우월적 지위를 부당하게 이용하여 상</u>

	<u>대방에게 불이익을 준 행위인지 여부는 당해 행위의 의도와 목적, 효과와 영향 등과 같은 구체적 태양과 상품의 특성, 거래의 상황, 해당 사업자의 시장에서의 우월적 지위의 정도 및 상대방이 받게 되는 불이익의 내용과 정도 등에 비추어 볼 때 정상적인 거래관행을 벗어난 것으로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는지 여부를 판단하여 결정하여야 한다.</u>
대법원 2010.1.14. 선고 2008두14739 판결 ⁵⁹⁾	① 불공정거래행위에 관한 법상의 관련 규정과 입법취지 등에 의하면 불공정거래행위에서의 “거래”란 통상의 매매와 같은 개별적인 계약 자체를 가리키는 것이 아니라 그 보다 넓은 의미로서 사업활동을 위한 수단 일반 또는 거래질서를 뜻하는 것으로 보아야 하는 점, [...]
대법원 2011.5.13. 선고 2009두24108 판결	[...] ‘거래상 지위’는 일방이 상대적으로 우월한 지위 또는 적어도 상대방과의 거래활동에 상당한 영향을 미칠 수 있는 지위를 갖고 있으면 이를 인정하기에 족하다고 할 것이고 (대법원 2002. 1. 25. 선고 2000두9359 판결 참조), 거래상 지위가 있는지 여부는 당사자가 처하고 있는 시장의 상황, 당사자 간의 전체적 사업능력의 격차, 거래의 대상인 상품의 특성 등을 모두 고려하여 판단하여야 할 것이다.

- 가맹사업법 상 거래상 지위 남용이 문제된 사건에서 법원은 ‘거래상 지위 성립 여부’에 대한 공정거래위원회 판단에 근본적 의문을 제기하거나, 「불공정거래행위 심사지침」의 핵심적 표지로서 ‘계속적 거래관계’와 ‘상당한 거래의존도’등에 관하여 재차 세밀하게 판단하지는 않고 있음. 실제로 관련 판례에서 법원은 가맹본부의 거래상 우월적 지위를 전제한 상황에서 금지행위 해당 여부와 위법성 판단에 집중하는 것으로 보임. 한편, 법원의 판단이 가맹사업의 특성이 반영된 표지에 대한 고려를 전제하고 있다는 점은 주목할 만함

59) 거래상 지위남용에서의 ‘거래의 개념’을 밝힌 동 판결(이른바 ‘삼성화재 사건’)에 대하여는 공정거래위원회, “불공정거래행위에 관한 대법원 판결 분석(2010) - 거래상 지위남용 사건을 중심으로 -”, 「경쟁법연구」 제23권, 한국경쟁법학회, 2011.5, 96-105면 참고.

대법원 2005.6.9. 선고 2003두7484 판결	가맹사업에서는 가맹사업의 통일성과 가맹본부의 명성을 유지하기 위하여 합리적으로 필요한 범위 내에서 가맹점사업자가 판매하는 상품 및 용역에 대하여 가맹점사업자로 하여금 가맹본부가 제시하는 품질기준을 준수하도록 요구하고, 그러한 품질기준의 준수를 위하여 필요한 경우 가맹본부가 제공하는 상품 또는 용역을 사용하도록 요구할 수 있다고 봄이 상당하다. [...] [...] 그것이 거래상 지위를 이용하여 가맹점사업자로 하여금 가맹사업의 목적달성을 위하여 필요한 범위를 벗어나서 판매상품(원재료 포함)을 가맹본부로부터 구입하도록 강제하는 행위에 해당한다고 볼 수는 없다.
서울고법 2017.8.17. 선고 2017누38630 판결(확정)	가맹본부가 가맹점사업자에게 거래상의 지위를 이용하여 부당하게 가맹사업자에게 불이익을 주는 행위로서 가맹사업의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위인지 여부는 가맹점계약의 내용, 어드민피 부과의 목적과 내용, 어드민피의 구체적인 분담 내역, 어드민피 부담에 관한 가맹점사업자의 의사반영의 여부, 어드민피 부과로 가맹점사업자에게 생길 수 있는 손해발생의 개연성과 내용, 관련 업계의 거래관행과 거래형태 등 여러 사정을 종합하여 구체적으로 판단하여 결정하여야 한다.
대법원 2018.11.9. 선고 2015두59686 판결	불이익제공행위의 불이익에 해당하기 위해서는, 그 행위의 내용이 상대방에게 다소 불이익하다는 점만으로는 부족하고, 구입 강제, 이익제공 강요, 판매목표 강제 등과 동일시할 수 있을 정도로 일방 당사자가 자기의 거래상 지위를 부당하게 이용하여 그 거래조건을 설정 또는 변경하거나 그 이행과정에서 불이익을 준 것으로 인정되어야 한다. 또한 거래상 지위를 부당하게 이용하여 상대방에게 불이익을 준 행위인지는 당해 행위의 의도와 목적, 효과와 영향 등과 같은 구체적 태양과 상품의 특성, 거래의 상황, 해당 사업자의 시장에서의 우월적 지위의 정도 및 상대방이 받게 되는 불이익의 내용과 정도 등에 비추어 볼 때 정상적인 거래 관행을 벗어난 것으로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는지 여부에 따라 결정되어야 한다(대법원 2006.9.8. 선고 2003두7859 판결, 대법원 2006.3.10. 선고 2002두332 판결 등 참조).

- 위에서 보는 바와 같이 공정거래위원회와 법원은 가맹본부와 가맹점 사업자 간 거래관계의 속성에 비추어 거래상 지위가 인정되는 것으로 판단하여 왔음. 「불공정거래행위 심사지침」 V. 6. (3) 에서 거래상 지위가 인정될 가능성이 있는 거래관계의 예시에 있어도 가맹사업의 특성이 포섭될 수 있음
- 요컨대, 가맹사업의 일반적 속성은 물론 가맹사업법 제5조와 제6조에 따른 가맹본부와 가맹점사업자의 준수사항 등에 비추어 보면 가맹점 사업자는 사업의 개시, 과정, 종료, 즉 가맹사업활동 전반에 있어서 가맹본부에 종속·의존할 수밖에 없는 만큼 거래상대방으로서 가맹점 사업자에 대한 가맹본부의 거래상 지위 인정은 상대적으로 용이할 수 있음

제4장 위법성 판단기준

제1절 가맹사업법상 불공정거래행위의 위법성 요건

1. 위법성 요건에 대한 해석론 일반

- 법위반 여부에 대한 판단은 결국 법률의 문언을 기초로 이루어져야 하고, 가맹사업법상 불공정거래행위 규정을 해석함으로써 위법성 요건이 도출되어야 함
- 일찍이 판례는, “법령의 해석은 어디까지나 법적 안정성을 해치지 않는 범위 내에서 구체적 타당성을 찾는 방향으로 이루어져야 한다. 이를 위해서는 가능한 한 원칙적으로 법령에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하고, 나아가 당해 법령의 입법 취지와 목적, 그 제·개정 연혁, 법질서 전체와의 조화, 다른 법령과의 관계 등을 고려하는 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원함으로써, 위와 같은 타당성 있는 법령 해석의 요청에 부응하여야 한다.”고 판시한 바 있음⁶⁰⁾
- 따라서 가맹사업법상 불공정거래행위를 규율하는 법규범의 문언을 출발점으로 삼아 위법성 요건을 도출하여야 하고, 그 내용을 구체화함에 있어 필요한 경우 기타 체계적·목적론적 해석방법론을 사용하여야 함⁶¹⁾

60) 대법원 2012.7.5. 선고 2011두19239 전원합의체 판결.

61) 같은 견해로 이봉익, “공정거래법상 특수관계인에 대한 이익제공의 ‘부당성’에 관한 해석방법론”, 「선진상사법률연구」 통권 제81호, 2018, 34-37면.

2. 법률 조문별 위법성 요건

가. 법 제12조 : 불공정거래행위

- 가맹사업법 제12조에 따르면, 가맹본부가 행하는 행위 중 제1항 각 호에 해당하는 행위로서 가맹사업의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위를 하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하는 행위가 금지됨
- 그런데 법 제12조 제1항 각호는 다시 거래거절, 구속조건부 거래, 거래상 지위남용, 손해배상 의무부담 등을 규율하면서 당해 행위 중 오직 '부당한' 경우만 금지하는 것으로 정하고 있음
- 이에 의하면 법 제12조의 위법성 요건은 일차적으로 '공정한 거래를 저해할 우려' 즉, '공정거래저해성'으로 정리되고, 이차적으로는 부당성 요건이 도출되므로, 양자 간의 관계 정립이 요구됨

나. 법 제12조의2 : 부당한 점포환경개선 강요 금지 등

- 가맹사업법 제12조의2는 가맹본부가 정당한 사유 없이 점포환경개선을 강요하는 행위를 금지하고 있음
- 따라서 법 제12조의2의 위법성 요건은 '정당한 사유없이'로 정리될 수 있음

- 이에 관하여 가맹사업법 시행령은 ‘정당한 사유’에 대해 점포의 시설, 장비, 인테리어 등의 노후화가 객관적으로 인정되는 경우(영 제13조의2 제1항 제1호), 그리고 위생 또는 안전의 결함이나 이에 준하는 사유로 인하여 가맹사업의 통일성을 유지하기 어렵거나 정상적인 영업에 현저한 지장을 주는 경우(영 동조 동항 제2호)를 규정하고 있음

다. 법 제12조의3 : 부당한 영업시간 구속 금지

- 가맹사업법 제12조의3은 가맹본부가 정상적인 거래관행에 비추어 부당하게 가맹점사업자의 영업시간을 구속하는 행위를 금지함(동조 제1항)
- 따라서 법 제12조의2의 위법성 요건은 ‘부당성’으로 정리될 수 있음
- 앞에서 정리하였듯이 가맹사업법은 부당한 영업시간 구속에 해당하는 경우에 대해 ‘1. 가맹점사업자의 점포가 위치한 상권의 특성 등의 사유로 심야 영업시간대의 매출이 그 영업에 소요되는 비용에 비하여 저조하여 일정한 기간 동안 영업손실이 발생함에 따라 가맹점사업자가 영업시간 단축을 요구함에도 이를 허용하지 아니하는 행위’, ‘2. 가맹점사업자가 질병의 발병과 치료 등 불가피한 사유로 인하여 필요 최소한의 범위에서 영업시간의 단축을 요구함에도 이를 허용하지 아니하는 행위’를 규정하고 있음

라. 법 제12조의4 : 부당한 영업지역 침해금지

- 가맹사업법 제12조의4 제3항에 따르면, 가맹본부가 정당한 사유 없이 가맹계약 기간 중 가맹점사업자의 영업지역 안에서 가맹점사업자와 동일한 업종의 자기 또는 계열회사의 직영점이나 가맹점을 설치하는 행위는 금지됨
- 따라서 법 제12조의4의 위법성 요건은 '정당한 사유없이'로 정리될 수 있음

법규범	금지행위	위법성 요건
제12조	불공정거래행위	공정거래저해성·부당성
제12조의2	부당한 점포환경개선 강요 금지 등	정당한 사유 없이
제12조의3	부당한 영업시간 구속 금지	부당성(정상적인 거래관행)
제12조의4	부당한 영업지역 침해 금지	정당한 사유 없이

3. 쟁점별 정리

- 법 제12조의 위법성 요건은 공정거래저해성 그리고 부당성이 모두 해당할 수 있으므로 양자 간의 관계를 정리해야 하는데, 이에 대해서는 기존 공정거래법상 불공정거래행위의 위법성 판단기준을 참조할 수 있을 것으로 판단됨
- '정당한 사유 없이'와 '부당성'의 차이가 규명되어야 하는데, 이 또한 공정거래법상 확립된 법리를 참조하여 가맹사업법에 도입할 수 있을 것으로 보임

- 부당성 판단의 방법과 판단 요소에 대해서는 가맹사업법의 목적과 규제체계 및 공정거래위원회 심결례와 법원의 판례 등을 종합하여 일반론을 제시하여야 할 것으로 판단됨

제2절 공정거래법상 불공정거래행위의 위법성 판단기준

1. 공정거래법상 불공정거래행위 위법성 판단기준

가. '공정거래저해성'의 의미 - '부당성'과의 관계

- 공정거래법상 불공정거래행위는 법 제23조 제1항 각 호에 열거된 행위로서 '공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위'를 말하며, 이는 불공정거래행위의 주된 위법성 판단의 핵심적 기준으로 의미를 가짐⁶²⁾
- '공정거래저해성'과 불공정거래행위를 구체화하는 제23조 제1항 각 호와 이를 세부적으로 규정하는 시행령 <별표 1의2> '불공정거래행위의 유형 및 기준'의 각 호에 위법성 판단을 위한 기준으로 기술되어 있는 '부당성'과의 관계와 관련하여, 공정거래저해성과 부당성을 별개의 개념으로 이해할 것인지 아니면 동일한 개념으로 볼 것인지에 관한 견해의 대립이 있었음.
- 부당성을 공정거래저해성의 구체적 표현에 불과한 것으로 보아 양자의 개념상 분리를 인정하지 않는 것이 지배적인 견해이고,⁶³⁾ 불공정거래행위 심사지침이나 대법원의 판결에서도 양자를 분리하여 판단하지 않음⁶⁴⁾

불공정거래행위 : Ⅲ. 위법성심사의 일반원칙

62) 이른바 '공정거래저해성'의 규범적 의미는 '경쟁제한성'보다 넓은 범위를 포섭한다는 점은 일반적으로 부인되기 어렵다. 다만, 그 구체적 개념을 정의하는 것은 쉽지 않다.

63) 권오승·서정, 앞의 책, 2016, 413-414면.

64) 공정거래위원회, 앞의 정책연구용역보고서 (연구책임자: 홍명수), 61면; 권오승·서정, 앞의 책, 413-414면.

심사지침 Ⅲ. 1. 가. (1), (2)	1. 위법성 심사기준 가. 공정한 거래를 저해할 우려 (1) 법 제23조 제1항에 열거된 개별행위 유형이 법위반에 해당되는지 여부를 판단하는 기준은 당해 행위가 ‘공정한 거래를 저해할 우려’(이하 “공정거래저해성”이라 함)가 있는지 여부이다. (2) 공정거래저해성의 의미 (가) 상기의 ‘공정거래저해성’과 법 제23조 제1항 각호에 규정된 ‘부당하게’는 그 의미가 동일한 것으로 본다. (나) 공정거래저해성이란 경쟁제한성과 불공정성(unfairness)을 포함하는 개념으로 본다. (다) 경쟁제한성이란 당해 행위로 인해 시장 경쟁의 정도 또는 경쟁사업자(잠재적 경쟁사업자 포함)의 수가 유의미한 수준으로 줄어들거나 줄어들 우려가 있음을 의미한다. (라) 불공정성(unfairness)이란 경쟁수단 또는 거래내용이 정당하지 않음을 의미한다. 경쟁수단의 불공정성은 상품 또는 용역의 가격과 질 이외에 바람직하지 않은 경쟁수단을 사용함으로써 정당한 경쟁을 저해하거나 저해할 우려가 있음을 의미한다. 거래내용의 불공정성이라 함은 거래상대방의 자유로운 의사결정을 저해하거나 불이익을 강요함으로써 공정거래의 기반이 침해되거나 침해될 우려가 있음을 의미한다.
대법원 1998.9.8. 선고 96누9003 판결	<u>[...] 불공정거래행위로서 같은 법의 규제대상이 되기 위하여는 당해 행위가 외형적으로 위 각 규정이 정하는 요건을 갖추는 외에 그것이 같은 법의 목적에 비추어 부당한 것이어야 하고, 이 때 그 부당성의 유무를 판단함에 있어서는 거래당사자의 거래상의 지위 내지 법률관계, 상대방의 선택 가능성·사업규모 등의 시장상황, 그 행위의 목적 및 효과, 관련 법규의 특성 및 내용 등 여러 사정을 고려하여 그 행위가 공정하고 자유로운 경쟁을 저해할 우려가 있는지의 여부에 따라야 한다.</u>⁶⁵⁾

65) 대법원의 1998년 9월 (주)쌍용정유의 불공정거래행위 판결을 인용한 판결로는, 대법원 2000.6.9. 선고

- 대법원 판결에 의하면 불공정거래행위의 부당성을 판단하는 구체적인 판단 기준으로 공정거래저해성을 이해하고, 내용적으로 부당성 판단에서 고려되는 다양한 요소들을 공정거래저해성에 대하여도 동일하게 적용함으로써, ‘공정한 거래를 저해할 우려’를 상당히 포괄적인 의미로 이해하고 있음⁶⁶⁾

나. 공정거래저해성의 내용

- 공정거래저해성의 내용을 구체적으로 규정하고 있는 불공정거래행위 심사지침은 최근 2015년에 그 개정이 이루어지면서 현재의 형태를 갖추게 되었고, 그 주요내용과 기대효과는 아래와 같음

구 분	주요내용 및 기대효과
예규 제241호, 2015.12.31., 일부개정	□ 주요 개정내용: 개정 심사지침은,⁶⁷⁾ i) 경쟁제한성을 위주로 심사하는 불공정거래행위 유형(거래거절, 차별적 취급, 경쟁사업자배제, 구속조건부거래)에 대한 위법성의 판단기준이 되는 경쟁제한성의 의미를 명확히 하고, 경쟁제한성에 대한 세부 판단 기준을 마련 ii) 끼워팔기의 위법성 판단에 있어서 경쟁제한성을 중심으로 판단하도록 기준을 합리화

97누19427 판결, 대법원 2000.10.6. 선고 99다30817,30824 판결, 대법원 2002.1.25. 선고 2000두9359 판결, 대법원 2002.9.27. 선고 2000두3801 판결, 대법원 2002.10.25. 선고 2001두1444 판결, 대법원 2003.12.26. 선고 2001두9646 판결, 대법원 2004.7.9. 선고 2002두11059 판결, 대법원 2006.9.8. 선고 2003두7859 판결, 대법원 2008.2.14. 선고 2004다39238 판결, 대법원 2010.8.26. 선고 2010다28185 판결 등.

66) 권오승·서정, 위의 책, 400-403면; 공정거래위원회, 앞의 정책연구용역보고서 (연구책임자: 홍명수), 64-65면: “동 판결에 대하여 법문의 ‘공정한 거래를 저해할 우려’ 대신에 ‘공정하고 자유로운 경쟁을 저해할 우려’라는 표현을 사용한 것에 규범적 의미를 부여할 수 있는지, 판시 사항에서 부당성 유무의 판단은 공정하고 자유로운 경쟁을 저해할지 여부의 판단에 따르는 것으로 하고 있는데, 이와 같은 판단의 과정이 불공정거래행위 규제의 법체계에 부합하는 것인지에 대한 추가적인 논의의 여지는 있다. 그러나 적어도 동 판결에서 제시하는 부당성 내지 공정거래(경쟁)저해성의 판단 요소가 독점규제법상 불공정거래행위 규제 목적의 범위에 상응한다는 점에서, 긍정적인 평가는 가능할 것이다.”

- 끼워팔기는 주된 상품시장에서 상당한 지위에 있는 사업자가 종된 상품을 끼워팔아 종된 상품 시장의 경쟁이 제한되는 경우를 규제하는 것이 일반적 경쟁법 이론이며 주요 국가의 법 집행 관행임

- 이러한 경쟁법 이론 및 주요 국가의 법 집행 관행을 반영하여 끼워팔기의 위법성 판단 기준을 불공정한 경쟁수단인 경우를 삭제하여 경쟁제한성 위주로 합리화
-> 끼워팔기 규제의 4가지 위법성 요건(① 2개의 별개 제품이 존재 ② 끼워파는 행위의 존재 ③ 주된 상품시장에서의 상당한 지위 ④ 종된 상품시장의 경쟁자 배제)을 반영

iii) 거래상 지위 여부 판단을 위한 기준을 보완: 기존의 ‘거래선 확보 용이성’ 기준을 ‘계속적 거래 여부’ 및 ‘거래 의존도’ 중심으로 판단⁶⁸⁾

‘거래상 지위’ 여부	
기존 심사지침	개정 심사지침
‘거래상대방의 대체 거래선 확보의 용이성’을 고려	① ‘계속적인 거래관계가 존재 하여야’ 하며, ② ‘일방의 타 방에 대한 거래의존도가 상당 하여야’ 할 것을 요건으로 규정
	최근 판례의 입장을 반영하여 거래상 지위 남용행위의 상대방은 원칙적으로 사업자에 한정되는 것으로 규정 ⁶⁹⁾ 다만, 불특정 다수의 소비자에게 피해를 입힐 우려가 있거나(소위 소비자에 대한 거래상 지위 남용행위), 유사한 위반 행위 유형이 계속적·반복적으로 발생하는 등, 거래질서와의 관련성이 인정되는 경우에는 소비자에 대해서도 거래상 지위 남용 행위가 성립할 가능성을 열어 둠 ⁷⁰⁾

	iv) 기술·인력의 부당이용·채용 행위의 위법성 요건을 완화하는 방향으로 개정(당해 위법성 요건을 ‘현저히 사업활동을 곤란하게 하는 경우’에서 ‘상당히 사업 활동을 곤란하게 하는 경우’로 완화). □ 기대효과 - 경쟁제한성 판단 기준이 보다 구체화되고 정립된 경쟁법 이론 및 심결례를 반영하여 위법성 판단 기준이 정비됨에 따라 법 집행의 일관성이 높아질 것으로 기대 - 또한 기술·인력의 부당 이용·채용 행위의 위법성 요건이 완화되면서 중소기업 기술의 유용 및 핵심 인력 유출 행위를 보다 효과적으로 방지할 수 있을 것으로 예상
--	--

- 불공정거래행위 심사지침은 최근 2020년 한 차례 더 개정되었는데, 사업자의 시장점유율 등에 비추어 통상적으로 공정거래저해성이 미미할 것으로 인정되는 경우 불공정거래행위의 외형에 해당되는 행위가 있다고 하더라도 공정거래저해성이 없는 것으로 보아 공정거래위원회가 원칙적으로 심사절차를 개시하지 않는 심사면제 대상인 안전지대를 경제규모의 성장을 고려하여 확대하고자 개정하였고, 경쟁제한성 위주로 위법성을 심사하는 거래거절, 차별적 취급, 경쟁사업자 배제, 구속조건부거래 등 4개 불공정거래행위 유형의 안전지대 범위를 행위사업자의 연간매출액 20억 원 미만에서 50억 원 미만으로 상향하는 것을 주요 내용으로 하였음

67) 공정거래위원회, ‘경쟁제한성 판단 기준 구체화, 거래상지위 판단 기준 보완’, 보도참고자료, 2015.11.6. 참조.

68) 또한 공정거래위원회는 거래상지위 남용행위의 위법성 판단기준 구성 체계를 정비하면서, 개별행위 유형별로 동일한 내용이 반복적으로 기술되어 있는 부분은 거래상지위 남용행위를 개괄하여 설명하는 부분에 모아서 한꺼번에 기술함.

69) 불공정거래행위에 관한 법령 규정은 행위의 상대방을 사업자 또는 경쟁자로 규정하고 있으며 해석상 거래 질서 또는 경쟁 질서와의 관련성을 요구하고 있음(대법원 2015.9.10. 선고 2012두18325 판결).

70) 공정거래위원회, ‘경쟁제한성 판단 기준 구체화, 거래상지위 판단 기준 보완’, 보도참고자료, 2015.11.6., 4면: 소비자에 대한 거래상지위 남용행위는 최근 판례(대법원 2015.9.10. 선고 2012두18325 판결)를 반영하여 거래질서와의 관련성을 중심으로 판단.

- 불공정거래행위 심사지침에 따르면 공정거래저해성은 경쟁제한성과 불공정성을 포함하는 개념으로 이해됨
 - 경쟁제한성은 당해 행위로 인해 시장 경쟁의 정도 또는 경쟁사업자 (잠재적 경쟁사업자 포함)의 수가 유의미한 수준으로 줄어들거나 줄어들 우려가 있음을 의미함
 - 불공정성은 경쟁수단 또는 거래내용이 정당하지 않음을 의미하는데, 경쟁수단의 불공정성은 상품 또는 용역의 가격과 질 이외에 바람직 하지 않은 경쟁수단을 사용함으로써 정당한 경쟁을 저해하거나 저해할 우려가 있음을 의미하고, 거래내용의 불공정성은 거래상 대방의 자유로운 의사결정을 저해하거나 불이익을 강요함으로써 공정거래의 기반이 침해되거나 침해될 우려가 있음을 뜻함
- 불공정거래행위 세부 유형별 공정거래저해성의 의미를 <표>로 정리 하면 다음과 같음⁷¹⁾

불공정거래행위 세부유형	공정거래저해성의 구체적 의미
▶ 거래거절(공동의 거래거절, 기타의 거래거절) ▶ 차별적 취급(가격차별, 거래조건차별, 집단적 차별) ▶ 경쟁사업자 배제(부당염매, 부당고가매입) ▶ 구속조건부 거래(배타조건부 거래, 거래지역 또는 거래상대방 제한)	경쟁제한성
▶ 부당한 고객유인(부당 이익에 의한 고객유인, 위계에 의한 고객유인, 기타의 부당 고객유인) ▶ 거래강제(사원판매, 기타의 거래강제)	경쟁수단의 불공정성

71) 권오승·서정, 앞의 책, 404-405면.

▶ 사업활동 방해(기술의 부당이용, 인력의 부당유인·채용, 거래처 이전방해, 기타의 사업활동 방해)	
▶ 거래상 지위의 남용(구입강제, 이익제공강요, 판매목표강제, 불이익제공, 경영간섭)	거래내용의 불공정성
▶ 거래강제(끼워팔기)	경쟁제한성+불공정성
▶ 차별적 취급(계열회사를 위한 차별) ▶ 부당지원행위	경쟁제한성+경제력집중

다. 공정거래저해성의 판단방법 ①: '부당하게'와 '정당한 이유없이'

- 공정거래법상 공정거래저해성은 그 판단방법에 있어 '부당하게'와 '정당한 이유없이'로 구분되며, 불공정거래행위 심사지침에서 그 관계를 정립함으로써 확립된 법리가 형성됨
- '부당하게'를 요건으로 하는 행위유형은 당해 행위가 발생하더라도 그것만으로 공정거래저해성이 있다고 인정되는 것은 아니며, 원칙적으로 범위반 요소인 경쟁제한성 내지 불공정성과 위법성 조각사유인 효율성 증대 효과나 소비자후생 증대효과 등을 비교 형량하여 전자가 후자보다 큰 경우에 위법한 것으로 판단함
- '부당성' 요건의 경우 위법성 입증책임은 공정거래위원회가 부담하는 것으로 함
- '정당한 이유없이'를 요건으로 하는 행위유형은 당해 행위의 외형이 있는 경우 원칙적으로 공정거래저해성 내지 부당성이 있는 것으로 보고, 정당한 이유가 인정되는 경우에만 위법성이 배척되는 법리가 확립됨

- ‘정당한 이유없이’의 경우 정당한 사유에 대한 입증책임은 범위반
혐의가 있는 사업자가 부담함

불공정거래행위 심사지침 Ⅲ. 1. 가. (3)	(3) ‘부당하게’와 ‘정당한 이유없이’의 구분 (가) 공정거래저해성은 그 판단방법과 관련하여 시행령 제36조 제1항[별표 1]의 각호에서 다시 ‘부당하게’와 ‘정당한 이유없이’로 구체화된다. (나) ‘부당하게’를 요건으로 하는 행위유형은 당해 행위의 외형이 있다고 하여도 그 사실만으로 공정거래저해성이 있다고 인정되는 것은 아니며, 원칙적으로 경쟁제한성·불공정성(unfairness)과 효율성 증대효과, 소비자후생 증대효과 등을 비교 형량하여 경쟁제한성·불공정성의 효과가 보다 큰 경우에 위법한 것으로 본다. ‘부당하게’를 요건으로 하는 행위에 대해서는 공정거래위원회(사무처)가 위법성을 입증할 책임을 부담하는 것으로 본다. (다) ‘정당한 이유없이’를 요건으로 하는 행위(공동의 거래거절, 계열회사를 위한 차별, 계속적 염매)에 대해서는 당해 행위의 외형이 있는 경우에는 원칙적으로 공정거래저해성이 있는 것으로 본다. 피심인은 정당한 이유가 있는지에 대해 입증할 책임이 있는 것으로 본다.(대판2000두833판결 취지)
---	--

라. 공정거래저해성의 판단방법 ②: ‘우려’의 판단

- 공정한 거래를 저해하는 효과가 실제로 구체적인 형태로 나타나는
경우뿐만 아니라 나타날 가능성이 큰 경우를 의미함
- 현재는 그 효과가 없거나 미미하더라도 미래에 발생할 가능성이 큰
경우를 포함함

마. 공정거래저해성의 판단방법 ③ : 종합적 접근방법

- 공정거래위원회와 법원 실무에서는 불공정거래행위의 위법성 판단에 있어 다양한 고려요소를 구체적인 사안에 탄력적으로 참작하여 종합적으로 판단하는 방식(comprehensive approach 또는 totality of circumstances test)을 채택함⁷²⁾
- 이에 따른 판단 구조는 “부당성의 유무를 판단함에 있어서는 ~ 등 여러 사정을 고려하여 그 행위가 공정하고 자유로운 경쟁을 저해할 우려가 있는지 여부에 따라야 한다.” 또는 “부당성을 갖는지 여부는 ~ 등 여러 사정을 종합적으로 고려하여 그로 인하여 공정한 거래가 저해될 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다.”는 모습을 보임⁷³⁾
- 보다 구체적으로는 당해 사업자의 지위, 입법취지, 행위의 동기와 의도, 거래상대방이나 시장에 미치는 영향 즉, 사업자의 특성, 문제된 행위를 둘러싼 전체적인 맥락, 당해 행위가 가져올 다양한 효과 등이 폭넓게 고려됨⁷⁴⁾
- 한편, 원칙적으로 공정거래저해성은 당해 행위의 효과를 기준으로 판단하고, 사업자의 의도나 거래상대방의 주관적 예측은 공정거래 저해성을 입증하기 위한 정황증거로서의 의미를 가짐

2. 소결

72) 이봉의, 앞의 글, 29면; 권오승 등 8인 공저, 「독점규제법」(제7판), 2020, 226면(홍대식 교수 집필부분).

73) 권오승 등 8인 공저, 앞의 책, 226면.

74) 이봉의, 앞의 글, 29면.

가. 가맹사업법과 공정거래법과의 관계

- 가맹사업법은 폭넓은 사후규제 체계를 그대로 유지하였고, 그 부분에 있어 가맹사업법은 기존 공정거래법상 불공정거래행위 금지의 성격을 벗어나지 않고 있는데, 이러한 특징은 대규모유통업법, 대리점법 등의 기타 유통 관련 법령에도 나타나는 것으로서, 내용상 중복 문제를 차치하고서라도 위법성 판단기준 등에 있어서는 연관성을 완전히 부정할 수 없음

나. 공정거래법상 공정거래저해성의 법리 참조

- 법리적 정합성을 유지하고, 판단의 합리성을 확보하는 차원에서 공정거래저해성 판단기준 등의 일반론은 큰 무리가 없는 한 준용하는 것이 가능함
 - 공정거래저해성과 부당성의 관계, '부당하게'와 '정당한 사유없이'의 내용, '우려'의 판단, 종합적 판단방법 등의 방법론은 가맹사업법상 불공정거래행위에 있어서도 유효하다고 판단할 수 있음
 - 한편, 가맹사업법의 경우 '부당하게'와 '정당한 사유없이'의 문언이 정리되어야 할 것으로 판단되는데, 특히 법 제12조의2 및 제12조의4가 문제됨. 즉, 법 제12조의2는 "부당한 점포환경개선 강요행위"를 규율하고 있지만, 제1항 본문에서는 "대통령령으로 정하는 정당한 사유없이 점포환경개선을 강요하여서

는 아니된다”고 하고, 법 제12조의4는 “부당한 영업지역 침해 행위”를 금지하면서 제3항 본문에서는 “정당한 사유없이 (...) 직영점이나 가맹점을 설치하는 행위를 하여서는 아니된다”고 규정하여, ‘부당성’과 ‘정당한 사유없이’를 혼용하고 있음. 이는 앞서 정리한 양자의 법리간 충돌을 야기할 것이므로 입법론적으로 정비될 필요가 있음

- 다만, 공정거래저해성 중 경쟁제한성은 가맹사업법의 입법취지 즉, 가맹본부와 가맹점사업자의 거래에서 발생하는 문제를 해소하겠다는 취지와는 이질적인 것으로 판단되는 바, 내용상으로는 가맹사업법만의 고유한 판단기준을 정립할 필요도 있어 보임

다. 중복되는 금지행위의 유형의 범위반 예시

- 불공정거래행위 심사지침에서 제시하고 있는 범위반이 주로 문제되는 행위는 비록 대리점을 그 대상으로 상정하여 규정하고 있는 경우라 할지라도 행위유형 자체만 보면 가맹사업법상 불공정거래행위에 대해서도 참조할 수 있으므로 아래 <표>에서 정리하도록 함
- 공정거래법과 가맹사업법은 불공정거래행위 금지에 있어 거래거절, 구속조건부 거래, 거래상 지위 남용(구입강제, 부당한 강요, 부당한 계약조항의 설정 또는 변경, 경영간섭)에 있어 그 내용이 중복됨
 - 그러나 이 중 경쟁제한성을 중심으로 위법성을 판단하는 거래거절과 구속조건부 거래는 앞서 정리한 바와 같이 경쟁제한을 판단하지 않는 가맹거래법의 성격과 맞지 않으므로 이를 제외한 거래상 지위

남용의 행위유형만 정리하도록 함

<공정거래법과 가맹사업법의 내용상 중복>

- 불공정거래행위 중 거래상 지위 남용을 중심으로 -

중복행위 유형	불공정거래행위 심사지침 -법위반이 주로 문제되는 행위(예시) -
구입강제	(가) 합리적 이유없이 신제품을 출시하면서 대리점에게 재고품 구입을 강요하는 행위 (나) 합리적 이유없이 계속적 거래관계에 있는 판매업자에게 주문하지도 않은 상품을 임의로 공급하고 반품을 허용하지 않는 행위 (다) 합리적 이유없이 자신과 지속적 거래관계에 있는 사업자에 대해 자기가 지정하는 사업자의 물품용역을 구입할 것을 강요하는 행위 (라) 합리적 이유없이 도·소매업자(또는 대리점)에게 과다한 물량을 할당하고, 이를 거부하거나 소화하지 못하는 경우 할당량을 도·소매업자(또는 대리점)가 구입한 것으로 회계처리하는 행위
부당한 강요 (아예제공강요)	(가) 합리적 이유없이 수요측면에서 지배력을 갖는 사업자가 자신이 구입하는 물량의 일정 비율만큼을 무상으로 제공하도록 요구하는 행위 (나) 합리적 이유 없이 사업자가 상품(원재료 포함) 또는 용역 공급업체에 대해 거래와 무관한 기부금 또는 협찬금이나 기타 금품·향응 등을 요구하는 행위 (다) 합리적 이유없이 회원권 시설운영업자가 회원권의 양도양수와 관련하여 실비보다 과다한 명의 개서료를 징수하는 행위 (라) 합리적 이유없이 대형소매점사업자가 수수료매장의 입점업자에 대해 계약서에 규정되지 아니한 입점비, POS 사용료 등 비용을 부담시키는 행위
부당한 계약조항의 설정 또는 변경 (거래조건의 설정·변경)	(가) 계약서 내용에 관한 해석이 일치하지 않을 경우 '갑'의 일방적인 해석에 따라야 한다는 조건을 설정하고 거래하는 경우 (나) 원가계산상의 착오로 인한 경우 '갑'이 해당 계약금액을 무조건 환수 또는 감액할 수 있다는 조건을 설정하고 거래하는 경우 (다) 계약 유효기간 중에 정상적인 거래관행에 비추어 부당한 거래조건을 추가한 새로운 대리점계약을 일방적으로 체결한 행위 (라) 계약서상에 외부기관으로부터 계약단가가 고가라는 지적이 있을

	경우 거래상대방이 무조건 책임을 지도록 한다는 조건을 설정하고 거래하는 경우 (마) 계약서에 규정되어 있는 수수료율, 지급대가 수준 등을 일방적으로 거래상대방에게 불리하게 변경하는 행위 (바) 계약기간 중에 자기의 점포 장기임차인에게 광고선전비의 부과기준을 일방적으로 상향조정한 행위
경영간섭	(가) 합리적 이유없이 대리점의 거래처 또는 판매내역 등을 조사하거나 제품광고시 자기와 사전합의하도록 요구하는 행위 (나) 금융기관이 채권회수에 아무런 곤란이 없음에도 불구하고 자금을 대출해준 회사의 임원선임 및 기타 경영활동에 대하여 간섭하거나 특정 임원의 선임이나 해임을 대출조건으로 요구하는 행위 (다) 상가를 임대하거나 대리점계약을 체결하면서 당초 계약내용과 달리 취급품목이나 가격, 요금 등에 관하여 지도를 하거나 자신의 허가나 승인을 받도록 하는 행위 (라) 합리적 이유없이 대리점 또는 협력업체의 업무용 차량 증가를 요구하는 행위
판매목표 강제	(가) 자기가 공급하는 상품을 판매하는 사업자 및 대리점에 대하여 판매목표를 설정하고 미달성시 공급을 중단하는 등의 제재를 가하는 행위 (나) 자기가 공급하는 용역을 제공하는 사업자 및 대리점에 대하여 회원이나 가입자의 수를 할당하고 이를 달성하지 못할 경우 대리점 계약의 해지나 수수료지급의 중단 등의 제재를 가하는 행위 (다) 대리점이 판매목표량을 달성하지 못하였을 경우 반품조건부 거래임에도 불구하고 반품하지 못하게 하고 대리점이 제품을 인수한 것으로 회계처리하여 추후 대금지급 시 공제하는 행위 (라) 대리점이 판매목표량을 달성하지 못하였을 경우 본사에서 대리점을 대신하여 강제로 미판매 물량을 덤핑 판매한 후 발생손실을 대리점의 부담으로 하는 행위 (마) 거래상대방과 상품 또는 용역의 거래단가를 사전에 약정하지 않은 상태에서, 거래상대방의 판매량이 목표에 미달되는 경우에는 목표를 달성하는 경우에 비해 낮은 단가를 적용함으로써 불이익을 주는 행위
불이익제공	(가) 설계용역비를 늦게 지급하고 이에 대한 지연이자를 장기간 지급하지 않아 거래상대방이 사실상 수령을 포기한 경우

	(나) 하자보수보증금율을 계약금액의 2%로 약정하였으나, 준공검사 시 일방적으로 20%로 상향조정하여 징구한 행위 (다) 반품조건부로 공급한 상품의 반품을 받아주지 아니하여 거래 상대방이 사실상 반품을 포기한 경우 (라) 사업자가 자기의 귀책사유로 이행지체가 발생한 경우에도 상당기간 지연이자를 지급하지 않아 거래상대방이 사실상 수령을 포기한 경우 (마) 합리적 이유없이 사업자가 물가변동을 인한 공사비인상 요인을 불인정하거나 자신의 책임으로 인해 추가로 발생한 비용을 불지급하는 행위 (바) 자신의 거래상 지위가 있음을 이용하여 거래상대방에 대해 합리적 이유없이 거래거절을 하여 불이익을 주는 행위(거래상 지위남용성 거래거절)
--	--

제3절 대리점법 및 대규모유통업법상 불공정거래행위 위법성 판단기준

1. 대리점법상 불공정거래행위 위법성 판단

가. 대리점법 제6조 내지 제12조

- 동법에 따르면 공급업자는 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 대리점이 구입할 의사가 없는 상품 또는 용역을 구입하도록 강제하는 행위를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 됨(대리점법 제6조 제1항)
- 아울러 공급업자는 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 대리점에게 자기를 위하여 금전·물품·용역, 그 밖의 경제상 이익을 제공하도록 강요하는 행위를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 됨(대리점법 제7조 제1항)
- 또한, 공급업자는 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 자기가 공급하는 상품 또는 용역과 관련하여 대리점에게 거래에 관한 목표를 제시하고 이를 달성하도록 강제하는 행위를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 됨(대리점법 제8조 제1항)
- 공급업자는 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 제6조부터 제8조까지에 해당하는 행위 외의 방법으로 대리점에게 불이익이 되도록 거래조건을 설정 또는 변경하거나 그 이행과정에서 불이익을 주는 행위를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행

하도록 하여서는 아니 됨(대리점법 제9조 제1항)

- 공급업자는 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 대리점의 경영활동을 간섭하는 행위를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 되고(대리점법 제10조 제1항), 대리점이 청약 또는 구입의사를 표시한 제품, 수량 등 주문내역의 정당한 확인요청에 대하여 이를 거부 또는 회피하는 행위를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 됨(대리점법 제11조)
- 공급업자는 동법 제12조 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 대리점에게 그 행위를 한 것을 이유로 거래의 정지 또는 물량의 축소, 그 밖에 불이익을 주는 행위를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 됨(대리점법 제12조)

나. 심사지침 상 대리점거래에서의 부당성 판단기준

- 공정거래위원회는 2020.6.30. 「대리점분야 불공정거래행위 심사지침」을 제정하여 운영하고 있으며, 당해 심사지침에서 정하는 부당성 판단 기준은 다음과 같음
- 부당성의 의미
 - 법 제6조 내지 제11조에 열거된 개별행위 유형이 법 위반에 해당 하는지 여부를 판단하는 기준은 공급업자의 당해 행위가 거래상 지위를 ‘부당하게’ 이용하였는지 여부이고, ‘부당하게’는 부

당성과 동일한 의미로 봄

- 상기의 '부당성' 여부는 관련시장에서의 경쟁제한성이나 경쟁수단의 불공정성보다는 거래내용의 불공정성 여부를 중심으로 판단하고, '거래내용의 불공정성'이라 함은 대리점의 자유로운 의사결정을 저해하거나 불이익을 강요함으로써 공정거래의 기반이 침해되거나 침해될 우려가 있음을 의미함
- '우려'는 거래내용의 공정성을 저해하는 효과가 실제로 구체적인 형태로 나타나는 경우뿐만 아니라 나타날 가능성이 큰 경우를 의미하고, 비록 현재는 그러한 효과가 없거나 미미하더라도 장래에 발생할 가능성이 큰 경우를 포함함

· 부당성 판단

- 부당성, 즉 거래내용의 불공정성은 대리점에 대해 거래상 지위가 인정되는 공급업자의 법 제6조 내지 제11조에 열거된 개별행위 유형에 해당하는 행위가 거래내용의 공정성을 침해하는지 여부, 합리성이 있는 행위인지 여부를 종합적으로 고려하여 판단함
- '부당하게'를 요건으로 하는 행위유형은 당해 행위의 외형이 있다고 하여도 그 사실만으로 부당성이 인정되는 것은 아니며, 원칙적으로 거래내용의 공정성을 침해하는 효과와 합리성의 효과를 비교형량하여 거래내용의 공정성을 침해하는 효과가 보다 큰 경우에 부당성이 있는 것으로 봄

- ‘거래내용의 공정성 여부’는 당해 행위를 한 목적, 당해 행위가 대리점의 자유로운 의사결정에 기초했는지 여부, 대리점의 예측 가능성, 대리점의 사업활동에 미치는 경제상 불이익 또는 사업활동 곤란의 정도, 당해 업종의 통상적인 거래관행, 관련 법령 등을 종합적으로 고려하여 판단함
 - ‘합리성이 있는 행위인지 여부’는 당해 행위로 인한 대리점거래의 효율성 증대효과나 소비자후생 증대효과가 거래내용의 공정성을 침해하는 효과를 현저히 상회하는지 여부, 기타 당해 행위에 합리적인 사유가 있는지 여부를 종합적으로 고려하여 판단한다. 다만, 거래상지위 남용행위의 속성상 제한적으로 해석함을 원칙으로 함
 - 원칙적으로 부당성은 당해 행위의 효과를 기준으로 판단한다. 공급업자의 의도나 목적 및 대리점의 주관적 예측 등은 거래내용의 불공정성을 입증하기 위한 정황증거로서의 의미를 가짐
- 보복조치의 금지에 대한 부당성 판단
- 법 제12조의 보복조치는 후술하는 바와 같이 법 제6조 내지 제11조에 규정된 개별행위 유형과 달리 거래를 전제로 하는 행위유형이 아니므로, 그 부당성 여부는 거래내용의 불공정성 여부에 대한 판단 없이 대리점의 신고 등 행위와 보복조치로서 이루어지는 행위 간 인과관계를 중심으로 판단함

2. 대규모유통업법상 불공정거래행위 위법성 판단

가. 대규모유통업법상 불공정거래행위

- 공정거래위원회는 대규모유통업법 제10조, 제11조, 제14조, 제15조, 제17조에서 규정하고 있는 행위 중 온라인쇼핑 거래의 특성을 고려할 필요가 있는 행위에 대하여 「온라인쇼핑몰업자의 불공정거래 행위 심사지침」(2021.2.1. 제정)을 마련함
- 동법에 따르면 대규모유통업자는 정당한 사유 없이 납품받은 상품의 전부 또는 일부를 반품하여서는 아니 됨(대규모유통업법 제10조 제1항 본문)
- 나아가 대규모유통업자는 판매촉진행사를 실시하기 이전에 대통령령으로 정하는 바에 따라 판매촉진행사에 소요되는 비용(이하 이 조에서 “판매촉진비용”이라 한다)의 부담 등을 납품업자등과 약정하지 아니하고는 이를 납품업자 등에게 부담시키는 행위를 하여서는 아니 됨(동법 제11조 제1항)
- 대규모유통업자는 부당하게 납품업자 등에게 동법 제14조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 정보를 제공하도록 요구하여서는 아니 되고(동법 제14조 제1항), 대규모유통업자는 정당한 사유 없이 납품업자 등에게 자기 또는 제3자를 위하여 금전, 물품, 용역, 그 밖의 경제적 이익을 제공하게 하여서는 아니 됨(동법 제15조 제1항)

나. 심사지침상 위법성 심사기준

· '정당한 사유' 유무 판단

- 법 제10조 제1항의 반품금지에 있어 정당화 사유의 유무는, i) 납품업자와의 사전 합의여부 및 그 내용, 계약상 반품사유의 존재, 계약해지·취소사유의 존재여부 ii) 납품거래의 형태와 특성, iii) 온라인쇼핑몰업자의 반품 의도와 목적, iv) 반품이 납품업자에게 미치는 효과 등을 종합적으로 고려하여 개별·구체적으로 판단함
- 법 제15조 제1항의 경제적 이익 제공 요구 금지에 있어 정당한 사유에 해당하는지 여부는 납품업자와의 사전합의 여부, 납품업자의 예측가능성, 상품판매와 경제적 이익의 관련 정도, 경제적 이익의 내용·성격, 정상적인 거래방식, 납품업자의 사업경영상의 필요성 등을 고려하여 납품업자가 경제적 이익을 부담할 타당한 사유가 있는지 여부를 종합적으로 고려하여 판단함
- 법 제17조 제1항의 불이익 제공행위 금지에 있어 정당한 사유에 해당하는지 여부는 납품업자와의 사전 합의 여부, 납품업자의 예측가능성, 불이익 행위의 사유 및 목적, 불이익 행위의 내용 및 정도, 납품업자의 불이익을 상쇄하는 반대급부의 존부, 정상적인 거래방식 등을 종합적으로 고려하여 판단함
- 정당화 사유에 대한 입증책임은 이를 주장하는 온라인쇼핑몰업자가 부담함

· 부당성 판단

- 법 제14조 제1항의 경영정보의 제공 요구 금지에 있어 부당성은 당사자가 처해있는 시장 및 거래의 상황, 거래의 대상인 상품의 특성, 경영정보 제공을 요구한 의도·경위·목적·효과·영향 및 구체적인 요구의 태양, 경영정보 요구에 응하지 않을 경우 받을 수 있는 불이익의 내용과 정도 등 여러 사정을 고려하여 그 요구 행위가 정상적인 거래관행을 벗어난 것으로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있다고 인정할 수 있는 경우를 의미함

3. 소결

- 가맹사업법의 입법취지와 고유한 특성에 맞는 위법성 판단기준을 정립할 필요가 있으며, 여기에는 대리점법 및 대규모유통업법상 위법성 판단기준이 좋은 참조례가 될 수 있음
- 특히 위법성 판단기준 일반론을 제시함에 있어 대리점법상 불공정 거래행위 심사지침의 형식을 따를 필요가 있어 보임
- 필요한 각 법위반 행위 유형별로 위법성 여부를 판단하는 과정에서 고려할 요소를 구체적으로 제시할 수 있는 경우나 제시할 필요가 있는 경우는 대규모유통업법 온라인쇼핑몰사업자의 불공정거래행위 심사지침의 경우를 참조할 수 있을 것으로 판단됨

제4절 가맹사업법 위반사례 분석

1. 공정거래위원회 심결례, 법원 판례 검토의 의의

- 가맹거래 관련 일련의 공정거래위원회 심결례 및 법원 판례에 대한 검토는 실제의 가맹거래에 있어서 주로 문제될 수 있는 불공정거래 행위 유형과 그 특징을 확인하는데 있어서 유효함

2. 주요 심결례 및 판례 검토

가. 가맹거래 관련 주요 심결례 및 판례 분석

- 이하에서는 지난 10년을 기준으로 공정거래위원회 웹페이지에 공개된 관련 심결례를 중심으로 하여, 해당 사건의 사실관계 내지 문제된 금지행위를 간단히 밝히고, i) 관련 법규정, ii) 공정거래법거래상 지위 여부의 판단, iii) 위법성 판단 기준을 위주로 정리함
- 이하에서 살펴볼 심결례는 다음과 같음
 1. 씨브웨이인터네셔널비브이의 가맹사업법 위반행위에 대한 건
[의결 제2021-182호] - 구속조건부 거래
 2. (주)웰빙을만드는사람들의 가맹사업법 위반행위에 대한 건
[의결(약) 제2021-7호] - 손해배상 의무 부담
 3. (주)팬아시아다인힐의 가맹사업법 위반행위에 대한 건
[의결(약) 제2021-1호] - 거래거절

4. (주)프랜푸드의 가맹사업법 위반행위에 대한 건
[의결(약) 제2020-72호] - **거래상 지위남용**
5. (주)이원의 가맹사업법위반행위에 대한 건
[의결(약) 제2020-40호] - **부당한 영업지역 침해**
6. (주)다판다의 가맹사업법 위반행위에 대한 건
[의결 제2020-182호] - **거래거절**
7. (주)더캠트의 가맹사업법 위반행위에 대한 건
[의결(약) 제2020-26호] - **거래거절/ 거래상 지위남용**
8. (주)올치에프씨의 경고심의요청에 대한 건
[의결 제2019-153호] - **부당한 영업지역 침해/ 거래거절**
9. (주)웰빙을만드는사람들의 가맹사업법 위반행위에 대한 건
[의결(약) 제2018-102호] - **손해배상의무 부담**
10. (주)에땅의 가맹사업법 위반행위에 대한 건
[의결 제2018-346호] - **구속조건부 거래**
11. (주)백만의 가맹사업법 위반행위에 대한 건
[의결(약) 제2018-80호] - **부당한 영업지역 침해**
12. (주)햇시즈너의 경고심의요청에 대한 건
[의결 제2018-235호] - **부당한 영업지역 침해**
13. (주)비에이치씨의 가맹사업법 위반행위에 대한 건
[의결 제2018-234호] - **부당한 점포환경개선 강요/ 거래상 지위남용**
14. (주)제너시스비비큐의 가맹사업법 위반행위에 대한 건
[의결 제2018-126호] - **부당한 점포환경개선 강요**
15. 바르다김선생의 가맹사업법위반행위에 대한 건
[의결 제2018-68호] - **구속조건부 거래/ 거래거절**

16. (주)마세다린의 가맹사업법 위반행위에 대한 건
[의결 제2018-49호] - **구속조건부 거래**
17. (주)쿠우쿠우의 가맹사업법 위반행위에 대한 건
[의결 제2018-51호] - **부당한 영업지역 침해**
18. 엔씨엔터(주)의 가맹사업법 위반행위에 대한 건
[의결 제2018-6호] - **부당한 영업지역 침해**

[사례 1] 씨브웨이인터네셔널비브이의 가맹사업법 위반행위에 대한 건

(의결 제2021-182호) - 구속조건부 거래, 거래거절

① 사실관계 및 문제된 행위

- 가맹사업상 합리적 범위를 넘어선 필수품목 지정 및 특정 발주시스템 구입 강제행위 (구속조건부 거래 중 거래상대방 구속행위)
- 가맹점사업자와의 부당한 계약해지 (거래거절 중 부당 계약해지 행위)

② 관련 법규정

- 법 제12조 제1항 제2호, 령 제13조 제1항 [별표 2] 2. 나.
- 법 제12조 제1항 제1호, 령 제13조 제1항 [별표 2] 1. 다.

③ 위법성 판단 (부당성 판단)

- 거래상대방 구속행위의 부당성
 - 필수 세척제로 지정된 13개 품목은 특정 회사의 제품으로서 가맹사업 제품의 맛과 품질 등과 직접적인 관련이 없는 특정 회사의 위생관련 제품만을 사용하게 하는 것임
 - 위생 관리에 있어서 가맹사업의 통일적 이미지나 맛과 품질의 동일성 유지를 위해 합리적으로 필요한 범위를 넘어선 부당한 통제까지 허용 되는 것은 아님
 - 피심인은 필수 세척제가 아닌 다른 세척제를 사용할 경우 가맹계약 해지의 사유가 별점을 부과하는 등 지나친 통제를 하였고, 특정 회사의 제품만을 필수 세척제로 지정함으로써 가맹점사업자의 자유로운 선택권을 과도하게 제한함
- 부당한 계약해지 행위의 부당성

- 가맹본부가 계약기간 중에,
- 가맹계약 해지 통지절차를 거치지 아니하는 등 부당하게 가맹점사업자와의 계약을 해지하는 행위가 존재
- 다만, 가맹점사업자의 계약위반 등 가맹점사업자의 귀책사유로 가맹사업의 거래관계를 지속하기 어려운 사정이 발생하는 경우에는 위법성이 조각됨

[사례 2] (주)웰빙을만드는사람들의 가맹사업법 위반행위에 대한 건

(의결(약) 제2021-7호) - 계약서상 영업지역 미기재/ 손해배상의무 부담

① 사실관계 및 문제된 행위

- 가맹계약서에 영업지역을 설정하여 기재하지 아니하고 가맹계약을 체결하는 행위
- 가맹계약서에 가맹점사업자가 비밀유지의무 및 경업금지의무를 위반할 경우 손해배상액으로 5천만 원을 부담하도록 규정하는 조항을 포함하여 가맹계약을 체결

② 관련 법규정

- 법 제12조의4 제1항
- 법 제12조 제1항 제5호, 령 제13조 제1항 [별표 2] 4. 다.

③ 위법성 판단 (부당성 판단)

- 계약서상 영업지역 미기재
 - 계약서상 영업지역을 기재하지 아니한 사실만으로 위법성 인정
- 손해배상의무 부담

- 경업금지나 비밀유지 의무 중 어느 쪽을 위반했는지 여부, 위반의 기간, 정도, 범위 및 그로 인한 피해 규모 등을 전혀 감안하지 아니하고 기계적·일률적으로 5천만 원의 위약금을 배상하도록 규정하고 있는데, 이는 가맹점사업자의 귀책사유 정도에 비해 과중한 위약금이 부과될 우려를 발생시킴

[사례 3] (주)팬아시아다인힐의 가맹사업법 위반행위에 대한 건

(의결(약) 제2021-1호) - 거래거절 중 부당한 계약해지행위

① 사실관계 및 문제된 행위

- 가맹점사업자와의 계약기간 중 계약해지 통지 및 폐점

② 관련 법규정

- 법 제12조 제1항 제1호, 령 제13조 제1항 [별표 2] 1. 다.

③ 위법성 판단 (부당성 판단)

- 부당한 계약해지행위
 - 계약해지 관련하여 가맹점사업자에게 귀책사유가 있지 아니함에도 가맹 계약을 해지함으로써 해당 가맹점주의 계속적인 거래기회를 박탈하여 그 사업활동을 곤란하게 한 점,
 - 해당 가맹점의 가맹계약 기간이 특약 매입계약 기간과 연동된다는 사실을 사전에 가맹점사업자에게 고지한 바 없고, 특약매입계약 종료를 계약 해지사유로 정한 바도 없는 점,
 - 가맹점사업자와의 가맹계약 해지 절차를 준수하지 아니한 점

[사례 4] (주)프랜푸드의 가맹사업법 위반행위에 대한 건

(의결(약) 제2020-72호) - 거래상 지위남용 중 부당한 계약조항 설정·변경

① 사실관계 및 문제된 행위

- 가맹본부가 가맹계약을 갱신하는 과정에서 자신의 거래상 지위를 이용하여 종전의 영업지역을 축소하는 내용으로 거래조건을 변경함으로써 가맹점사업자에게 부당하게 불이익을 주는 행위

② 관련 법규정

- 법 제12조 제1항 제3호, 령 제13조 제1항 [별표 2] 3. 다.

③ 위법성 판단 (부당성 판단)

- 부당한 계약조항 설정 또는 변경
 - 가맹본부와 가맹점사업자 사이의 사전 협의 및 동의를 받는 절차가 충분하거나 적절하지 아니함
 - 종전보다 영업지역을 축소하는 조건으로 갱신계약 체결함

[사례 5] (주)이원의 가맹사업법위반행위에 대한 건

(의결(약) 제2020-40호) - 부당한 영업지역 침해 중 계약서상 영업지역 미기재

① 사실관계 및 문제된 행위

- 가맹계약서 상에 거래상대방인 가맹점사업자의 영업지역을 설정하지 아니한 행위

② 관련 법규정

- 법 제12조의4 제1항

③ 위법성 판단 (부당성 판단)

- 계약서상 영업지역 미기재
 - 계약서상 영업지역을 기재하지 아니한 사실만으로 위법성 인정

[사례 6] (주)다판다의 가맹사업법 위반행위에 대한 건

(의결 제2020-182호) - 거래거절 중 부당한 계약갱신 거절 및 계약해지

① 사실관계 및 문제된 행위

- 가맹본부가 가맹사업을 운영하던 중 영업손실로 인한 가맹사업의 중단을 이유로 가맹점사업자에게 가맹사업 중단 및 계약갱신 거절의 통지 발송 (부당한 계약갱신 거절)
- 계약종료 통보, 거래중단, 물품 공급 중단(부당한 계약해지)

② 관련 법규정

- 법 제12조 제1항 제1호, 령 제13조 제1항 [별표 2] 1. 나.
- 법 제12조 제1항 제1호, 령 제13조 제1항 [별표 2] 1. 다.

③ 위법성 판단 (부당성 판단)

- 부당한 계약갱신 거절
 - 갱신거절 절차를 지키지 않아 계약만료 전과 같은 계약조건으로 가맹 계약 갱신이 이루어져 계약이 유효하였음에도 불구하고 가맹본부가

가맹점사업자에게 일방적으로 계약종료를 통보하고 이후 부당하게 상품의 공급을 중단하였음

· 부당한 계약해지

- 계약해지 통지절차를 준수하지 아니하고 가맹계약을 해지하였고, 이와 같은 계약해지는 효력이 없음에도 불구하고 가맹점사업자들에게 일방적으로 계약종료를 통보하고 이후 부당하게 상품의 공급을 중단하였음

[사례 7] (주)더캠트의 가맹사업법 위반행위에 대한 건

(의결(약) 제2020-026호) - 거래거절 중 부당한 가맹계약해지행위/ 거래상 지위남용 중 구입강제

① 사실관계 및 문제된 행위

- 가맹본부가 계약기간 중에 가맹점사업자들과의 계약을 해지하는 행위
- 가맹본부가 자기의 거래상 지위를 부당하게 이용하여 자기와 거래하는 가맹점사업자들에게 구입할 의사가 없는 제품을 일괄출고하는 방식과 같이 구입을 강제하는 행위

② 관련 법규정

- 법 제12조 제1항 제1호, 령 제13조 제1항 [별표 2] 1. 다.
- 법 제12조 제1항 제1호, 령 제13조 제1항 [별표 2] 3. 가.

③ 위법성 판단 (부당성 판단)

- 부당한 가맹계약해지행위
 - 가맹점사업자의 계약해지 의사가 없었다는 점

- 가맹본부가 2개월 이상의 유예기간 설정, 계약해지에 대한 2회 이상 서면통지 등의 가맹계약 해지통지 절차를 전혀 이행하지 아니한 점
- 구입강제
 - 가맹점사업자의 주문 없이 상품을 일방적으로 일괄출고한 점,
 - 가맹점사업자별로 매장크기, 매출규모, 이용고객의 구매성향 등에 따라 상품별로 경영상 필요한 수량이 상이할 것임에도 불구하고, 이에 대한 고려 없이 모든 가맹점에 일정수량을 일괄출고하거나, 단지 매출규모에 따라서만 약간의 차등만을 두어 상품을 출고한 점,
 - 필수구매품목 뿐만 아니라 가맹점사업자가 자율적으로 구매할 수 있는 품목에 대해서도 가맹점사업자의 구입의사와 관계없이 일방적으로 공급한 점

[사례 8] (주)올치에프씨의 경고심의요청에 대한 건

(의결 제2019-153호) - 부당한 영업지역 침해/ 거래거절 중 부당한 계약해지

① 사실관계 및 문제된 행위

- 가맹본부가 계약기간 중에 가맹점사업자의 영업지역 내에 동일한 업종의 가맹점을 설치함으로써 부당하게 영업지역을 침해한 행위
- 가맹점사업자가 허위사실을 유포하여 가맹본부의 명성이나 신용을 뚜렷이 훼손한 사실이 없음에도 허위사실에 의한 명예훼손을 이유로 부당하게 가맹계약을 해지한 행위

② 관련 법규정

- 법 제12조의4 제3항

- 법 제12조 제1항 제1호, 령 제13조 제1항 [별표 2] 1. 다.

③ 위법성 판단 (부당성 판단)

- 부당한 영업지역 침해
 - 가맹본부가 기존 가맹점의 영업지역 내에 동일한 영업표지의 가맹점의 사업자등록까지 완료한 점,
 - 동일한 영업표지의 가맹점의 설치 그 자체로 기존 가맹점사업자의 영업지역을 침해한 것이 명백한 점,
 - 가맹본부 스스로도 영업지역 침해를 인정한다는 취지의 문서를 가맹점 사업자에게 송부한 사실이 있는 점,
 - 영업개시 전에 신규 가맹점의 영업표지를 제거하였다는 사실만으로 법 제12조의4 제3항 적용이 배제된다고 해석되지 아니하는 점
- 부당한 계약해지
 - 가맹점사업자의 인터뷰·협조문 등의 내용이 허위사실이 아닌바 정당한 가맹계약 해지사유가 있었다고 보기 어려운 점,
 - 이로 인해 가맹사업거래를 지속하기 어려운 사정이 발생하였다고 볼 만한 근거도 전혀 없는 점

[사례 9] (주)웰빙을만드는사람들의 가맹사업법 위반행위에 대한 건

(의결(약) 제2018-102호) - 손해배상의무 부담

① 사실관계 및 문제된 행위

- 가맹점사업자와의 가맹계약이 해지된 이후에도 기존 가맹점사업자가 사용하던 주문전화번호의 사용을 중지하지 않는다는 이유로 위약금

18,000,000원을 청구하는 소 제기

② 관련 법규정

- 법 제12조 제1항 제5호, 령 제13조 제1항 [별표 2] 4. 가, 나, 다.

③ 위법성 판단 (부당성 판단)

- 손해배상의무 부담
 - 인정사실에 비추어 보아, 법 제12조 제1항 제5호 위반에 해당함

[사례 10] (주)에땅의 가맹사업법 위반행위에 대한 건

(의결 제2018-346호) - 구속조건부 거래 중 거래상대방 구속

① 사실관계 및 문제된 행위

- 가맹점사업자들과 가맹계약(재계약, 양수도계약 포함)을 체결하면서 가맹 계약서와는 별도로 홍보협의를서를 작성하거나 홍보예치금을 미리 받는 등의 방법으로 가맹점사업자로 하여금 자신으로부터만 홍보전단지를 구매하도록 함

② 관련 법규정

- 법 제12조 제1항 제2호, 령 제13조 제1항 [별표 2] 2. 나.

③ 위법성 판단 (부당성 판단)

- 거래상대방 구속
 - 홍보전단지는 가맹브랜드의 통일적인 맛·품질을 위하여 가맹점이 가맹 본부로부터 필수적으로 구입하여야할 원·부재료 등과는 성격을 달리

하는 것으로 가맹점이 자신의 매장을 홍보하기 위하여 소요비용 전액을 부담하여 실시하는 개별광고 수단임에도 가맹본부 자신을 통해서만 홍보전단지를 구매하도록 함으로써 이를 필수구입품목과 같이 운영하였다는 점,

- 홍보전단지 거래를 하면서 가맹점사업자에게 홍보물제작업체로부터 구입한 홍보전단지 매입단가에 일정한 마진율을 붙여 판매함으로써 정보공개서 및 가맹계약서에 기재하지 아니한 계속 가맹금을 수취하였다는 점,
- 홍보전단지 구입 강요가 동종업계의 거래관행이라고 보기도 어렵다는 점,
- 다수의 가맹점사업자들이 지속적으로 홍보전단지 영업에 관련된 고충을 호소한 사실이 있다는 점

[사례 11] (주)백만의 가맹사업법 위반행위에 대한 건

(의결(약) 제2018-80호) - 부당한 영업지역 침해

① 사실관계 및 문제된 행위

- 가맹희망자와 가맹계약을 체결하면서 가맹점사업자의 영업지역을 설정하고도 이를 가맹계약서에 기재하지 아니하는 행위

② 관련 법규정

- 법 제12조의4 제1항

③ 위법성 판단 (부당성 판단)

- 부당한 영업지역 침해
 - 계약서상 영업지역을 기재하지 아니한 사실만으로 위법성 인정

[사례 12] (주)햇시즈너의 경고심의요청에 대한 건

(의결 제2018-235호) - 부당한 영업지역 침해

① 사실관계 및 문제된 행위

- 가맹본부가 양수한 사업장을 정당한 사유없이 해당 가맹점사업자가 운영 하던 영업지역 내로 이전·설치한 행위

② 관련 법규정

- 법 제12조의4 제3항

③ 위법성 판단 (부당성 판단)

- 부당한 영업지역 침해
 - 가맹본부가 다른 가맹점사업자의 영업지역을 침해한 것이 인정되는 점,
 - 가맹본부가 점포노후화에 따른 위생 문제를 이유로 이전·설치했다는 주장에 대한 객관적 자료를 제출하지 못했을 뿐만 아니라 그 외의 정당한 사유도 확인되지 않는 점,
 - 기존 가맹점사업자가 가맹점을 양도하였다는 사정만으로 영업지역이 침해되는 점포이전까지 용인하였다고 볼만한 근거는 없는 점,
 - 점포이전이 인근 가맹점에게 미치는 영향은 구체적인 점포이전의 내용 및 형태, 입지조건·영업형태의 변동 등 다양한 요소에 의해 결정되는 바 이전·설치가 기존 가맹점사업자에게 유리하였다고 단정할 수도 없는 점

[사례 13] (주)비에이치씨의 가맹사업법 위반행위에 대한 건

(의결 제2018-234호) - 부당한 점포환경개선 강요/ 거래상 지위남용

① 사실관계 및 문제된 행위

- 가맹본부가 가맹점사업자에게 점포환경개선을 실시하도록 권유 또는 요구하였음에도 가맹점사업자가 점포환경개선에 지출한 비용을 법정비율 미만으로 부담하는 것과 같은 행위

② 관련 법규정

- 법 제12조의2 제2항

③ 위법성 판단 (부당성 판단)

- 부당한 점포환경개선 강요
 - 가맹점사업자가 실시한 점포환경개선에 소요된 비용 중 법정비율에 해당하는 금액 미만으로 부담한 사실이 있다는 점, 그리고 가맹점사업자의 귀책사유로 인한 위생·안전 및 이와 유사한 문제가 발생하였다고 볼만한 객관적인 사정이 확인되지 않는 점

[사례 14] (주)제너시스비비큐의 가맹사업법 위반행위에 대한 건

(의결 제2018-126호) - 부당한 점포환경개선 강요

① 사실관계 및 문제된 행위

- 가맹본부가 가맹점사업자에게 점포환경개선을 실시하도록 권유 또는 요구하였음에도 가맹점사업자가 점포환경개선에 지출한 비용을 법정비율 미만으로 부담하는 것과 같은 행위

② 관련 법규정

- 법 제12조의2 제2항

③ 위법성 판단 (부당성 판단)

- 부당한 점포환경개선 강요
 - 가맹점사업자가 실시한 점포환경개선에 소요된 비용 중 법정비율에 해당하는 금액 미만으로 부담한 사실이 있다는 점, 그리고 가맹점사업자의 귀책사유로 인한 위생·안전 및 이와 유사한 문제가 발생하였다고 볼만한 객관적인 사정이 확인되지 않는 점

[사례 15] 바르다김선생의 가맹사업법위반행위에 대한 건

(의결 제2018-68호) - 구속조건부 거래 중 거래상대방 구속

① 사실관계 및 문제된 행위

- 가맹본부가 자신이 아닌 다른 사업자로부터 구입하여도 상표권 보호나 상품 또는 용역의 동일성 유지에 문제가 없음에도 18개 품목을 자신과 거래하도록 강제하여 가맹점사업자의 거래상대방을 부당하게 구속하는 것과 같은 행위

② 관련 법규정

- 법 제12조 제1항 제2호, 령 제13조 제1항 [별표2] 2. 나.

③ 위법성 판단 (부당성 판단)

- 거래상대방 구속

- 가맹본부가 이들 품목을 필수품목으로 지정하여 자신으로부터 구입하지 않았을 경우에 가맹계약을 해지하도록 규정하는 등 거래를 강제한 점,
- 이들 중 15개 품목의 일반공산품은 가맹점사업자들이 충분히 동일한 제품을 구입할 수 있고 3개 주문생산품도 동일·유사한 제품을 구입 또는 자체주문 등의 방법으로 조달할 수 있으며, 이들 품목은 모두 김밥 등 중심상품의 맛·품질과 직접적인 관련이 없고 가맹사업의 통일적 이미지에도 큰 영향을 주지 않는 점,
- 가맹본부가 별도의 품질기준을 제시하고 가맹점사업자가 그 기준에 맞춰 자유롭게 구입하더라도 그 용도나 기능에 지장이 있다고 보기 어려운 점

[사례 16] (주)마세다린의 가맹사업법 위반행위에 대한 건

(의결 제2018-49호) - 구속조건부 거래 중 거래상대방 구속

① 사실관계 및 문제된 행위

- 가맹본부가 자신이 아닌 다른 사업자로부터 구입하여도 상표권 보호나 상품 또는 용역의 동일성 유지에 문제가 없음에도 50개 품목을 자신과 거래하도록 강제하여 가맹점사업자의 거래상대방을 부당하게 구속하는 것과 같은 행위

② 관련 법규정

- 법 제12조 제1항 제2호, 령 제13조 제1항 [별표2] 2. 나.

③ 위법성 판단 (부당성 판단)

- 거래상대방 구속

- 가맹본부가 해당 품목들을 필수품목으로 지정하여 이를 자신으로부터 구입하지 않을 경우에 가맹계약을 해지하도록 규정함으로써 거래를 강제하였고 실제로도 가맹점사업자가 이를 가맹본부로부터만 구입한 점,
- 당해 품목들은 일반 시중에서 충분히 구입가능한 공산품으로서 중심 상품의 맛·품질과 직접적인 관련이 없고 가맹사업의 통일적 이미지에도 큰 영향을 주지 않는 점,
- 가맹본부가 별도의 품질기준을 제시하고 가맹점사업자가 그 기준에 맞춰 자유롭게 구입하더라도 그 용도나 기능에 지장이 있다고 보기 어려운 점

[사례 17] (주)쿠우쿠우의 가맹사업법 위반행위에 대한 건

(의결 제2018-51호) - 부당한 영업지역 침해

① 사실관계 및 문제된 행위

- 가맹본부가 정당한 사유 없이 가맹계약기간 중 가맹점사업자의 영업지역 안에서 가맹점사업자와 동일한 업종의 자기 또는 계열회사의 직영점이나 가맹점을 설치하는 것과 같은 행위

② 관련 법규정

- 법 제12조의4 제1항

③ 위법성 판단 (부당성 판단)

- 부당한 영업지역 침해
 - 가맹본부가 가맹점사업자와 가맹계약으로 정한 영업지역 안에 자신의 가맹사업과 관련된 동일한 업종의 다른 가맹점을 개설하여 운영하게

한 행위 자체만으로 위법성 인정

[사례 18] 엔씨엔터(주)의 가맹사업법 위반행위에 대한 건

(의결(약) 제2018-6호) - 부당한 영업지역 침해

① 사실관계 및 문제된 행위

- 가맹본부가 가맹점사업자와 가맹계약을 체결하면서 영업지역의 범위를 설정하지 아니하거나 불완전하게 설정하는 것과 같은 행위

② 관련 법규정

- 법 제12조의4 제1항

③ 위법성 판단 (부당성 판단)

- 부당한 영업지역 침해
 - 가맹본부가 가맹점사업자와 가맹계약을 체결하면서 영업지역을 설정하지 아니한 행위 및 구체적이고 명확한 영업지역을 설정하지 아니한 행위는 그 자체만으로 위법성 인정

제4장 결론: 가맹분야 불공정거래행위 심사지침(안)

가맹분야 불공정거래행위 심사지침(안)

I. 목적

이 지침은 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」(이하 “가맹사업법”이라 함) 제12조와 그에 따른 동법 시행령 [별표 2] 「불공정거래행위의 유형 또는 기준」 및 법 제12조의2 내지 제12조의5를 보다 구체적이며 명확하게 규정함과 아울러 대표적인 불공정거래행위에 해당될 수 있는 범위반사례를 예시함으로써, 위법성을 심사하는 기준으로 삼는 한편 가맹본부의 범위반행위를 예방함에 그 목적이 있다.

II. 지침의 적용범위

1. 법 제2조 제1호에서 규정한 ‘가맹사업’은 가맹본부가 가맹점사업자로 하여금 자기의 상표·서비스표·상호·간판 그 밖의 영업표지를 사용하여 일정한 품질기준이나 영업방식에 따라 상품(원재료 및 부재료를 포함) 또는 용역을 판매하도록 함과 아울러 이에 따른 경영 및 영업활동 등에 대한 지원·교육과 통제를 하며, 가맹점사업자는 영업표지의 사용과 경영 및 영업활동 등에 대한 지원·교육의 대가로 가맹본부에 가맹금을 지급하는 지속적인 거래관계를 말하며, 그 구체적 의미는 다음과 같다.

가. 가맹본부의 상표·서비스표·상호·간판 그 밖의 영업표지 사용

- 1) ‘상표’란 자기의 상품(지리적 표시가 사용되는 상품의 경우를 제외하고는 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함)과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)을 말한다. 가맹본부는 자신의 상품과 타인의 상품을 구분하기 위하여 상표를 사용할 수 있고, 이를 가맹점사업자도 사용할 수 있도록 허락할 수 있다.
- 2) ‘서비스표’라 함은 서비스업을 영위하는 자가 자기의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말한다.
- 3) ‘상호’란 사업자가 영업활동을 함에 있어서 자기의 영업을 타인의 영업과 식별하

기 위하여 정하고 사용하는 명칭으로서 상인의 명칭을 의미한다. 상법 제46조 제20호에 따른 상인으로서 가맹본부는 그 성명 기타의 명칭으로 상호를 정할 수 있으며, 이를 가맹점사업자도 사용할 수 있도록 허락할 수 있다.

나. 일정한 품질기준이나 영업방식에 따라 상품(원재료 및 부재료 포함) 또는 용역을 판매하도록 함

- 1) 가맹사업에서는 가맹사업의 통일성과 가맹본부의 명성을 유지하기 위하여 합리적으로 필요한 범위 내에서 가맹점사업자가 판매하는 상품 및 용역에 대하여 가맹점사업자로 하여금 가맹본부가 제시하는 품질기준을 준수하도록 요구하고, 그러한 품질기준의 준수를 위하여 필요한 경우 가맹본부가 제공하는 상품 또는 용역을 사용하도록 요구할 수 있다. (대법원 2005.6.9. 선고 2003두7484 판결)
- 2) 가맹본부의 품질기준 설정은 상품이나 용역을 시간, 재료, 성과, 신뢰도, 외형 또는 제품의 특성 등의 측면에 비추어 일정한 표준에 부합하도록 함을 의미한다. 아울러, 영업방식 설정은 영업시간·판매방식·고객응대요령, A/S 기준 등을 일정한 표준에 맞추는 것을 말한다.
- 3) 가맹점 매뉴얼(manual)은 가맹본부가 제품의 통일성과 품질관리 및 명성의 유지를 위하여 가맹계약에 터잡아 가맹점운영규칙의 일환으로 제정하여 운영하는 것이므로, 가맹점사업자가 상품을 제조·판매·보관·포장하는 등의 방법에 관하여는 물론 가맹점계약에 의하여 가맹점사업자에게 부과되어 있는 의무를 구체화하기 위한 내용도 포함될 수 있다. (대법원 2005.6.9. 선고 2003두7484 판결)

다. 경영 및 영업활동 등에 대한 지원·교육과 통제

- 1) 가맹사업의 성공을 위하여 가맹본부는 가맹점사업자에게 기술적인 노하우와 영업표지 등 지식재산권의 실시허락뿐만 아니라, 사업운영에 필요한 경영지원을 지속적으로 해주어야 한다. 가맹사업법 뿐만 아니라 상법 제168조의7에서도 동일한 내용의 의무가 규정되어 있다.
- 2) 가맹사업에 해당하기 위해서는, 가맹사업의 동일성과 가맹본부의 명성을 유지하기 위하여 가맹본부가 가맹점사업자에게 가맹본부의 영업전략과 기업문화에 맞는 일정한 지시 및 통제를 하여야 한다. 이때 가맹본부의 통제는 가맹점사업자 영업의 주된 부분에 관련된 것이어야 하고, 통제의 정도는 단순한 제의나 암시보다는 강하고, 강압적 요구보다는 약한, 상당한 수준의 지시 및 통제를 의미한다.

(헌법재판소 2015.9.24. 2015헌마149 전원재판부 - 심의절차종료결정취소)

- 3) '경영 및 영업활동 등에 대한 지원·교육과 통제'는 대리점 거래를 비롯한 다른 유통(거래)방식과 구별되는 가맹사업의 특수한 표지이다.

라. 가맹금을 지급하는 계속적인 거래관계

- 1) 가맹사업법의 적용 대상이 되는 가맹계약은 각각 독립된 상인인 가맹본부와 가맹점사업자 사이의 가맹점운영과 관련된 계속적 거래관계에 관한 계약으로 볼 수 있고, 가맹점사업자는 기본적으로 가맹본부의 지원 및 경영지도 등에 기초하여 가맹점을 독자적인 책임과 비용으로 경영하여야 한다. (대법원 2018.7.20. 선고 2015두59679 판결)

- 2) 일회성 기술이나 노하우 전수 등에 따른 대가 지급의 관계는 이에 해당하지 않는다.

2. 소규모 가맹본부에 대한 적용 배제를 규정한 법 제3조 제1항에 의하여 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에는 동 지침을 적용하지 아니한다.

가. 가맹점사업자가 가맹금의 최초 지급일부터 6개월까지의 기간 동안 가맹본부에 게 지급한 가맹금의 총액이 100만원을 초과하지 아니하는 경우

나. 가맹본부의 연간매출액이 5천만 원(해당 가맹사업과 같은 품질기준이나 영업방식에 따라 상품이나 용역을 판매하는 직영점을 개설하여 운영하고 있는 경우에는 해당 직영점의 매출액을 포함하여 5천만 원) 미만인 경우. 다만, 가맹본부가 가맹사업을 시작하기 전에 직영점을 개설하여 운영한 기간이 1년 이상인 경우에는 2억 원(직영점의 매출액을 포함하여 2억 원)으로 한다. 한편, 가맹본부와 계약을 맺은 가맹점사업자의 수가 5개 이상인 경우는 제외한다.

다. 가맹본부의 연간매출액의 산정은 바로 전 사업연도의 손익계산서상의 매출액으로 한다. 다만, 가맹본부가 손익계산서를 작성하지 아니하는 경우에는 「부가가치세법」에 따른 바로 전 2개 과세기간의 부가가치세확정신고서 상의 과세표준과 면세수입금액을 합한 금액으로 한다.

라. 가맹본부가 가맹사업을 시작한 후 1년이 지나지 아니한 경우에는 사업을 시작한 때부터 마지막으로 부가가치세확정신고서를 한 때까지의 부가가치세확정신고서(부가가치세확정신고서를 하지 아니한 경우에는 부가가치세예정신고서)상의 과세표

준과 면세수입금액을 합한 금액을 다항 단서의 금액으로 본다.

3. 이 지침은 가맹사업거래에서 발생하는 공통적이고 대표적인 사항을 중심으로 규정하였으므로 지침에 열거되지 아니한 사항에 해당된다고 해서 법 제12조 내지 제12조의5에 위반되지 않는 것은 아니다. 또한, 특정 행위가 이 지침에서 제시한 「법위반에 해당될 수 있는 행위(예시)」에 해당되더라도 위법성을 심사한 결과 부당하지 아니하다고 인정될 경우에는 법 제12조 내지 제12조의5에 위반되지 않을 수 있다.

Ⅲ. 위법성 심사의 일반원칙

1. 법 제12조의 위법성 판단기준

가. 법 제12조(불공정거래행위) 제1항에 열거된 개별행위 유형이 법위반에 해당하는지 여부를 판단하는 기준은 당해 행위가 가맹사업의 ‘공정한 거래를 저해할 우려’(이하 “공정거래저해성”)가 있는지 여부이다.

나. 공정거래저해성의 의미

- 1) 상기의 공정거래저해성 여부는 관련시장에서의 경쟁제한성이나 경쟁수단의 불공정성보다는 거래내용의 불공정성 여부를 중심으로 판단한다. 단, 법 제12조 제1항 제6호의 경우, 경쟁수단의 불공정성 여부를 중심으로 판단할 수 있다.
- 2) 거래내용의 불공정성이라 함은 가맹점사업자의 자유로운 의사결정을 저해하거나 불이익을 강요함으로써 가맹사업상 공정거래의 기반이 침해되거나 침해될 우려가 있음을 의미한다.
- 3) ‘거래내용의 공정성 여부’는 당해 행위를 한 목적, 당해 행위가 가맹점사업자의 자유로운 의사결정에 기초했는지 여부, 가맹점사업자의 예측가능성, 가맹점사업자의 사업활동에 미치는 경제상 불이익 또는 사업활동 곤란의 정도, 당해 업종의 통상적인 거래관행, 관련 법령 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.
- 4) 상기의 ‘우려’는 거래내용의 공정성을 저해하는 효과가 실제로 구체적인 형태로 나타나는 경우뿐만 아니라 나타날 가능성이 큰 경우를 의미한다. 또한, 현재는 그 효과가 없거나 미미하더라도 장래에 발생할 가능성이 큰 경우를 포함한다.

- 5) 원칙적으로 공정거래저해성은 당해 행위의 효과를 기준으로 판단한다. 사업자의 의도나 거래상대방의 주관적 예측은 공정거래저해성을 입증하기 위한 정황증거로서의 의미를 갖는다.

다. '부당하게'와 '정당한 이유 없이'의 구분

- 1) 공정거래저해성은 그 판단방법과 관련하여 법 제12조 제1항 각호, 동법 시행령 [별표 2] 「불공정거래행위의 유형 또는 기준」에서 다시 '부당하게'와 '정당한 이유 없이'로 구체화된다.
- 2) '부당하게'를 요건으로 하는 행위유형은 당해 행위의 외형이 있다고 하여도 그 사실만으로 부당성이 인정되는 것은 아니며, 원칙적으로 거래내용의 공정성을 침해하는 효과와 소비자 후생 증대효과 등을 비교형량하여 거래내용의 공정성을 침해하는 효과가 보다 큰 경우에 부당성이 있는 것으로 본다. '부당하게'를 요건으로 하는 행위에 대해서는 공정거래위원회가 위법성을 입증할 책임을 부담하는 것으로 본다.
- 3) '정당한 이유 없이'를 요건으로 하는 행위에 대해서는 당해 행위의 외형이 있는 경우에는 원칙적으로 위법한 것으로 본다. 피심인은 정당한 이유가 있는지에 대하여 입증할 책임이 있는 것으로 본다.

2. 법 제12조의2 및 제12조의4의 위법성 판단기준

가. 법 제12조의2(부당한 점포환경개선 강요금지 등) 제1항, 제12조의4(부당한 영업지역 침해금지) 제3항에 규정된 행위 유형이 범위반에 해당하는지 여부를 판단하는 기준은 당해 행위가 '정당한 사유 없이' 행하여졌는지 여부이다.

나. '정당한 사유 없이'에 대한 판단은 이 지침의 「Ⅲ. 위법성 심사의 일반원칙 1. 다. 3)」에서 제시되는 '정당한 이유 없이'의 판단방법에 따른다.

다. 원칙적으로 '정당한 사유 없이'는 당해 행위의 효과를 기준으로 판단한다. 사업자의 의도나 거래상대방의 주관적 예측은 '정당한 사유 없이' 요건을 입증하기 위한 정황증거로서의 의미를 갖는다.

3. 법 제12조의3의 위법성 심사기준

가. 법 제12조의3(부당한 영업시간 구속 금지) 제1항에 규정된 행위 유형이 법위반에 해당하는지 여부를 판단하는 기준은 당해 행위가 ‘부당하게’ 행해졌는지 여부이다.

나. ‘부당하게’에 대한 판단은 이 지침의 「Ⅲ. 위법성 심사의 일반원칙 1. 다. 2)」에서 제시되는 ‘부당하게’의 판단방법에 따른다.

다. 원칙적으로 ‘부당하게’는 당해 행위의 효과를 기준으로 판단한다. 사업자의 의도나 거래상대방의 주관적 예측은 ‘부당하게’ 요건을 입증하기 위한 정황증거로서의 의미를 갖는다.

4. 법 제12조의5의 위법성 판단기준

법 제12조의5(보복조치)의 위법성 여부는 가맹점사업자의 신고 등 행위와 보복조치로서 이루어지는 행위 간 인과관계를 중심으로 판단한다.

IV. 개별행위 유형별 위법성 판단기준

이하의 불공정거래행위는 법 제12조 제1항, 시행령 제13조 제1항 관련 [별표 2]에 규정한 행위 유형에 기초한 것이지만, 가맹사업법상 문제되는 불공정거래행위는 그에 한정되지 않으며 법 제12조 제1항 제6호에 따라 부당하게 경쟁가맹본부의 가맹점사업자를 자기와 거래하도록 유인하는 행위 등 가맹사업의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위를 포괄한다.

이에, 동 지침은 시행령 [별표 2]에서 정하는 불공정거래행위 유형 이외에 가맹거래 관련 쟁점으로서 법 제12조의2 내지 제12조의5에 따른 ‘점포환경개선 강요’, ‘영업시간 구속’, ‘영업지역 침해’ 및 ‘보복조치’에 관한 위법성 판단기준을 제시한다.

1. 거래거절

가맹본부는 가맹점사업자에 대하여 상품이나 용역의 공급 또는 영업의 지원 등을 부당하게 중단 또는 거절하거나 그 내용을 현저히 제한하는 행위로서 가맹사업의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위를 하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다. 다만, 가맹점사업자의 계약위반 등 가맹점사업자의 귀책사유로 인해 가맹사업의 거래관계를 지속하기 어려운 사정이 발생하는 경우에는 위법하지 않다고 볼 수 있다.

구체적으로 가맹점사업자의 계약위반 등 가맹점사업자의 귀책사유로 인하여 가맹사업의

거래관계를 지속하기 어려운 중대한 사정이 없음에도 불구하고 가맹점사업자의 계속적인 거래기회를 박탈하여 그 사업활동을 곤란하게 하거나, 가맹점사업자에 대한 부당한 통제 등의 목적달성을 위하여 그 실효성을 확보하기 위한 수단 등으로 부당하게 행하여진 행위를 거래거절이라 할 수 있다. (대법원 2005.6.9. 선고 2003두7484 판결)

가. 영업지원 등의 거절

정당한 이유 없이 거래기간 중에 가맹사업을 영위하는데 필요한 부동산·용역·설비·상품·원재료 또는 부재료의 공급과 이와 관련된 영업지원, 정보공개서 또는 가맹계약서에서 제공하기로 되어 있는 경영 및 영업활동에 관한 지원 등을 중단 또는 거절하거나 그 지원하는 물량 또는 내용을 현저히 제한하는 행위를 말한다. (시행령 별표2)

1) 대상행위

가) 가맹본부가 가맹점사업자에 대하여 거래기간 중에 가맹사업을 영위하는데 필요한 부동산·용역·설비·상품·원재료 또는 부재료의 공급을 중단 또는 거절하는 행위가 거래거절의 대상이 되지만, 부수적으로 제공되는 것이라 할지라도 위의 거래와 밀접한 관련성이 인정된다면 이에 대해서도 거래거절의 대상이 될 수 있다.

다) 가맹본부는 가맹점사업자의 경영 및 영업활동에 대한 지속적인 조언과 지원의무(법 제5조 제5호)를 지므로, 영업지원, 정보공개서 또는 가맹계약서에서 제공하기로 되어 있는 경영 및 영업활동에 관한 지원 등을 중단 또는 거절하는 행위는 거래거절의 대상이 된다.

라) 가맹본부가 가맹점사업자에 대한 공급이나 지원 등을 현저히 제한하여 사실상 거래를 거절하는 행위도 포함한다.

2) 위법성의 판단기준

영업지원 등의 거절의 위법성은 이 지침의 「Ⅲ. 1. 법 제12조의 위법성 판단기준」에서 제시되는 바에 따라 판단한다.

3) 법 제12조 제1항 제3호와의 관계

가맹본부가 가맹점사업자에 대한 거래상 지위를 이용하여 불이익의 일환으로 합리적 이유 없이 ‘거래거절’을 하거나 거래상대방의 사업활동을 곤란하게 할 목적으로

‘거래거절’을 하는 경우에는 부당하게 가맹사업자에게 불이익을 주는 행위로 법 제12조 제1항 제3호에 위반될 수 있다.

4) 법위반에 해당될 수 있는 행위(예시)

- ① 가맹점사업자의 귀책여부가 불분명한 상황이었음에도 이를 계약위반으로 간주하고 가맹사업법 상 절차를 위반하여 효력이 없는 계약 해지 통보 후 상품공급을 중단한 행위(공정위 의결 제2014-008호, 2014.1.8. 2012서제3082)
- ② 가맹본부가 주문된 상품 외의 기타 비용을 납품대금에 포함하여 청구한 경우, 가맹점사업자가 주문 상품에 대한 대금은 납부했음에도 불구하고 기타 비용이 납부되지 않았다는 이유로 상품 주문을 받지 않거나 공급을 중단하는 행위

나. 부당한 계약갱신의 거절

- 1) 가맹본부가 정당한 사유 없이 가맹점의 영업지역에 직영점을 설치할 목적으로 가맹점사업자의 계약갱신 요구를 거절하는 행위를 말한다. 다만, 가맹본부가 가맹점사업자로부터 가맹점을 양수하거나, 가맹점사업자가 계약갱신 요구를 하지 않은 경우로서 가맹본부가 법 제13조 제4항에 따라 가맹계약을 갱신하지 않는다는 사실을 통지함으로써 가맹계약이 종료된 경우는 제외한다.
- 2) 가맹본부가 정당한 사유 없이 특정 가맹점사업자에 대해서만 차별적으로 계약갱신 요구를 거절하는 행위를 말한다. 다만, 가맹본부가 소속 가맹점사업자에게 공통적으로 적용되는 평가기준, 평가시기, 평가방식 등을 포함한 계약갱신 기준(이하 "평가기준 등"이라 한다)을 사전에 통지하고 평가기준 등에 따라 가맹점 평가를 실시한 후 그 결과에 따라 계약갱신 요구를 거절하는 행위는 제외한다.
- 3) 가맹본부의 요구에 따른 점포환경개선 비용 중 가맹점사업자가 부담한 금액, 점포환경개선 후 가맹점 영업 기간, 해당 기간 동안의 가맹점 수익상황 등에 비추어 가맹점사업자가 점포환경개선 비용을 회수할 수 있는 충분한 기간이 경과하지 않았음에도 불구하고 정당한 사유 없이 가맹점사업자의 계약갱신 요구를 거절하는 행위를 말한다.
- 4) 1)부터 3)까지에 준하는 행위로서 가맹본부가 부당하게 가맹점사업자와의 계약갱신을 거절하는 행위를 말한다. (시행령 별표2)

1) 대상행위

가) 가맹본부가 정당한 사유 없이 가맹점의 영업지역에 직영점을 설치할 목적으로 가맹점사업자의 계약갱신 요구를 거절하는 행위가 대상이 된다.

다만, 아래와 같은 경우 계약갱신 거절의 정당한 사유로 인정된다.

- ① 가맹본부가 가맹점사업자로부터 가맹점을 양수한 경우

- ② 가맹점사업자가 계약갱신 요구를 하지 않은 경우로서 가맹본부가 법 제13조 제4항에 따라 가맹계약을 갱신하지 않는다는 사실을 통지함으로써 가맹계약이 종료된 경우

나) 가맹본부가 정당한 사유 없이 특정 가맹점사업자에 대해서만 차별적으로 계약갱신 요구를 거절하는 행위가 대상이 된다.

다만, 아래와 같은 경우 계약갱신 거절의 정당한 사유로 인정된다.

- ① 가맹본부가 소속 가맹점사업자에게 공통적으로 적용되는 평가기준, 평가시기, 평가방식 등을 포함한 계약갱신 기준(이하 “평가기준 등”이라 한다)을 사전에 통지하고 평가기준 등에 따라 가맹점 평가를 실시한 후 그 결과에 따라 계약갱신 요구를 거절한 경우

위와 같은 정당한 사유가 인정되는 경우라 할지라도, 평가기준과 방식, 그 시기를 사전에 가맹점사업자 전체에 공지하지 않아 가맹점사업자가 이에 충분히 대비할 수 없었거나, 당해 평가결과에 따라 개선조치 대상 가맹점으로 정해진 가맹점사업자에게 이의제기 절차 등을 보장하지 않은 상황에서 가맹점사업자의 계약갱신 요구를 거절하는 행위는 부당한 계약갱신 거절에 해당할 수 있다.

다) 가맹본부의 요구에 따른 점포환경개선 비용 중 가맹점사업자가 부담한 금액, 점포환경개선 후 가맹점 영업 기간, 해당 기간 동안의 가맹점 수익상황 등에 비추어 가맹점사업자가 점포환경개선 비용을 회수할 수 있는 충분한 기간이 경과하지 않았음에도 불구하고 정당한 사유 없이 가맹점사업자의 계약갱신 요구를 거절하는 행위가 대상이 된다.

다만, 정당한 사유가 있다면 가맹본부는 충분한 기간이 경과하지 않았음에도 가맹점사업자의 계약갱신 요구를 거절할 수 있다.

라) 가)부터 다)까지에 준하는 행위로서 가맹본부가 부당하게 가맹점사업자와의 계약갱신을 거절하는 행위가 대상이 된다.

2) 위법성의 판단기준

부당한 계약갱신의 거절의 위법성은 이 지침의 「Ⅲ. 1. 법 제12조의 위법성 판단기준」에서 제시되는 바에 따라 판단한다.

다. 부당한 계약해지

부당하게 계약기간 중에 가맹점사업자와의 계약을 해지하는 행위를 말한다.(시행령 별표2)

1) 대상행위

가) 가맹본부가 부당하게 계약기간 중에 가맹점사업자와의 계약을 해지하는 행위가 대상이 된다.

나) 가맹본부가 가맹계약을 해지하려는 경우에는 가맹점사업자에게 2개월 이상의 유예기간을 두고 계약의 위반 사실을 구체적으로 밝히고, 당해 가맹점사업자가 이를 시정하지 아니하면 그 계약을 해지한다는 사실을 서면으로 2회 이상 통지한 후 해지할 수 있다. (법 제14조)

다) 다만, 가맹사업의 거래를 지속하기 어려운 경우로서 영 제15조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 가맹본부는 계약기간 중이라 하더라도 가맹점사업자와의 즉시 계약 해지가 가능하다.

2) 위법성의 판단기준

부당한 계약해지의 위법성은 이 지침의 「Ⅲ. 1. 법 제12조의 위법성 판단기준」에서 제시되는 바에 따라 판단한다.

3) 범위반에 해당될 수 있는 행위(예시)

- ① 가맹사업의 거래를 지속하기 어려운 경우가 아님에도 불구하고, 가맹본부가 계약기간 중 가맹계약 해지 절차를 거치지 아니하고 가맹점사업자와의 계약을 해지하는 행위 (공정위 의결 제2021-182호, 2021.6.29. 2018서경3442)
- ② 해당 가맹점의 가맹계약 기간이 특약매입계약 기간과 연동된다는 사실을 가맹본부가 가맹점사업자에게 사전에 고지하지 않았음은 물론 특약매입계약 종료를 계약 해지사유로 정하지 않았음에도, 가맹점사업자와의 가맹계약 해지 절차를 준수하지 않으면서 계약을 해지한 행위 (공정위 의결(약) 제2021-1호, 2021.1.18. 2019구사2772)
- ③ 가맹점사업자가 허위사실을 유포하여 가맹본부의 명성이나 신용을 뚜렷하게 훼손한 사실이 없음에도 허위사실에 의한 명예훼손을 이유로 부당하게 가맹계약을 해지한 행위 (공정위 의결 제2019-153호, 2019.7.12. 2018서경2872)

- ④ 가맹점사업자가 가맹계약과 관련하여 진실에 기초한 사실에 대해 단순한 평가적 가치판단의 진술로서 인터넷 게시판에 공개한 것을 가맹본부가 즉시 계약해지 사유에 해당한다고 판단하여 가맹점사업자와의 계약을 해지하는 행위 (공정위 의결(약) 제2016-079호, 2016.8.1. 2015서제0089)
- ⑤ 가맹점 설정계약서에 명시된 계약해지 사유가 아님에도 불구하고 가맹본부가 가맹점사업자에게 요구한 광고비 납부에 응하지 않는다는 이유로 계약을 해지하는 행위 (공정위 의결(약) 제2006-178호, 2006.5.8. 2005전사2409)

2. 구속조건부 거래

가맹점사업자가 가맹본부에 의하여 설계된 사업구조에 가입함으로써 사업활동에 필요한 물품 등의 공급이나 지원을 받는 동시에 각종 의무를 부담하게 되면서 사업활동에 일정한 제한을 받게 되는 가맹사업거래의 특성과 본질에 비추어 보면, 가맹점사업자에 대한 가맹본부의 구속조건부 거래는 다른 불공정거래행위에 비하여 상대적으로 용이할 수 있으며, 경우에 따라서는 불가피한 측면이 있을 수 있다.

그럼에도 불구하고, 사업자가 거래상대방에 대해 가격이나 거래상대방 등을 구속 내지 제한하는 경우 거래의 불공정성이 일반적으로 문제될 수 있으며, 가맹사업의 경우 가맹점사업자가 취급하는 상품 또는 용역의 가격, 거래상대방, 거래지역이나 가맹점사업자의 사업활동을 부당하게 구속하거나 제한하는 경우 가맹사업의 공정한 거래를 저해할 우려가 있을 수 있으므로 금지된다.

가. 가격의 구속

정당한 이유 없이 가맹점사업자가 판매하는 상품 또는 용역의 가격을 정하여 그 가격을 유지하도록 하거나 가맹점사업자가 상품 또는 용역의 가격을 결정하는 행위를 부당하게 구속하는 행위. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 행위는 제외한다. (시행령 별표2)

- (1) 판매가격을 정하여 가맹점사업자에게 이를 따르도록 권장하는 행위
- (2) 가맹점사업자에게 판매가격을 결정하거나 변경하는 경우 그 내용에 관하여 사전에 협의하도록 하는 행위. 다만, 사전협의를 통해 판매가격을 강요하는 행위는 가격을 구속하는 행위로 본다.

1) 대상행위

가) 가맹점사업자가 판매하는 상품 또는 용역의 가격을 정하여 그 가격을 유지하도록 하거나 가맹점사업자가 상품 또는 용역의 가격을 결정하는 행위를 구속하는 행위가 대상이 된다.

나) 가맹점사업자의 가격유지 또는 가격결정 행위 구속에는 당해 내용이 계약서에 명시된 경우뿐만 아니라 계약서에 명시되지 않더라도 이를 따르지 않을 경우에는 가맹계약 해지 또는 갱신거절 등의 불이익이 수반됨으로써 사실상 구속성이 인정되는 경우가 포함된다.

다) 가맹본부에 의한 다음 두 가지 행위의 경우, 가맹사업의 통일성 유지에 기여하는 효과가 있으므로 금지대상에서 제외된다.

- ① 판매가격을 정하여 가맹점사업자에게 이를 따르도록 권장하는 행위
- ② 가맹점사업자가 판매가격을 결정 또는 변경하는 경우 그 내용에 관하여 사전 협의하도록 하는 행위

라) 다만, 권장판매가격을 준수하지 아니함을 이유로 불이익 등 제재조치를 취하거나 권장판매가격을 준수하도록 하는 규약이나 의무가 부과된 경우(대법원 2001.12.24. 선고 99두11141 판결), 그리고 사전협의를 통해 판매가격을 강요하는 행위는 가격을 구속하는 행위로 본다.

2) 위법성의 판단기준

가맹본부의 가격 구속 행위의 위법성은 이 지침의 「Ⅲ. 1. 법 제12조의 위법성 판단기준」에서 제시되는 바에 따라 판단한다.

3) 범위반에 해당할 수 있는 행위(예시)

- ① 가맹사업의 특성상 허용되는 가맹본부의 가맹점사업자에 대한 제품 판매가격과 관련된 지원, 교육 및 통제의 한도를 넘어 가맹점사업자에게 자신이 정한 제품 판매 가격 준수를 강요하고 이를 거부하거나 할인판매 한 가맹점사업자에 대하여 가맹계약을 해지한 행위 (공정위 2004.2.11. 의결 제2004-40호) 등

나. 거래상대방의 구속

부동산·용역·설비·상품·원재료 또는 부재료의 구입·판매 또는 임대차 등과 관련하여 부당하게 가맹점사업자에게 특정한 거래상대방(가맹본부를 포함)과 거래할 것을 강제하는 행위. 다만, 다음의 요건을 모두 충족하는 경우에는 그러하지 아니하다. (시행령 별표2)

- (1) 부동산·용역·설비·상품·원재료 또는 부재료가 가맹사업을 경영하는 데에 필수적이라고 객관적으로 인정될 것
- (2) 특정한 거래상대방과 거래하지 아니하는 경우에는 가맹본부의 상표권을 보호하고 상품 또는 용역의 동일성을 유지하기 어렵다는 사실이 객관적으로 인정될 것
- (3) 가맹본부가 미리 정보공개서를 통하여 가맹점사업자에게 해당 사실을 알리고 가맹점사업자와 계약을 체결할 것

1) 대상행위

가) 부동산·용역·설비·상품·원재료 또는 부재료의 구입·판매 또는 임대차 등과 관련하여 가맹점사업자에게 특정한 거래상대방(가맹본부 포함)과 거래할 것을 강제하는 행위가 대상이 된다.

나) 거래의 대상은 가맹점사업자가 사업을 영위하는데 필요한 상품이나 원재료·부재료뿐만 아니라 인테리어 시공 및 설비·기기·용품 등이 포함된다.

다) 가맹본부가 가맹점사업자로 하여금 가맹본부를 포함한 특정한 거래상대방과 거래하도록 강제하는 행위여야 하며, 그에 관한 구체적 판단은 아래와 같다.

- ① 특정한 거래상대방과 거래하도록 강제하는 행위는 상대방의 자유로운 의사결정을 구속하는 행위로서 당해 요구에 응하지 않으면 불이익을 가하겠다는 의사를 밝히거나 불이익을 실제 가한 경우를 말하는 것으로, 가맹점사업자가 이러한 강제 행위를 이행하였는지 여부는 강제성 인정에 영향을 미치지 않는다.
- ② 특정한 거래상대방과 거래하도록 강제하는 행위에는 상대방이 구입하지 아니할 수 없는 객관적인 상황을 만들어내는 것도 포함된다. (대법원 2018.11.9. 선고 2015두59686 판결)
- ③ 가맹점사업자가 가맹계약 체결 전에 특정한 거래상대방과 거래하여야 하는 사정을 정보공개서를 통해 알리거나, 그에 대하여 사전에 의사 합치가 있는 상태에서 가맹계약을 체결하였다는 사정이 있다고 하더라도, 그와 같은 사정이 특정 거래상대방과의 거래를 강제하지 않았다는 것을 단정해주지는 않는다. (대법원 2018.11.9. 선고 2015두59686 판결)

2) 위법성 판단기준

가) 거래상대방 구속행위의 위법성은 이 지침의 「Ⅲ. 1. 법 제12조의 위법성 판단 기준」에서 제시되는 바에 따라 판단한다.

나) 다만, 다음의 요건을 모두 충족하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- ① 부동산·용역·설비·상품·원재료 또는 부재료가 가맹사업을 경영하는 데에 필수적이라고 객관적으로 인정될 것
- ② 특정한 거래상대방과 거래하지 아니하는 경우에는 가맹본부 상표권을 보호하고 상품 또는 용역의 동일성을 유지하기 어렵다는 사실이 객관적으로 인정될 것
- ③ 가맹본부가 미리 정보공개서를 통하여 가맹점사업자에게 해당 사실을 알리고 가맹점사업자와 계약을 체결할 것

3) 범위반에 해당할 수 있는 행위(예시)

- ① 가맹본부가 가맹사업의 목적 달성에 필요한 범위 밖에 있는 설비 또는 기기의 구입 및 설치를 자기 또는 자기가 지정한 자로부터 하도록 가맹점사업자에게 강제하는 행위 (대법원 2006.3.10. 선고 2002두332 판결, 대법원 2018.11.9. 선고 2015두59686 판결)
- ② 가맹본부가 가맹점사업자로 하여금 가맹사업의 목적달성에 필요한 범위 밖에 있는 일반공산품을 가맹본부로부터만 공급받도록 하는 행위 (대법원 2006.3.10. 선고 2002두332 판결)
- ③ 다른 업체를 선택할 권한이 없는 상태에서 가맹점 인테리어 시공의 기본공사 부분과 추가공사 부분을 가맹본부 또는 특정 사업자에게만 맡기도록 하는 행위 (대법원 2018.11.9. 선고 2015두59686 판결)
- ④ 가맹점사업자들과 가맹계약서와는 별도로 홍보협의를 작성하거나 홍보예치금을 미리 받는 등의 방법으로 가맹점사업자로 하여금 자신으로부터만 홍보전단지를 구매하도록 하는 행위 (공정위 의결 제2018-346호, 2018.11.26. 2016가맹3591)
- ⑤ 자신 또는 자신이 지정하는 사업자가 아닌 다른 사업자로부터 구입하여도 가맹본부의 상표권 보호나 상품 또는 용역의 동일성 유지에 문제가 없음에도 불구하고 부자재 등을 자신 또는 자신이 지정하는 사업자와 거래하도록 강제하는 행위 (공정위 의결 제2018-49호, 2018.1.17. 2016가맹3583)
- ⑥ 중심 상품의 맛·품질과 직접적 관련이 없고 가맹사업의 통일적 이미지에도 영향을 주지 않으며, 가맹점사업자가 일정한 품질기준에 맞게 자유롭게 구매하더라도 그 용도나 기능에 지장이 없음에도 불구하고 일반공산품 및 주문생산품을 가맹본부 자신으로부터만 구입하지 않으면 가맹계약을 해지하도록 규정한

고 강제한 행위 (공정위 2018.2.5. 의결 2018-68호) 등

다. 가맹점사업자의 상품 또는 용역의 판매제한

가맹점사업자에게 부당하게 지정된 상품 또는 용역만을 판매하도록 하거나 거래상대방에 따라 상품 또는 용역의 판매를 제한하는 행위. 다만, 다음의 요건을 모두 충족하는 경우에는 그러하지 아니하다. (시행령 별표2)

- (1) 가맹점사업자의 상품 또는 용역의 판매를 제한하지 아니하는 경우에는 가맹본부의 상표권을 보호하고 상품 또는 용역의 동일성을 유지하기 어렵다는 사실이 객관적으로 인정될 것
- (2) 가맹본부가 미리 정보공개서를 통하여 가맹점사업자에게 해당 사실을 알리고 가맹점사업자와 계약을 체결할 것

1) 대상행위

가) 가맹점사업자에게 지정된 상품 또는 용역만을 판매하도록 하거나 거래상대방에 따라 상품 또는 용역의 판매를 제한하는 행위가 대상이 된다.

나) 이러한 행위는 기본적으로 가맹점사업자 스스로 판매할 상품 또는 용역이나 자신의 거래상대방을 정할 수 있는 영업활동의 자유를 제한하는 것으로 금지된다. 다만, 이러한 제한 행위라 하더라도 다음 요건을 모두 충족하는 경우에는 예외적으로 허용된다.

- ① 가맹점사업자의 상품 또는 용역의 판매를 제한하지 아니하는 경우에는 가맹본부의 상표권을 보호하고 상품 또는 용역의 동일성을 유지하기 어렵다는 사실이 객관적으로 인정되는 경우
- ② 가맹본부가 정보공개서를 통하여 가맹점사업자에게 해당 사실을 사전에 알리고 가맹점사업자와 계약을 체결한 경우

2) 위법성 판단기준

상품 또는 용역의 판매제한행위의 위법성은 이 지침의 「Ⅲ. 1. 법 제12조의 위법성 판단기준」에서 제시되는 바에 따라 판단한다.

3) 법위반에 해당할 수 있는 행위(예시)

- ① 가맹사업의 통일성 내지 가맹사업 시스템의 유지와 무관한 이유로 가맹점사업

자의 판매상품을 지정하거나 거래상대방에 따라 판매를 부당하게 제한하는 행위

- ② 가맹본부의 상표권 침해 우려 등에 관한 객관적 근거 없이 가맹점사업자의 판매상품을 지정하거나 거래상대방에 따라 판매를 부당하게 제한하는 행위
- ③ 가맹본부가 정보공개서 등에 당해 사실을 가맹점사업자에게 사전에 알리지 않고 가맹점사업자의 판매상품을 지정하거나 거래상대방에 따라 판매를 부당하게 제한하는 행위 등

라. 영업지역의 준수강제

부당하게 가맹점사업자에게 영업지역을 준수하도록 조건을 붙이거나 이를 강제하는 행위. 다만, 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위는 그러하지 아니하다. (시행령 별표2)

- (1) 가맹본부가 가맹점사업자의 영업거점지역을 정하는 행위
- (2) 가맹점사업자가 자기의 영업지역에서의 판매책임을 다한 경우에 영업지역 외의 다른 지역에서 판매할 수 있도록 하는 행위
- (3) 가맹점사업자가 자기의 영업지역 외의 다른 지역에서 판매하고자 하는 경우 그 지역의 가맹점사업자에게 광고선전비 등 판촉비용에 상당하는 일정한 보상금을 지급하도록 하는 행위

1) 대상행위

가) 가맹본부가 가맹점사업자에게 영업지역을 준수하도록 조건을 붙이거나 이를 강제하는 행위가 대상이 된다.

나) 다만, 이러한 거래지역 제한은 그 제한 정도와 방식이 다양하게 나타날 수 있으며, 가맹본부의 엄격한 지역제한을 금지하기 위한 것으로 다음의 경우는 예외적으로 허용된다.

- ① 가맹본부가 가맹점사업자의 영업거점지역을 정하는 행위
- ② 가맹점사업자가 자기의 영업지역에서의 판매책임을 다한 경우에 영업지역 외의 다른 지역에서 판매할 수 있도록 하는 행위
- ③ 가맹점사업자가 자기의 영업지역 외의 다른 지역에서 판매하고자 하는 경우 그 지역의 가맹점사업자에게 광고선전비 등 판촉비용에 상당하는 일정한 보상금을 지급하도록 하는 행위

다) ‘영업지역을 준수하기 위해 조건을 부가하거나 강제하는 행위’에는 가맹사업자

가 이를 위반한 것을 이유로 가맹본부로부터 경고, 공급중단, 폐점 등의 조치를 받는다 하더라도 이의를 제기하지 않겠다는 각서의 작성, 서면경고 등이 해당한다. (공정위 2009.7.9. 의결 제2009-157호; 공정위 2000.11.15. 의결 제2000-163호)

2) 위법성 판단기준

가) 영업지역의 준수 강제의 위법성은 이 지침의 「Ⅲ. 1. 법 제12조의 위법성 판단 기준」에서 제시되는 바에 따라 판단한다.

나) 다만, 영업지역의 준수 강제가 부당한지 여부는 가맹점사업자 간 경쟁, 가맹브랜드 내 경쟁과 브랜드 간 경쟁의 여부에 따라 판단될 수 있다. 즉, 가맹본부가 가맹점사업자에게 영업지역 준수를 강제하려는 의도가 가맹점사업자간 경쟁을 제거하고자 하는 것이 명백하고, 당해 행위로 인한 브랜드 내 경쟁을 제한하는 효과는 매우 크나 브랜드 간 경쟁을 촉진하는 효과는 미미하면 부당성이 인정될 수 있다. (공정위 2009.7.9. 의결 제2009-157호)

3) 법위반에 해당할 수 있는 행위(예시)

- ① 가맹본부가 지정된 영업지역을 준수하도록 하면서 이를 위반할 경우 가맹점사업자에게 경고, 식품공급중단, 폐점 등의 조치를 하더라도 이의를 제기하지 않겠다는 내용의 각서를 받고, 미준수 가맹점사업자에게 경고, 식품공급중단 및 계약 연장거부 의사통보를 하는 행위 (공정위 2009.7.9. 의결 제2009-157호)
- ② 가맹계약서에서 가맹점 소재 지역 외에서는 배달판매 및 판촉행위를 금지하고, 자신의 배달구역을 넘어 다른 지역에 배달한 가맹점사업자에 대해 가맹계약서에 근거하여 서면으로 경고를 하는 행위 (공정위 2000.11.15. 의결(약) 제2000-163호) 등

마. 그 밖에 가맹점사업자의 영업활동의 제한

가목 내지 라목에 준하는 경우로서 부당하게 가맹점사업자의 영업활동을 제한하는 행위. 다만, 다음의 요건을 모두 충족하는 경우에는 그러하지 아니하다. (시행령 별표2)

- (1) 가맹점사업자의 영업활동을 제한하지 아니하는 경우에는 가맹본부의 상표권을 보호하고 상품 또는 용역의 동일성을 유지하기 어렵다는 사실이 객관적으로 인정될 것
- (2) 가맹본부가 미리 정보공개서를 통하여 가맹점사업자에게 해당 사실을 알리고 가맹점사업자와 계약을 체결할 것

1) 대상행위

가) 이상에서 규정한 구속조건부 거래행위에 준하는 경우로서 가맹점사업자의 영업 활동을 제한하는 행위가 대상이 된다.

나) 다만, 이러한 제한 행위라 하더라도 다음 요건을 모두 충족하는 경우에는 금지되지 아니 한다.

- ① 가맹점사업자의 상품 또는 용역의 판매를 제한하지 아니하는 경우에는 가맹본부의 상표권을 보호하고 상품 또는 용역의 동일성을 유지하기 어렵다는 사실이 객관적으로 인정되는 경우
- ② 가맹본부가 미리 정보공개서를 통하여 가맹점사업자에게 해당 사실을 알리고 가맹점사업자와 계약을 체결한 경우

2) 위법성 판단기준

구속조건부 거래행위에 준하는 기타의 영업활동 제한행위의 위법성은 이 지침의 「Ⅲ. 1. 법 제12조의 위법성 판단기준」에서 제시되는 바에 따라 판단한다.

3. 거래상 지위 남용 금지

가. 가맹본부의 거래상 지위 남용금지

- 1) 가맹본부가 거래상 우월적 지위가 있음을 이용하여 열등한 지위에 있는 가맹점사업자에 대하여 일방적으로 각종 물품구입 강제 등 각종 불이익을 부과하거나 경영에 간섭하는 것은 경제적 약자에게 불이익을 주는 행위로서, 공정한 거래기반을 침해하게 되므로 금지된다.
- 2) 가맹본부가 가맹점사업자에 대하여 거래상 우월적 지위를 가지고 있다고 인정되는 경우에 법 제12조 제1항 제3호가 적용된다. 가맹사업거래에서의 가맹본부의 거래상 지위는 시장지배적 지위와 같은 정도의 지위를 의미하는 것은 아니며, 최소한 가맹점사업자의 거래활동에 상당한 영향을 미칠 수 있는 지위로서 그 가맹점사업자와의 관계에서 상대적으로 결정된다.
- 3) 다만, 거래상 지위 남용 유형에 해당하는 행위를 허용하지 아니하는 경우 가맹본

부의 상표권을 보호하고 상품 또는 용역의 동일성을 유지하기 어렵다는 사실이 객관적으로 인정되는 경우로서 해당 사실에 관하여 가맹본부가 미리 정보공개서를 통하여 가맹점사업자에게 알리고 가맹점사업자와 계약을 체결하는 경우에는 예외적으로 허용될 수 있다.

- 3) 가맹본부가 가맹점사업자에 대해 거래상 지위를 갖는다고 하더라도 양 당사자 간 권리의무 귀속관계, 채권채무관계(예: 채무불이행, 손해배상청구, 지체상금 등) 등과 관련하여 계약서 및 관련 법령내용 등의 해석에 대해 다툼이 있는 경우에는 법 적용대상이 되지 않는다.

나. 가맹본부의 거래상 지위 판단기준

- 1) 가맹사업의 일반적 속성은 물론 법 제5조와 제6조에 따른 가맹본부와 가맹점사업자의 준수사항 등에 비추어 보면 가맹점사업자는 사업의 개시, 과정, 종료, 즉 가맹사업활동 전반에 있어서 가맹본부에 종속·의존할 수밖에 없는 만큼 거래상대방으로서 가맹점사업자에 대한 가맹본부의 거래상 지위 인정은 상대적으로 용이하다.
- 2) 가맹사업의 본질적 특성상 가맹사업의 동일성 유지를 위한 범위 내에서 가맹본부의 가맹점사업자에 대한 일정한 통제가 허용되는 점이나, 가맹점사업자의 경우 가맹본부로부터 영업행위 일체에 대한 지원을 받는 동시에 가맹점사업자가 원치 않는 시기에 계약이 해지될 경우 시설투자비용을 충분히 회수하기 어려워 경제적 손실이 예상되는 경우를 감안하면 가맹본부에 대한 가맹점사업자의 종속성은 강화될 수 있다. 이에 더하여, 가맹본부가 해당 가맹분야(시장)에서 지배적 지위에 상응하는 시장점유율을 보유하거나 상당히 높은 소비자선호도를 보이는 경우에도 거래상 지위가 보다 용이하게 인정될 수 있다.

다. 거래상 지위 남용의 유형

법 제12조 제2항은 제1항에 따른 구체적 유형 또는 기준을 시행령 제13조에 의하여 시행령 [별표 2]에 구체화하고 있고 있으며, 그 범위 안에서 특정업종 또는 특정행위에 적용되는 세부적인 불공정거래행위 유형 또는 기준을 정하여 고시할 수 있도록 하고 있다.

다. - 1. 구입강제

가맹점사업자에게 가맹사업의 경영과 무관하거나 그 경영에 필요한 양을 넘는 시설·설비·상품·용역·원재료 또는 부재료 등을 구입 또는 임차하도록 강제하는 행위 (시행령 별표 2)

1) 대상행위

가) 가맹본부가 가맹점사업자에게 가맹사업의 경영과 무관하거나 그 경영에 필요한 양을 넘는 시설·설비·상품·용역·원재료 또는 부재료 등을 구입 또는 임차하도록 강제하는 행위가 대상이 된다.

나) 가맹본부의 구입요청을 거부하여 불이익을 당하였거나 주위의 사정으로 보아 객관적으로 구입하지 않을 수 없는 사정이 인정되는 경우에는 구입강제가 있는 것으로 본다.

2) 위법성의 판단기준

구입강제의 위법성은 이 지침의 「Ⅲ. 1. 법 제12조의 위법성 판단기준」에서 제시되는 바에 따라 판단한다.

3) 법 제12조 제1항 제3호와의 관계

가맹본부의 가맹점사업자에 대한 구입강제 행위는 가맹점사업자에게 특정한 거래상 대방(가맹본부 포함)과 거래할 것을 강제하는 행위로 법 제12조 제1항 제3호에 위반될 수 있다.

4) 범위반에 해당될 수 있는 행위(예시)

- ① 가맹본부가 자기의 거래상 지위를 부당하게 이용하여 자기와 거래하는 가맹점 사업자들에게 구입할 의사가 없는 제품을 일괄출고하는 방식과 같이 구입을 강제하는 행위 (공정위 의결(약) 제2020-26호, 2020.4.22. 2018전사3631, 3644, 3645)
- ② 교육(학원) 가맹점에 가맹본부가 제공하는 교재 재고가 많이 남아있음에도 추가 구매를 강요하는 행위 등

다. - 2. 부당한 강요

부당하게 경제적 이익을 제공하도록 강요하거나 가맹점사업자에게 비용을 부담하도록 강요하는 행위 (시행령 별표 2)

1) 대상행위

가) 가맹점사업자에게 부당하게 금전·물품·용역 등의 경제상 이익을 제공하도록 강요하는 행위가 대상이 된다.

나) 경제상 이익에는 그 명칭에 상관없이 가맹본부 또는 제3자에게 경제적 가치가 있는 모든 것이 포함된다.

다) ‘강요’는 가맹점사업자의 자유로운 의사에 반하여 가맹본부가 요구하는 일정한 행위를 하게 하는 것을 말한다. 강요는 협박, 요구, 요청, 제안 등 방식에 관계없이 가맹점사업자로 하여금 가맹본부의 의사에 따르는 의사결정을 하도록 하는 상황을 만들거나 그러한 결과를 가져오도록 하는 행위 등 묵시적 강요를 포함한다.

라) 이익제공 강요에는 가맹본부 등(가맹본부의 계열회사 포함)에게 경제상 이익을 제공하도록 적극적으로 요구하는 행위뿐만 아니라 가맹본부가 부담하여야 할 비용을 가맹점사업자에게 전가하여 소극적으로 경제적 이익을 누리는 행위도 포함된다.

① 가맹본부의 점포환경개선 권유 또는 요구는 당해 가맹사업의 통일성 유지 및 가맹점사업자의 귀책사유로 인하여 발생한 문제 해결 등을 위한 경우로 한정하여 허용된다.

② 광고·판매촉진행사에는 명칭이나 형식에 상관없이 상품 또는 용역에 대한 수요를 늘려 판매를 증진시킬 목적으로 행하는 모든 행사 또는 활동을 포함한다.

마) 다만, 매출확대 등 이익증진에 공통의 이해관계를 가지는 경우 등에 발생한 비용을 합리적인 기준과 절차에 의하여 가맹본부가 가맹점사업자의 동의를 얻어 부담시키는 경우에는 이익제공을 강요한 것으로 볼 수 없다.

2) 위법성의 판단기준

경제상 이익제공 강요행위의 위법성은 이 지침의 「Ⅲ. 1. 법 제12조의 위법성 판단 기준」에서 제시되는 바에 따라 판단한다.

3) 법위반에 해당될 수 있는 행위(예시)

- ① 사전에 정보공개서나 가맹계약서에서 구체적으로 기재되지 않은 광고·판촉행사 등 계획에 따라 부담된 광고·판촉비의 지급을 강요하는 행위
- ② 가맹본부가 전국적인 판매촉진행사를 하면서 가맹점사업자의 영업지역에 판매촉진행사를 광고하는 광고전단지를 배포하게 하고 그 광고전단지 비용을 부담시킨 행위
- ③ 가맹본부가 통신회사 및 카드사와 제휴하여 할인행사 등을 실시하면서, 비용분담에 대하여 정보공개서를 통하여 사전에 가맹점사업자에게 알리거나 동의를 구하지 아니하고 할인행사 등에 따른 비용을 가맹점사업자에게 부담하도록 강요하는 행위

다. - 3. 부당한 계약조항의 설정 및 변경

가맹점사업자가 이행하기 곤란하거나 가맹점사업자에게 불리한 계약조항을 설정 또는 변경하거나 계약갱신과정에서 종전의 거래조건 또는 다른 가맹점사업자의 거래조건보다 뚜렷하게 불리한 조건으로 계약조건을 설정 또는 변경하는 행위 (시행령 별표 2)

1) 대상행위

가) 가맹점사업자가 이행하기 곤란하거나 가맹점사업자에게 불리한 계약조항을 설정 또는 변경하거나 계약갱신과정에서 종전의 거래조건 또는 다른 가맹점사업자의 거래조건보다 뚜렷하게 불리한 조건으로 계약조건을 설정 또는 변경하는 행위가 대상이 된다.

나) 가맹점사업자에게 일방적으로 불리한 거래조건을 당초부터 설정하였거나 기존의 거래조건을 불리하게 변경하는 것을 말한다. 거래조건에는 최초 가맹금, 보증금, 예치 가맹금, 차액가맹금, 가맹점 입지 선정기준, 가맹사업자와 그 종원업의 교육 및 계약·채용 기준, 가맹점 사업에 필요한 설비 등의 내역 및 공급방법·업체, 가맹금 납부 방식, 가맹영업 중의 비용 부담, 계약연장이나 재계약, 계약해지 조건, 기타 각종의 구속사항 등 모든 조건이 포함된다.

다) ‘이행이 곤란하거나 불리한’ 계약조건의 설정·변경의 경우에 있어서, 이행곤란 사유와 불리함의 정도는 당해 가맹점거래계약의 목적과 계약당사자로서 가맹점사업자의 객관적 사정에 비추어 판단한다.

라) '종전의 또는 다른 가맹점사업자의 거래조건에 비추어 뚜렷하게 불리한' 계약조건의 설정·변경에 있어서, 새로운 거래조건 또는 기존 거래조건의 불이익한 설정·변경에 대한 객관적 정당화 사유가 존재하는지 여부와 그 설정·변경의 정도가 종전의 거래조건 또는 다른 가맹점사업자의 거래조건에 비추어 뚜렷하게 불리하여 정상적 사업활동이 어려울 것이 예상되거나 가맹점사업자의 거래상 지위를 약화시킬 우려가 있는지 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

(2) 위법성의 판단기준

가) 부당한 계약조항의 설정 및 변경의 위법성은 이 지침의 「Ⅲ. 1. 법 제12조의 위법성 판단기준」에서 제시되는 바에 따라 판단한다.

나) 이행곤란사유 또는 불리함에 대해 가맹점사업자가 계약체결 이전에 이미 알고 있었는지 여부는 위법성 판단에 영향을 미치지 아니한다.

3) 법위반에 해당될 수 있는 행위(예시)

- ① 가맹점사업자가 계약기간으로부터 약 3년 후 가맹본부에게 계약해지 의사를 표시하였는데, 가맹본부가 계약 조항을 근거로 계약종료 후에도 가맹점사업자가 유사 또는 동종업종을 영위할 수 없음을 통지하는 행위
- ② 가맹계약 갱신과정에서 종전의 영업지역을 축소하는 내용으로 거래조건을 변경함으로써 가맹점사업자에게 부당하게 불이익을 주는 행위 (공정위 의결(약) 제 2020-72호, 2020.11.22. 2019구사2576, 서울고등법원 2016. 5. 26. 선고 2015누51554 판결)
- ③ 가맹계약 갱신과정에서 로열티 또는 가맹금을 인상하는 등 가맹점사업자에게 불리하게 변경된 내용이 포함된 갱신계약서를 송부하는 행위
- ④ 가맹점사업자가 법인인 경우 그 법인의 대표자 변경시 명의개서료를 가맹점사업자가 부담하여야 한다는 계약조항을 설정하는 행위 등

다. - 4. 경영간섭

정당한 이유 없이 특정인과 가맹점을 같이 운영하도록 강요하는 행위 (시행령 별표 2)

1) 대상행위

가) 정당한 이유 없이 특정인과 가맹점을 같이 운영하도록 강요하는 행위가 대상이 된다.

나) '강요'에는 명시적인 강요와 묵시적인 강요를 포함한다.

2) 위법성의 판단기준

경영간섭의 위법성은 이 지침의 「Ⅲ. 1. 법 제12조의 위법성 판단기준」에서 제시되는 바에 따라 판단한다.

3) 법위반에 해당될 수 있는 행위(예시)

- ① 가맹점사업자가 상권조사 및 점포임대 등 직접적 노력을 기울여 계약을 체결하고자 하였음에도, 가맹본부가 정당한 이유 없이 특정인과 함께 가맹점을 운영하도록 강요하는 행위 등

다. - 5. 판매목표 강제

부당하게 판매 목표를 설정하고 가맹점사업자로 하여금 이를 달성하도록 강제하는 행위 (시행령 별표 2)

1) 대상행위

가) 가맹본부가 가맹점사업자에게 부당하게 판매 목표를 정해주고 이를 달성하도록 강제하는 행위가 대상이 된다.

나) 판매목표 강제는 가맹계약서에 명시적으로 규정된 경우뿐만 아니라 계약체결 후 구두로 이루어지는 경우도 포함된다.

다) 판매목표의 대상이 되는 상품 또는 용역은 가맹본부가 공급하는 것이어야 하며, 대체로 상품의 경우에는 판매량의 할당이, 용역의 경우에는 일정수의 가입자나 회원의 확보가 문제된다.

2) 위법성의 판단기준

가) 판매목표 강제의 위법성은 이 지침의 「Ⅲ. 1. 법 제12조의 위법성 판단기준」에

서 제시되는 바에 따라 판단한다.

나) 거래내용의 공정성 판단시 판매목표 달성에 강제성이 있는지 여부를 중점적으로 판단한다. 판매목표의 달성을 '강제'하기 위한 수단에는 제한이 없으며, 목표가 과다한 수준인지, 실제 가맹점사업자가 목표를 달성하였는지 여부는 강제성 인정에 영향을 미치지 않는다. 목표불이행시 실제로 제재수단이 사용되었을 필요는 없다.

다) 목표를 달성하지 못했을 경우 가맹거래계약의 해지나 원·부재료의 공급거절 또는 공급량의 현저한 제한, 공급지연 등 불이익이 부과되는 경우에는 강제성이 인정되나, 가맹점사업자에게 장려금이나 지원금을 지급하는 등 자발적인 협력을 위한 수단으로 판매목표가 사용되는 경우에는 원칙적으로 강제성이 인정되지 않는다. 다만, 장려금이나 지원금이 정상적인 유통마진을 대체하는 효과가 있어 사실상 판매목표를 강제하는 효과를 갖는 경우에는 그러하지 아니하다.

3) 범위반에 해당될 수 있는 행위(예시)

- ① 가맹본부가 가맹점사업자에게 제시한 판매목표가 지나치게 과다함에도 불구하고 이를 달성하지 못하는 경우 계약갱신 거절이나 공급 제한 등 일정한 제재를 가하는 행위
- ② 가맹본부가 공급하는 용역을 제공하는 가맹점사업자에 대하여 회원 또는 가입자의 수를 할당하고 이를 달성하지 못할 경우 가맹계약 해지나 수수료지급 중단 등의 제재를 가하는 행위
- ③ 일정한 판매목표의 달성을 위하여 지급되는 장려금이나 지원금이 가맹점사업자의 판매촉진을 위한 수준을 넘어 마진을 강제하는 수준에 이른 경우
- ④ 가맹본부가 자신의 판매목표를 달성하거나 재고 소진 등을 위하여 가맹점사업자에 대하여 미판매 물량을 임의로 할당하고 가맹점사업자에게 재고와 비용을 부담하게 하는 행위 등

다. - 6. 불이익제공

구입강제, 부당한 강요, 부당한 계약조항의 설정 또는 변경, 경영간섭, 판매목표강제 행위에 준하는 경우로 가맹점사업자에게 부당하게 불이익을 주는 행위 (시행령 별표 2)

1) 대상행위

- 가) 가맹본부가 구입강제, 부당한 강요, 부당한 계약조항의 설정 또는 변경, 경영간섭, 판매목표 강제 행위에 준하는 경우로 가맹점사업자에게 부당하게 불이익을 주는 행위가 대상이 된다.
- 나) 불이익제공행위의 ‘불이익’에 해당하기 위해서는, 그 행위의 내용이 상대방에게 다소 불이익하다는 점만으로는 부족하고, 구입 강제, 이익제공 강요, 판매목표 강제 등과 동일시할 수 있을 정도로 일방 당사자가 자기의 거래상 지위를 부당하게 이용하여 그 거래조건을 설정 또는 변경하거나 그 이행과정에서 불이익을 준 것으로 인정되어야 한다. (대법원 2018.11.9. 선고 2015두59686 판결)
- 다) 가맹본부의 가맹점사업자에 대한 불이익제공은, 가맹점사업자에게 일방적으로 불리한 거래조건을 당초부터 설정하였거나 기존의 거래조건을 불리하게 변경하는 것은 물론 거래과정에서 일정한 행위를 강요하여 가맹점사업자에게 불이익이 되도록 하는 행위 전반을 포함하는 포괄적 개념이다.
- 라) 불이익제공은 적극적으로 가맹점사업자에게 불이익이 되는 행위를 하는 작위뿐만 아니라 소극적으로 자기가 부담해야 할 비용이나 책임 등을 이행하지 않는 부작위에 의해서도 성립할 수 있다.
- 마) 가맹계약기간 중에 합리적인 이유 없이 거래를 중단하여 불이익을 주는 행위는 거래거절, 가맹계약의 해지를 포함한다.

2) 위법성의 판단기준

불이익 제공의 위법성은 이 지침의 「Ⅲ. 1. 법 제12조의 위법성 판단기준」에서 제시되는 바에 따라 판단한다.

3) 범위반에 해당될 수 있는 행위(예시)

- ① 가맹본부가 모든 가맹점사업자에게 판매촉진활동의 일환으로 실시하는 할인판매 행사에 대한 비용분담 비율을 합의하였음에도, 당해 할인행사 실시 후 가맹본부가 거래상 지위를 이용하여 자신이 부담하기로 한 비용의 전부 또는 일부를 가맹점사업자에게 전가하는 행위
- ② 가맹본부가 계약기간 중에 일방적으로 기존 가맹점사업자의 인근에 신규 가맹점을 개설하는 방법으로 거래상 지위를 이용하여 가맹점사업자에게 부당하게 불이

익을 주는 행위 (서울고법 2014.11.14. 선고 2014누4271 판결) 등

4. 부당한 손해배상의무 부과행위

법 제12조 제1항 제5호에 따른 계약의 목적과 내용, 발생할 손해 등 대통령령으로 정하는 기준에 비하여 과중한 위약금을 부과하는 등 가맹점사업자에게 부당하게 손해배상의무를 부담시키는 행위 (법 제12조 제1항 제5호)

법 제12조 제1항 제5호에서 “계약의 목적과 내용, 발생할 손해 등 대통령령으로 정하는 기준”이란, ① 계약의 목적과 내용, ② 발생할 손해액의 크기, ③ 당사자 간 귀책사유 유무 및 정도, ④ 해당 업종의 정상적인 거래관행을 말함 (시행령 제12조의2)

여기에는 과중한 위약금 설정·부과행위, 소비자 피해에 대한 손해배상의무 전가행위, 부당한 영업위약금 부과행위가 해당되며, 이에 준하는 경우로서 가맹점사업자에게 부당하게 손해배상의무를 부담하도록 하거나 가맹본부가 부담해야 할 손해배상의무를 가맹점사업자에게 전가하는 행위가 해당됨 (시행령 별표 2)

가. 과중한 위약금 설정·부과행위

1) 대상행위

가) ‘계약 중도해지 시 과중한 위약금 설정·부과 행위’와 ‘과중한 지연손해금 설정·부과행위’가 과중한 위약금 설정·부과 행위에 해당한다.

나) ‘계약 중도해지 시 과중한 위약금 설정·부과 행위’는 가맹본부가 가맹사업자에 대하여 계약해지의 경위 및 거래당사자 간 귀책사유 정도, 잔여계약기간의 정도, 중도해지 후 가맹본부가 후속 가맹점사업자와 계약을 체결하기 위하여 통상 소요될 것으로 예상되는 기간에 상당하는 손해액 등에 비추어 부당하게 과중한 위약금을 설정하여 계약을 체결하거나 이를 부과하는 행위를 말한다.

다) ‘과중한 지연손해금 설정·부과행위’는 상품 또는 용역에 대한 대금지급의 지연 시 지연경위, 정상적인 거래관행 등에 비추어 과중한 지연손해금을 설정하여 계약을 체결하거나 이를 부과하는 행위를 의미한다.

2) 위법성의 판단기준

과중한 위약금 설정·부과행위의 위법성은 이 지침의 「Ⅲ. 1. 법 제12조의 위법성 판단기준」에서 제시되는 바에 따라 판단한다.

3) 법위반에 해당될 수 있는 행위(예시)

- ① 가맹계약 후 가맹점사업자의 귀책사유 없이 경영적자가 지속되어 가맹점 유지가 어려운 상황에서 불가피하게 폐점하였음에도 가맹본부가 과도한 영업위약금을 요구하는 행위 등

나. 소비자 피해에 대한 손해배상의무 전가행위

1) 대상행위

가맹본부가 가맹점사업자에게 공급한 물품의 원시적 하자 등으로 인하여 소비자 피해가 발생한 경우까지도 부당하게 가맹점사업자가 손해배상의무를 모두 부담하도록 계약을 체결하는 행위가 해당된다.

2) 위법성의 판단기준

소비자 피해에 대한 손해배상의무 전가행위의 위법성은 이 지침의 「Ⅲ. 1. 법 제12조의 위법성 판단기준」에서 제시되는 바에 따라 판단한다.

3) 법위반에 해당될 수 있는 행위(예시)

- ① 가맹본부가 상품을 직접 제조하지 않았다는 이유를 들어 공급한 물품의 하자로 인한 손해배상의무를 가맹점사업자에게 전가하는 행위

다. 부당한 영업위약금 부과행위

1) 대상행위

가) 가맹점사업자가 영업을 개시한 날이 속하는 달의 다음 달부터 1년간의 평균 매출액이 가맹본부가 법 제9조 제3항 및 제5항에 따라 제공한 예상매출액의 최저액에 미달하여 가맹점사업자가 계약을 중도에 해지하는 경우에 가맹본부가 계약 해지에 따른 기대이익 상실을 이유로 위약금을 부과하는 행위가 대상이 된다.

나) 다만, 가맹점사업자의 가맹계약 위반, 가맹본부가 제시한 경영방침 미준수 또는 이에 준하는 사유로 인하여 평균 매출액이 예상매출액의 최저액에 미달한 경우는 제외한다.

다) 가맹점사업자의 가맹계약 위반, 가맹본부가 제시한 경영방침 미준수 또는 이에 준하는 사유에 대한 입증책임은 가맹본부가 부담한다.

2) 위법성의 판단기준

가) 부당한 영업위약금 부과행위의 위법성은 이 지침의 「Ⅲ. 1. 법 제12조의 위법성 판단기준」에서 제시되는 바에 따라 판단한다.

나) 특히, 위약금의 부당성 판단은 법 시행령 제12조의2 각 호의 기준에 의한다.

3) 법위반에 해당될 수 있는 행위(예시)

- ① 가맹계약서에 가맹점사업자가 비밀유지의무 및 경업금지의무를 위반할 경우 손해배상액으로 5천만 원을 부담하도록 규정하는 조항을 포함하여 가맹계약을 체결하는 행위 (공정위 의결(약) 제2021-7호, 2021.2.9. 2018가맹2255)
- ② 가맹점사업자와의 가맹계약이 해지된 이후에도 기존 가맹점사업자가 사용하던 주문전화번호 사용을 중지하지 않는다는 이유로 위약금 1.8천만 원을 청구하는 소를 제기하는 행위 (공정위 의결(약) 제2018-102호, 2018.11.29. 2016서경3382)
- ③ 가맹본부가 가맹점사업자와 계약 시 매출액에 대한 일일송금의무를 규정하고, 이를 이행하지 않았다는 이유로 가맹계약 해지를 통고하고 가맹계약 위반에 대한 위약금을 청구하는 행위 (대법원 2000.6.9. 선고 98다45553 판결)
- ④ 가맹본부가 가맹희망자에게 부풀린 예상매출액을 제공하였으나 가맹점사업자가 이러한 예상매출액의 최저액 미달을 이유로 계약을 중도 해지하는 경우에 위약금을 부과하는 행위 등

5. 부당한 점포환경개선 강요행위

가맹본부는 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이 점포환경개선을 강요하여서는 아니 됨 (법 제12조의2 제1항)

“점포환경개선”이란 가맹점 점포의 기존 시설, 장비, 인테리어 등을 새로운 디자인이나 품질의 것으로 교체하거나 신규로 설치하는 것을 말한다. 이 경우 점포의 확장 또는 이전을 수반하거나 수반하지 아니하는 경우를 모두 포함함 (법 제2조 제11호)

1) 대상행위

가) 가맹본부가 점포환경개선을 강요하는 행위가 해당되며, 대통령령으로 정하는 정당한 사유에 해당하는 경우는 예외로 한다.

나) ‘대통령령으로 정하는 정당한 사유’란, ① 점포의 시설, 장비, 인테리어 등의 노후화가 객관적으로 인정되는 경우, 또는 ② 위생 또는 안전의 결함이나 이에 준하는 사유로 인하여 가맹사업의 통일성을 유지하기 어렵거나 정상적인 영업에 현저한 지장을 주는 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

다) 이때의 ‘강요’는 가맹점사업자의 자유로운 의사에 반하여 가맹본부가 요구하는 일정한 행위를 하게 하는 것을 말한다. 강요는 협박, 요구, 요청, 제안 등 방식에 관계없이 가맹점사업자로 하여금 가맹본부의 의사에 반하는 의사결정을 하도록 하는 상황을 만들거나 그러한 결과를 가져오도록 하는 행위 등 묵시적 강요를 포함한다.

라) 가맹본부는 가맹점사업자의 점포환경개선에 소요되는 비용으로서 대통령령으로 정하는 비용의 100분의 40 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율에 해당하는 금액을 부담하여야 한다.

마) ‘대통령령으로 정하는 비용’이란, ① 간판 교체비용, ② 인테리어 비용(장비·집기의 교체비용을 제외한 실내건축공사에 소요되는 일체의 비용)을 말한다. 다만, 인테리어 공사비용 중 가맹사업의 통일성과 관계없이 가맹점사업자가 추가 공사를 함에 따라 발생한 비용은 가맹본부의 부담에서 제외한다.

바) ‘대통령령으로 정하는 비율’은 점포환경개선의 정도에 따라 다음과 같이 구분된다.

- ① 점포의 확장 또는 이전을 수반하지 아니하는 점포환경개선의 경우: 100분의 20
- ② 점포의 확장 또는 이전을 수반하는 점포환경개선의 경우: 100분의 40

사) 다만, 법 제12조의2 제2항 각 호에 의하여, ① 가맹본부의 권유 또는 요구가 없음에도 가맹점사업자의 자발적 의사에 의하여 점포환경개선을 실시하는 경우, 또는 ② 가맹점사업자의 귀책사유로 인하여 위생·안전 및 이와 유사한 문제가 발생하여 불가피하게 점포환경개선을 하는 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우는 예외로 한다.

(아) 이때 가맹점사업자의 '자발성'은 가맹점사업자에 대한 가맹본부의 경영계획의 일환으로서 점포환경개선 계획을 공지나 요청 등이 없이 가맹점사업자 스스로 결정한 경우로, 점포환경개선 실시에 관여할 수 있는 가맹본부가 어떠한 권유 또는 요구를 하지 않았음에도 가맹점사업자 스스로의 의사에 따라 점포환경개선을 실시한 것이 명백한 사안으로 한정하여 자발성이 인정될 수 있다.

자) 법 제12조의2 제2항 제2호의 예외사유는 가맹점사업자의 정상적인 영업에 현저한 지장을 줄 정도의 위생·안전 및 이와 유사한 문제가 현실적으로 발생해야 하는 것으로 한정하여 해석하여야 하고, 시행령 제13조의2 제1항 각 호의 사유보다 좁게 해석하는 이상 점포 시설의 노후화가 바로 법 제12조의2 제2항 제2호의 위생·환경 및 이와 유사한 문제에 해당한다고 볼 수 없으며 브랜드 평판 저하, 전체 매출에 대한 영향 등의 문제가 이에 해당한다고 할 수도 없다. (서울고법 2019.1.23. 선고 2018누48726 판결; 대법원 2019.6.19. 선고 2019두35985 판결)

차) 가맹본부가 법정부담액을 지급하지 않을 수 있는 위의 예외사유에 해당하는지 여부는 가맹본부가 입증하여야 한다.

2) 위법성의 판단기준

부당한 점포환경개선 강요 행위의 위법성은 이 지침의 「Ⅲ. 2. 법 제12조의2 및 제12조의4의 위법성 판단기준」에서 제시되는 바에 따라 판단한다.

3) 법 제12조와의 관계

정당한 사유 없이 가맹본부가 가맹점사업자에 대하여 점포환경개선을 강요하는 행위는 거래상 지위를 이용하여 부당하게 가맹사업자에게 불이익을 주는 행위로 법 제12조 제1항 제3호에 위반될 수 있다.

4) 법위반에 해당될 수 있는 행위(예시)

- ① 가맹본부가 가맹점사업자에게 점포환경개선을 실시하도록 권유 또는 요구하였음에도 가맹점사업자가 점포환경개선에 지출한 비용을 법정비율 미만으로 부담하는 것과 같은 행위 (공정위 의결 제2018-234호, 2018.7.5. 2017제하1958; 제2018-126호, 2018.4.23. 2016가맹2547)

- ② 가맹본부는 가맹점사업자가 리뉴얼 공사에 소요한 총 비용의 20%를 지급해야 함에도 불구하고, 가맹본부가 리뉴얼 공사에 소요된 비용 중 일부 항목을 임의로 조정함으로써 실제로는 20%에 미치지 못하는 수준의 비용만을 부담하는 행위 (공정 위 2017.8.1. 의결 제2017-268호) 등

6. 부당한 영업시간 구속행위

가맹본부는 정상적인 거래관행에 비추어 부당하게 가맹점사업자의 영업시간을 구속하는 행위를 하여서는 아니 됨 (법 제12조의3 제1항)

1) 대상행위

가) 가맹본부가 정상적인 거래관행에 비추어 부당하게 가맹점사업자의 영업시간을 구속하는 행위가 대상이 되며, 다음과 같은 가맹본부의 행위는 부당한 영업시간 구속으로 본다.

- ① 가맹점사업자의 점포가 위치한 상권의 특성 등의 사유로 대통령령으로 정하는 심야 영업시간대의 매출이 그 영업에 소요되는 비용에 비하여 저조하여 대통령령으로 정하는 일정한 기간 동안 영업손실이 발생함에 따라 가맹점사업자가 영업시간 단축을 요구함에도 이를 허용하지 아니하는 행위
- ② 가맹점사업자가 질병의 발병과 치료 등 불가피한 사유로 인하여 필요 최소한의 범위에서 영업시간의 단축을 요구함에도 이를 허용하지 아니하는 행위

나) ‘대통령령으로 정하는 심야 영업시간대’란 오전 0시부터 오전 6시까지 또는 오전 1시부터 오전 6시까지를 말한다.

다) ‘대통령령으로 정하는 일정한 기간’이란 가맹점사업자가 영업시간 단축을 요구한 날이 속한 달의 직전 3개월을 말한다.

2) 위법성의 판단기준

부당한 영업시간 구속 행위의 위법성은 이 지침의 「Ⅲ. 3. 법 제12조의3의 위법성 판단기준」에서 제시되는 바에 따라 판단한다.

3) 범위반에 해당될 수 있는 행위(예시)

- ① 가맹점사업자 점포의 위치와 상권의 특성 등으로 인하여 오전 0시 또는 오전 1시부터 오전 6시까지의 매출액이 당해 시간 대 영업비용에 비하여 저조하여 가맹점사업자가 영업시간의 단축을 요구한 날이 속한 달의 직전 3개월 동안 영업손실이 지속적으로 발생하여 가맹점사업자가 가맹본부영업시간 영업시간 단축을 요구했음에도 불구하고 이를 허용하지 않는 행위
- ② 가맹점사업자가 질병의 발병과 치료 등 불가피한 사유로 필요 최소한의 범위에서 영업시간의 단축을 가맹본부에 요구하였음에도 불구하고 이를 허용하지 않는 행위
- ③ 가맹본부가 야간영업의 허용 여부를 판단하기 위한 매출액 기준을 지나치게 낮게 설정함으로써 가맹점사업자의 영업시간 단축 요구를 사실상 불가능하게 하는 경우 등

7. 부당한 영업지역 침해행위

가맹본부는 가맹계약 체결 시 가맹점사업자의 영업지역을 설정하여 가맹계약서에 이를 기재하여야 함 (법 제12조의4 제1항)

가맹본부가 가맹계약 갱신과정에서 상권의 급격한 변화 등 대통령령으로 정하는 사유가 발생하여 기존 영업지역을 변경하기 위해서는 가맹점사업자와 합의하여야 함 (동조 제2항)

가맹본부는 정당한 사유 없이 가맹계약기간 중 가맹점사업자의 영업지역 안에서 가맹점사업자와 동일한 업종(수요층의 지역적·인적 범위, 취급품목, 영업형태 및 방식 등에 비추어 동일하다고 인식될 수 있을 정도의 업종을 말한다)의 자기 또는 계열회사(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조 제12호에 따른 계열회사를 말한다. 이하 같다)의 직영점이나 가맹점을 설치하는 행위를 하여서는 아니 됨 (동조 제3항)

“영업지역”이란 가맹점사업자가 가맹계약에 따라 상품 또는 용역을 판매하는 지역을 말함 (법 제2조 제12호)

1) 대상행위

가) 가맹본부가 가맹계약 체결 시 가맹계약서에 기재한 가맹점사업자의 영업지역을 정당한 이유 없이 침해하는 행위가 대상이 되는데, 보다 구체적으로 가맹본부는 정당한 사유 없이 가맹계약기간 중 가맹점사업자의 영업지역 안에서 가맹점사업자와 동일한 업종(수요층의 지역적·인적 범위, 취급품목, 영업형태 및 방식 등에 비추어 동일하다고 인식될 수 있을 정도의 업종)의 자기 또는 계열회사의 직영점이나 가맹점을 설치하는 행위를 하여서는 아니 된다.

나) 한편, 가맹본부가 가맹계약 갱신과정에서 상권의 급격한 변화 등 대통령령으로 정하는 사유가 발생하여 기존 영업지역을 변경하기 위해서는 가맹점사업자와 합의하여야 한다.

다) 영업지역 변경이 허용되는 ‘대통령령으로 정하는 사유’는 ① 재건축, 재개발 또는 신도시 건설 등으로 인하여 상권의 급격한 변화가 발생하는 경우, ② 해당 상권의 거주인구 또는 유동인구가 현저히 변동되는 경우, ③ 소비자의 기호변화 등으로 인하여 해당 상품·용역에 대한 수요가 현저히 변동되는 경우, ④ 이상의 상황에 준하는 경우로서 기존 영업지역을 그대로 유지하는 것이 현저히 불합리하다고 인정되는 경우를 말한다.

라) “직영점이나 가맹점을 설치하는 행위”란 신규 가맹점으로서 외관을 실제로 갖춘 행위를 말하고, 실제로 영업개시를 했을 것을 요하지는 않는다. (서울고법 2020.2.5. 선고 2019누55448 판결)

2) 위법성의 판단기준

부당한 영업지역 침해 행위의 위법성은 이 지침의 「Ⅲ. 2. 법 제12조의2 및 제12조의4의 위법성 판단기준」에서 제시되는 바에 따라 판단한다.

3) 범위반에 해당될 수 있는 행위(예시)

- ① 가맹계약서상에 가맹점사업자의 영업지역을 설정하지 아니하거나 불완전하게 설정하는 것과 같은 행위(공정위 의결(약) 제2020-40호, 2020.7.15. 2018서경3020; 공정위 의결(약) 제2018-6호, 2018.1.11. 2017서경0293)
- ② 가맹희망자와 가맹계약을 체결하면서 가맹점사업자의 영업지역을 설정하고도 이를 가맹계약서에 기재하지 아니하는 행위(공정위 의결(약) 제2018-80호, 2018.9.18. 2017부사0824)
- ③ 가맹본부가 양수한 사업장을 정당한 이유 없이 해당 가맹점사업자가 운영하던 영업지역 내로 이전·설치한 행위(공정위 의결 제2018-235호, 2018.7.16. 2017서경1235)
- ④ 가맹본부가 정당한 이유 없이 가맹계약기간 중 가맹점사업자의 영업지역 안에서 가맹점사업자와 동일한 업종의 자기 또는 계열회사의 직영점이나 가맹점을 설치하는 것과 같은 행위 (공정위 의결 제2018-51호, 2018.1.17. 2016서제3233)
- ⑤ 가맹본부와 가맹계약을 체결하면서 당해 가맹점으로부터 반경 1km 내에 신규 가맹점 또는 직영점을 개점할 수 없음을 계약서에 명시하였음에도 불구하고, 가

맹본부가 약 500m 떨어진 곳에 가맹본부의 직영점을 개설·운영하는 행위

- ⑥ 가맹본부가 가맹점사업자와 계약을 체결하면서 ‘지하철 역사 및 그 일대, 지하상가, 외국인 상권 등’ 그 지역 자체를 영업지역으로 설정할 뿐, 영업지역 설정거리 등 그 범위를 구체적으로 밝히지 않는 행위 (공정위 의결 제2017-080호, 2017.1.26. 2016가맹3079 2016서제2397) 등

8. 보복조치 행위

가맹본부는 가맹점사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 것을 이유로 그 가맹점사업자에 대하여 상품·용역의 공급이나 경영·영업활동 지원의 중단, 거절 또는 제한, 가맹계약의 해지, 그 밖에 불이익을 주는 행위를 하거나 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 됨 (법 제12조의5)

1. 제22조 제1항에 따른 분쟁조정 신청
2. 제32조의2에 따른 공정거래위원회의 서면실태조사에 대한 협조
3. 제32조의3 제1항에 따른 신고 및 같은 조 제2항에 따른 공정거래위원회의 조사에 대한 협조

1) 대상행위

가) 가맹점사업자의 분쟁조정 신청, 공정위의 조사 또는 서면실태조사에 대한 협조, 법 위반 사실의 공정위 신고 등을 이유로 가맹점사업자에게 상품·용역의 공급이나 경영·영업활동 지원의 중단, 거절 또는 제한, 가맹계약의 해지, 그 밖에 불이익을 주는 행위가 대상이 된다.

나) 가맹점사업자에게 불이익을 주는 행위는 상품·용역의 공급이나 경영·영업활동 지원의 중단, 거절 또는 제한 및 계약 해지 외에 보복개점 등은 물론이고 거래 조건 설정이나 거래과정 등에서 합리적 이유 없이 다른 가맹점보다 차별적으로 불리하게 취급하는 행위도 포함한다.

2) 위법성의 판단기준

가) 보복조치의 위법성은 이 지침의 「Ⅲ. 2. 법 제12조의5의 위법성 판단기준」에서 제시되는 바에 따라 판단한다.

나) 보복조치는 구입강제 등 다른 행위 유형들과 달리 거래를 전제로 하지 않으며, 공정위 신고나 조사 협조, 분쟁조정 신청 등의 원인행위를 이유로 이루어지는 악의에 기한 행위이다.

다) 따라서, 가맹본부가 가맹사업자에 대하여 위와 같은 불이익한 행위 또는 조치를 취하면서 법 제12조의5 각 호에 해당하지 않는 이유를 제시하더라도, 실질적으로 그와 같은 가맹점사업자의 행위에 따른 행위라면 가맹본부의 보복의사가 인정된다.

라) 가맹점사업자에 대한 가맹본부의 보복의사는 가맹점사업자에 의한 이른바 원인 행위에 따른 가맹본부의 불이익 한 조치에 이르는 과정 전반은 물론 당해 조치 전후의 정황사실을 종합적으로 고려하여 판단하도록 한다.

3) 범위반에 해당될 수 있는 행위(예시)

- ① 가맹본부의 가맹사업법 위반사실을 공정위에 신고하였다는 이유로 정당한 사유 없이 가맹계약 갱신을 거절하거나 계약을 해지하는 행위
- ② 가맹점사업자가 공정위 조사에 협조하였다는 이유로 정당한 사유 없이 상품·용역의 공급이나 경영·영업활동 지원의 중단, 거절 또는 제한하는 등의 방법으로 가맹점사업자의 사업활동을 곤란하게 하는 행위
- ③ 가맹점사업자가 분쟁조정을 신청하였다는 이유로 정당한 이유 없이 거래조건 또는 지원사항 등을 다른 가맹점사업자에 비하여 현저히 불리하게 변경하는 행위
- ④ 가맹점사업자가 공정위에 신고하고 조사에 협조하였다는 이유로, 가맹계약 기간 중임에도 불구하고 정당한 이유 없이 당해 가맹점사업자의 영업지역 안에서 가맹본부의 직영점을 개점하거나 가맹점사업자와 유사한 업종의 가맹점을 개설하는 행위(이른바, ‘중복출점’ 또는 ‘보복출점’ 행위) 등